

FAMILIA

Apunte realizado en base al libro "Derecho de Familia, Tomo I y II" de Ramón Ramos Pazos.

INTRODUCCIÓN

El derecho de familia es aquella rama del derecho civil que se dedica al conjunto de problemáticas relativas a los aspectos jurídicamente relevantes de las relaciones de familia. En tal sentido, si bien constituye una rama del derecho civil, es necesario resaltar algunas peculiaridades que la distinguen de la generalidad del derecho civil patrimonial.

En primer lugar, la regulación legal de la familia es especialmente sensible respecto de los cambios ideológicos, valorativos y culturales de una sociedad determinada. En nuestro caso concreto, esto ha implicado una importante evolución en los principios inspiradores del derecho de familia, desde las primeras regulaciones legales de la república hasta nuestros días. Es importante estudiar la normativa legal vigente teniendo esta idea en mente.

Por otro lado, y de la mano de lo anterior, uno de los rasgos más determinantes del derecho de familia actual es una tendencia al cambio, con un impulso a la materialización de las ideas modernas de la igualdad y la no discriminación. En este mismo sentido, para muchos autores y autoras es preferible hablar de "Derecho de las familias", precisamente para subrayar el carácter plural de las familias en nuestras sociedades contemporáneas.

Por último, en un plano estrictamente normativo, también debemos subrayar la dispersión de las reglas relevantes en el derecho de familia. Además de encontrar normas relevantes en los libros I, III y IV de Código Civil, es necesario tener en cuenta otros cuerpos normativos como la Nueva Ley de Matrimonio Civil, la Ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, entre otros. Es muy importante estudiar el derecho de familia teniendo la normativa legal a mano. Dado que la mayoría de estas normas son de orden público, reciben aplicación directa en las relaciones de familia. Su manejo preciso resulta, por consiguiente, fundamental.

ÍNDICE

1. Introducción	6
1.1 Concepto de familia	6
1.2 Derecho de familia	7
1.3 Principios del derecho de familia	9
1.3.1 Principios de la época de dictación del CC.....	9
1.3.2 Modernos principios del derecho de familia	10
1.4 Parentesco	14
2. Los esponsales.....	16
3. El matrimonio	18
3.1 Definición.....	18
3.2 Requisitos de existencia del matrimonio	19
3.3 Requisitos de validez del matrimonio	20
3.3.1 Consentimiento libre y espontáneo.....	20
3.3.2 Capacidad y ausencia de impedimentos dirimentes	21
3.3.3 Formalidades legales del matrimonio	26
4. Término de la vida en común de los cónyuges	30
4.1 Separación de hecho.....	30
4.2 Separación judicial	32
4.3 Término del matrimonio por muerte natural	35
4.4 Término del matrimonio por muerte presunta	36
4.5 Término del matrimonio por sentencia firme de nulidad	37
4.5.1 Matrimonio putativo	41
4.6 Término del matrimonio por sentencia firme de divorcio	42
4.6.1 Divorcio sanción o por culpa	42
4.6.2 Divorcio de común acuerdo	43
4.6.2 Divorcio unilateral	43
5. Reglas comunes a ciertos casos de separación, nulidad y divorcio	47
5.1 Compensación económica	47
5.2 Conciliación	51
5.3 Mediación	51
6. Efectos del matrimonio	53
6.1 Relaciones personales de los cónyuges	53
6.2 Régimen matrimonial	56
6.3 Sociedad conyugal	57
6.3.1 Capitulaciones matrimoniales	58
6.3.2 Haberes en la sociedad conyugal	60
6.3.2.1 Haber absoluto	60
6.3.2.2 Haber relativo	63
6.3.2.3 Haber propio o personal de cada cónyuge	64
6.3.3 Presunciones de dominio de la sociedad conyugal	70
6.3.4 Pasivo de la sociedad conyugal	71
6.3.4.1 Pasivo real o absoluto	71
6.3.4.2 Pasivo aparente o relativo	74

6.3.5	Recompensas	74
6.3.6	Administración ordinaria de la sociedad conyugal	76
6.3.6.1	Administración de los bienes sociales	77
6.3.6.2	Administración de los bienes propios	79
6.3.7	Administración extraordinaria de la sociedad conyugal	82
6.3.8	Disolución de la sociedad conyugal	84
6.3.9	Beneficio de emolumento	87
6.3.10	Patrimonio reservado de la mujer casada	89
6.3.11	Mecanismos de protección a la mujer casada	93
6.3.12	Proyecto de ley de reforma a la sociedad conyugal	94
6.4	Participación en los gananciales	95
6.4.1	Funcionamiento del sistema a la extinción del régimen	96
6.4.2	Del crédito de participación	99
6.4.3	Extinción del régimen de participación en los gananciales	100
6.5	Separación de bienes	100
6.5.1	Separación de bienes legal	100
6.5.2	Separación de bienes judicial	102
6.5.3	Separación de bienes convencional	104
7.	Bienes familiares	105
7.1	Cuestiones generales	105
7.2	Forma de constituir un bien como familiar	106
7.3	Efectos de la declaración de un bien como familiar	106
7.4	Desafectación del bien familiar	108
8.	Filiación	109
8.1	Aspectos generales	109
8.2	Clases de filiación	109
8.3	Determinación de la filiación	110
8.3.1	Determinación de la maternidad	110
8.3.2	Determinación de la filiación matrimonial	111
8.3.3	Determinación de la filiación no matrimonial	111
8.4	Reconocimiento voluntario	112
8.4.1	Reconocimiento expreso	113
8.4.2	Reconocimiento tácito o presunto	114
8.5	Repudiación del reconocimiento	114
9.	Acciones de filiación	117
9.1	Aspectos generales	117
9.2	Acciones de reclamación de filiación	117
9.2.1	Características de la acción de reclamación	118
9.2.2	Prueba en los juicios de reclamación de filiación	119
9.2.3	Otros aspectos relevantes	120
9.3	Acciones de impugnación de filiación	120
9.3.1	Impugnación de la paternidad de filiación matrimonial	121
9.3.2	Impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento	122
9.3.3	Impugnación de la maternidad	122
10.	Efectos de la filiación	124
10.1	Autoridad paterna	124
10.2	Patria potestad	129
10.3	Atributos de la patria potestad	130

10.3.1 Derecho legal de goce o usufructo legal	130
10.3.2 Administración de los bienes del hijo	131
10.3.3 Representación legal del hijo	132
10.4 Suspensión de la patria potestad	133
10.5 Emancipación	134
11. Derecho de alimentos	136
12. Tutelas y curatelas	143
13. Acuerdo de unión civil	148
14. Anexos	154

DERECHO DE FAMILIA

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.

1.1 CONCEPTO DE FAMILIA.

La familia es un conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio, acuerdo de unión civil, o parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún efecto jurídico.

1. Definición legal

Hasta hace poco tiempo, no existía en nuestra legislación una definición de familia. Solo existía la definición del art. 815 CC, para fines muy limitados (el alcance del derecho real de uso y habitación)

Art. 815 CC: "El uso y la habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o habitador. En las necesidades personales del usuario o habitador se comprenden las de su familia. La familia comprende al cónyuge y los hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución. Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de éstos; y a las personas a quienes éstos deben alimentos".

Dicha situación cambió el año 2019, con la modificación que la ley 21.150 introdujo en la ley 20.530, que regula el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El artículo 2 nº1 otorga la siguiente definición:

Familia: Núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos.

La definición citada da cuenta de un proceso de evolución en la comprensión del derecho de familia, que va en la línea de superar los aspectos más rígidos de las comprensiones religiosas del derecho de familia, y que fueron muy determinantes en la dictación de las primeras regulaciones legales de la familia. Hoy por hoy se impone un nuevo paradigma, según el cual no existe un solo modelo o tipo de familia que el derecho deba amparar. Por el contrario, el derecho se manifiesta cada vez más abierto a acoger y proteger los distintos tipos de familia posibles. Así, la doctrina más moderna prefiere hablar del "Derecho de las familias" por sobre "derecho de familia".

2. Concepto constitucional de familia

Art. 1º inc. 2º CPR. "La familia es el núcleo fundamental de la sociedad."

Se ha discutido el alcance de esta afirmación:

Comprende tanto a la familia matrimonial como a la no matrimonial (Figueroa, Peña):

- 1) Los tratados internacionales sobre derechos humanos establecen la igualdad de todos los hijos. La ley también (Art. 33 CC).
- 2) El Art. 1º LMC establece que el matrimonio es la base principal de la familia.

Sólo se refiere a la familia basada en el matrimonio (Corral, Rosende):

- 1) La CPR no lo precisó porque es algo obvio.
- 2) Eso explica el silencio de la Comisión Constituyente.
- 3) Los textos internacionales no hablan de la familia como una realidad abierta y descriptiva.
- 4) Es absurdo pensar que el Estado deba propender al fortalecimiento de las uniones de hecho.

En sede internacional, la Corte IDH ha sostenido en la Opinión Consultiva 21/2014 que no existe un único modelo de familia, por lo que la "definición de familia no debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes, como los tíos, primos y abuelos (...) Más aún, en el contexto migratorio, los 'lazos familiares' pueden haberse constituido entre personas que no necesariamente sean jurídicamente parientes (...) Es por ello que el Estado tiene la obligación de determinar en cada caso la constitución del núcleo familiar de la niña o del niño".

1.2 DERECHO DE FAMILIA.

Derechos de familia (sentido subjetivo): facultades o poderes que nacen de aquellas relaciones que, dentro del grupo familiar, mantiene cada uno de los miembros con los demás para el cumplimiento de los fines superiores de la entidad familiar.

Derecho de Familia (sentido objetivo): conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia entre sí y respecto de terceros.

1. Naturaleza jurídica del derecho de familia

Para Ramón Meza Barros, el derecho de familia ofrece características que lo destacan dentro del derecho privado, esto adoptando "*como criterio distintivo la condición de los sujetos de la relación jurídica*".

2. Paralelo entre el derecho patrimonial y el derecho de familia

Muchos Códigos Civiles han realizado una división tajante entre el derecho de familia y el derecho civil patrimonial¹. Para Gonzalo Figueroa no es bueno separarlos, debiendo recibir tramitación conjunta, siendo útil, en todo caso, ver las características de uno y otro para comprender sus diferencias.

	DERECHO PATRIMONIAL	DERECHO DE FAMILIA
PRINCIPIO QUE LO RIGE	Rige plenamente la autonomía de la voluntad.	Es un derecho de orden público, aunque sea derecho privado y haya nacido de la voluntad de los individuos. En consecuencia, sus normas son irrenunciables.
NATURALEZA JURÍDICA DE SUS NORMAS	Normas permisivas que suponen la igualdad entre las partes.	Normas dispositivas que generan relaciones de dependencia y subordinación.
MODALIDADES	Acepta modalidades (condición, plazo, modo).	No acepta modalidades: no se pueden establecer plazos ni tampoco estipular condiciones.
ACTOS FORMAS O NO PARTE DEL COMERCIO JURÍDICO	Los actos forman parte del comercio jurídico.	Está normalmente fuera del comercio jurídico. Son derechos inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.
POSIBILIDAD DE RESCILIAR	Hay resciliación.	Las cosas no pueden deshacerse como se hicieron.
ACTOS CONSENSUALES O SOLEMNES	Por regla general los actos son consensuales	Lo normal pasa a ser la solemnidad
SANCIONES	Opera la nulidad como la conocemos	Se establecen sanciones especiales como consecuencia de la nulidad. Por ejemplo, no hay un efecto plenamente retroactivo, como sucede con el matrimonio putativo

3. Características del derecho de familia.

- 1) Contenido eminentemente ético. Por ello encontramos preceptos sin sanción o con sanción atenuada, obligaciones incoercibles.
- 2) Disciplina de condiciones personales o estados que son inherentes a la persona y se imponen como derechos absolutos, respecto de todos. De estos estados pueden surgir relaciones patrimoniales, pero son inseparables de ellos.

¹ En países como Bolivia, incluso, se ha llegado más allá, pues derecho de familia tiene dedicado un Código exclusivo.

- 3) Claro predominio del interés social sobre el individual. Consecuencias:
1. Las normas reguladoras del Derecho de Familia son de orden público (imperativas, inderogables).
 2. El principio de la autonomía de la voluntad no juega un rol tan preponderante en el Derecho de Familia.
 3. Existen relaciones de superioridad y recíprocamente dependencia: derechos
 4. Los demás derechos familiares son recíprocos.
 5. Las relaciones de estado familiar son, en buena medida, derechos y deberes.
 6. Los derechos de familia son en sí y por regla general, inalienables, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles.
 7. Los actos de Derecho de Familia no están sujetos a modalidades.
 8. La mayor parte de estos actos son solemnes.

1.3 PRINCIPIOS DEL DERECHO DE FAMILIA.

Dada la importancia social y la complejidad cultural del objeto de la regulación del derecho de familia, la normativa legal sobre esta materia ha sido, históricamente, muy permeable por las ideas y valores preponderantes en una época determinada. Por la misma razón, el derecho de familia es muy susceptible de cambios, en razón de la evolución y cambios culturales que puedan darse en un país determinado.

En el caso de Chile, podemos distinguir claramente los principios que informaban el derecho de familia en la época de dictación del Código Civil, y los principios modernos del derecho de familia.

En términos generales, podemos decir que los principios que informaban el derecho de familia a la época de dictación del Código Civil estaban muy marcados por determinadas concepciones religiosas, que consagraban exclusivamente a la familia matrimonial, además determinaban una diferenciación de roles por género, discriminando a la mujer en relación con el marido, y no tenían una mayor consideración por las infancias, más allá de los aspectos patrimoniales.

Por su parte, los modernos principios del derecho de familia, tienden a una consagración progresiva del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, a la protección de la posición jurídica de niños y niñas, y apuntan al reconocimiento de la diversidad de modelos de familia posibles.

1.3.1 PRINCIPIOS QUE INFORMABAN EL DERECHO DE FAMILIA A LA ÉPOCA DE DICTACION DEL CC.

1. Matrimonio religioso e indisoluble: así era en la época de la dictación del CC.
 - Con la Ley de Matrimonio Civil de 1884 se produce la secularización del matrimonio.
 - El último hito en la materia está en la LMC, que permite celebrar el

matrimonio ante entidades religiosas, y también permite el divorcio.

2. Incapacidad relativa de la mujer casada: se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley 18.802.

3. Administración unitaria y concentrada del marido de la sociedad conyugal: actualmente se mantiene, pero atenuado por varias leyes relativas a:

- el patrimonio reservado de la mujer casada y
- a las limitaciones a las facultades con que el marido administra los bienes sociales.

4. Patria potestad exclusiva y con poderes absolutos del padre de familia: a partir de la Ley 19.585, la patria potestad corresponde al padre, la madre o ambos conjuntamente.

5. Filiación matrimonial fuertemente favorecida: en un principio no se permitía la investigación de la filiación no matrimonial, y los hijos legítimos excluían a los naturales en el primer orden de sucesión abintestato. La Ley 19.585 termina con toda discriminación entre los hijos. Todos ellos, provengan de filiación matrimonial o no matrimonial, gozan de los mismos derechos.

1.3.2 MODERNOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DE FAMILIA.

1. Principio de igualdad:

1.1. Principio de igualdad entre los hijos: Nuestra legislación ha sido objeto de una serie de reformas que han buscado eliminar las discriminaciones que contenía el CC en materia de filiación. La más importante, en el año 1998², eliminó la distinción entre filiación legítima e ilegítima, discriminación que tenía importantes consecuencias sobre todo en materia de alimentos y derechos sucesorios. Actualmente artículo 33 del Código Civil señala expresamente que "*la ley considera iguales a todos los hijos*". Se eliminó además la prohibición de investigar la filiación, consagrándose acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la identidad³. Por último, el año 1999 se puso fin a la distinción entre hijos biológicos y adoptivos, actualmente la ley dispone que la adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo⁴.

² Ley N° 19.585 de 1998

³ **Derecho a la identidad:** Consagrado en la Convención de los Derechos del Niño (artículos 7 y 8) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 18) y en el artículo 26 de la Ley N° 21.430. Consiste en el derecho que asiste a cada persona a conocer sus orígenes, a saber quiénes son sus padres y su familia (entre otros aspectos). Manifestaciones del derecho: 1. El principio de la libre investigación de la paternidad y maternidad (Art. 195), 2. La libertad probatoria en materia de filiación (Art. 198), 3. Las facultades de los jueces de decretar de oficio las pruebas que estime conveniente para determinar la filiación (Art. 198), 4. La sanción al padre o madre ante la negativa injustificada de realizarse la prueba pericial biológica. (Art. 199 inc. 1), 5. El carácter imprescriptible e irrenunciable de la acción de reclamación de la filiación (Art. 195 inc. 2), 6. No opera la cosa juzgada contra quien se presente como verdadero padre o madre, o como verdadero hijo (art. 320).

⁴ Ley N° 19.620 de 1999

⁵ Ley N° 20.680 de 2013

1.2. Principio de igualdad entre padres: Respecto de los derechos y obligaciones derivados de las relaciones paterno-filiales, la tendencia legislativa también apunta a establecer un régimen más igualitario entre padre y madre. En primer lugar, en relación a la llamada autoridad paterna, luego de la reforma del año 1998 el CC establece que los hijos le deben respeto y obediencia a ambos padres, sin distinción alguna (el antiguo artículo 219, consignaba que los hijos “estarán especialmente sometidos al padre”). En cuanto al cuidado personal, con la reforma del año 2013⁵ se eliminó la regla que disponía que si los padres vivían separados el cuidado personal le correspondía a la madre y la patria potestad al padre. Actualmente el CC dispone que si los padres viven juntos, el cuidado personal le corresponde de consuno a ambos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. Si los padres están separados, y a falta de acuerdo, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo. En cuanto a la patria potestad, que a la época de dictación del CC sólo podría corresponder al padre, actualmente podrá ser ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente, según lo que ellos acuerden, y si los padres viven separados, será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo. Por último, en materia de derechos sucesorios y de alimentos, nuestra legislación actual no contempla diferencias respecto los derechos deberes que le corresponden a padre y madre.

1.3. Principio de igualdad entre cónyuges: Nuestra legislación ha sido objeto de una serie de reformas con el objeto de establecer un régimen más igualitario entre cónyuges. En consideración a los principios e ideas que respecto a la familia imperaban a la época de dictación del CC, en general estas modificaciones han buscado mejorar la situación en la que se encuentra la mujer respecto el marido.

En cuanto a los efectos personales del matrimonio, se han ido suprimido las diferencias que existían respecto los derechos y deberes recíprocos entre los cónyuges que discriminaban a la mujer (por ejemplo, se modificó el deber de fidelidad, eliminando la distinción del adulterio cometido por el marido o mujer, y se suprimió la facultad del marido para impedir que la mujer ejerciere una profesión u oficio).

En cuanto a los efectos patrimoniales, la legislación actual permite que ambos cónyuges demanden alimentos y compensación económica al otro, en la medida que se cumplan los requisitos. En cuanto al régimen de bienes, a la época de dictación del CC sólo se contemplaba el régimen de sociedad conyugal. Luego, el año 1934, se consagró la posibilidad de pactar en las capitulaciones matrimoniales el régimen de separación de bienes, y con posterioridad, el año 1994, se agregó el régimen de participación en los gananciales, de modo que actualmente los cónyuges tienen libre elección para escoger alguno de estos tres y no regirse necesariamente por las reglas de la sociedad conyugal, régimen que se ha criticado por aún mantener normas que atentan contra la igualdad entre cónyuges. Así, se ha señalado que es un régimen que discrimina a la mujer al establecer que el marido es el jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer, norma de orden público que no puede ser alterada por las partes. Por otra parte también se ha señalado que las normas de este régimen discriminaría al marido, que a diferencia de la mujer, no puede tener un patrimonio

reservado como el del artículo 150 CC. Así, se ha señalado que la mujer quedaría en una situación privilegiada ya que podría aceptar los gananciales y gozar de los beneficios de una buena administración del marido o, en caso de una administración del marido poco exitosa puede precaverse de sus perjuicios y renunciar a los gananciales, manteniendo sus bienes reservados. No obstante las críticas que aún existen a este régimen, diversas reformas⁶ han intentado mejorar la situación de la mujer, así por ejemplo su incapacidad relativa cesó el año 1989, y se han atenuado las facultades de administración del marido al establecer la necesidad de obtener la autorización de la mujer para la celebración de los actos más importantes de disposición de los bienes.

1.4. Principio de Igualdad y AUC: La incorporación del AUC a nuestro ordenamiento tuvo por objeto regular y dar certeza jurídica a los derechos y obligaciones personales y patrimoniales que emanan de las uniones de hecho. Principalmente se buscó eliminar, o al menos aminorar, la discriminación que existía respecto las parejas homosexuales, que, al no poder contraer matrimonio, quedaban en una situación de desprotección jurídica. Como emana del mismo mensaje del ejecutivo, el AUC busca proteger los derechos de las parejas que conviven sin estar casadas para que estas pudiesen tener acceso a derechos de salud, previsión, de herencia, y a otros beneficios que las parejas casadas si gozan. Si bien la regulación del AUC se ha considerado como un importante avance en pos del principio de igualdad, se ha señalado que éste constituye sólo un primer paso para llegar a un estatuto que regule de forma real y completamente igualitaria los efectos derivados de la convivencia de parejas heterosexuales y homosexuales.

2. Principio del interés superior del hijo⁷

El artículo 3 de la Convención de Derecho de Niño consagra el principio del interés superior del niño, señalando que *"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"*.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone en su artículo 19 que *"Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado"*. La Corte IDH en el Caso Niños de la Calle vs. Guatemala ha entendido que las medidas de protección a las que alude dicha norma incluyen "la no discriminación, a la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación", entre otras. Asimismo, en la Opinión Consultiva 21/2014, lo ha vinculado con el principio de autonomía progresiva, sosteniendo que "las niñas y niños ejercen por sí mismos sus derechos de manera progresiva, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal", siendo este el fundamento de las medidas diferenciadas de protección que a su respecto deben tomarse, consagrando "un trato preferente a las niñas o niños en razón precisamente de su peculiar vulnerabilidad y, de esa forma, procuran proporcionarles el instrumento adecuado para que se logre la efectiva igualdad ante la ley de que gozan los adultos por su condición de tales".

⁶ Ley 18.802 de 1989, DL 328 de 1928, Ley 5.521 de 1934, Ley 10.271 de 1952

A nivel nacional, luego de las modificaciones introducidas por la ley 19.585, el código civil consagra al comienzo del título IX (De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos) el principio del interés superior del hijo. El artículo 222 dispone que *“La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades”*.

Por su parte, el artículo 16 de la Ley N°19.968 que crea los Tribunales de Familia, contempla una consagración del interés superior del niño, niña o adolescente y el derecho de estos a ser oído, estableciendo como objetivo garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y goce pleno y efectivo de sus derechos y garantías, y disponiendo que el juez de familia debe tenerlo siempre como consideración principal en la resolución del asunto.

El artículo 7 de la Ley N°21.430 establece que el interés superior del niño, niña o adolescente es un derecho, principio y una norma de procedimiento, que se basa en una evaluación de todos los intereses de uno o más niños en una situación concreta. De ese modo, cuando deba tomarse una decisión sobre cuestiones que le afecten deberá considerarse primordialmente su interés superior, entendido este como la máxima satisfacción posible de principios, derechos y garantías. En consecuencia, ante pluralidad de interpretaciones, se deberá elegir aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño, niña o adolescente.

Este principio busca que la protección y satisfacción de los derechos fundamentales del hijo sean el criterio que oriente toda decisión que se tome a su respecto, con preeminencia sobre otros intereses con los que pueda colisionar. Se ha señalado que este concepto de interés superior del hijo es flexible y adaptable; debe ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales.

Para determinar el interés superior del niño se deben evaluar las circunstancias concretas y específicas de cada niño, analizando los comportamientos de los adultos que están a su cargo y el impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño, debiendo tomar en cuenta daños o riesgos reales y probados y no especulativos, excluyendo, de ese modo, toda argumentación basada en estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia (según el razonamiento ofrecido por la Corte IDH en el Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile). Por su parte, la Ley N°21.430 establece una serie de criterios que deberán tomarse en cuenta para determinar cuál es el interés superior:

Para su determinación, se deberán considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente o grupo de niños, niñas o adolescentes como:

- a) Los derechos actuales o futuros del niño, niña o adolescente que deban ser respetados, promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad.
- b) La opinión que el niño, niña o adolescente exprese, cuando ello sea posible conforme a su edad, grado de desarrollo, madurez y/o su estado afectivo si no pudiere o no quisiere manifestarla.
- c) La opinión de los padres y/o madres, representantes legales o de quien lo tuviere legalmente a su cuidado, salvo que sea improcedente.
- d) El bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social del niño, niña o adolescente.
- e) La identidad del niño, niña o adolescente y las necesidades que de ella se derivan, sean éstas físicas, emocionales, sociales, culturales o de origen étnico
- f) La autonomía del niño, niña o adolescente y su grado de desarrollo.
- g) Cualquier situación de especial desventaja en la que se encuentre el niño, niña o adolescente que haga necesaria una protección reforzada para el goce y ejercicio efectivos de sus derechos.
- h) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del niño, niña o adolescente considerando su entorno de vida.
- i) Otras circunstancias que resulten pertinentes en el caso concreto que se conoce, tales como los efectos probables que la decisión pueda causar en su desarrollo futuro.

En nuestro Código Civil, el principio se encuentra inmerso en diversas disposiciones como los artículos 222 inciso 1º, 225, 225-2, 226, 229, 234, 240, 242, 244, 245, 268 y 272. Así, se han señalado como manifestaciones concretas del mismo:

- Garantizarle los derechos que surgen de su calidad de persona humana, los que deben ser respetados en el ejercicio de la autoridad de los padres.
- Permitirle manifestar su opinión y tomarla en cuenta de acuerdo con su edad y grado de madurez, en todas las instancias judiciales o extrajudiciales en que tenga interés el niño, como en los acuerdos regulatorios en caso de separación o divorcio de los padres.
- Permitirle permanecer con el padre que mejor asegure su bienestar físico y espiritual y, al mismo tiempo, facilitar su vinculación con el otro padre, en caso de separación, nulidad o divorcio
- Permitirle la libre investigación de su filiación, protegiendo su derecho esencial a tener un nombre y conocer a sus padres
- Preferir, en caso de conflicto, la prueba de la posesión notoria antes que la pericial, en el entendido que los lazos afectivos y psicológicos de paternidad, se crean con más fortaleza en la vida diaria que en razón de la sola herencia, desprovista de toda otra relación filial. Esta regla tiene como excepción que, por graves razones, sea más conveniente preferir la prueba pericial, lo que nuevamente da cuenta que atrás de esta regla subyace el principio de interés superior del niño.

Otro principio fundamental del derecho de la infancia, es el principio de autonomía progresiva, consagrado en el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño y en el artículo 11 de la Ley N°21.430. Esta última disposición señala que todo niño, niña o adolescente “podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, salvo que la ley limite este ejercicio, tratándose de derechos fundamentales”. Asimismo, establece que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protagonistas activos de sus vidas, y para ello requieren experimentar el balance permanente entre la

autonomía para el ejercicio de sus derechos y la necesidad simultánea de recibir protección". Desde que el niño es considerado como un sujeto de derecho, se le reconoce no solo la titularidad de derechos, sino, también, su capacidad para ejercerlos por sí mismo. Ahora, considerando que los niños se encuentran en situación fáctica especial, son "personas en desarrollo", el ejercicio de estos derechos será progresivo, atendiendo a la evolución de sus facultades. Como manifestaciones en el CC, se ha reconocido el derecho del hijo a participar en las decisiones en asuntos que afecten su interés (como en materia de cuidado personal y relación directa y regular), y las normas relativas al peculio profesional.

3. Principio de protección del cónyuge más débil

El principio de protección del cónyuge más débil se encuentra reconocido expresamente en la LMC en el artículo 3º, que dispone "*Las materias de familia reguladas por esta ley deberán ser resueltas cuidando proteger siempre el interés superior de los hijos y del cónyuge más débil*".

La ley no describe cuando el marido o la mujer se encuentran en la situación de "cónyuge más débil", no obstante, la discusión parlamentaria de la LMC permitiría afirmar que se buscó proteger a aquel cónyuge que, con ocasión de la ruptura matrimonial, se encontrara en una posición de desmedro económico frente al otro. Así, en general la doctrina ha entendido que la noción de cónyuge más débil tiene un carácter económico, no obstante existen autores que han sostenido una interpretación más amplia, entendiendo que comprende además de aspectos económicos, aspectos psíquicos, emocionales o fisiológicos.

En virtud de este principio, el legislador busca otorgar una protección especial al "*cónyuge más débil*", lo que se puede traducir en que se grave al otro cónyuge -al "más fuerte"- con ciertas limitaciones o restricciones (como por ejemplo, limitando su facultad de disposición respecto de sus bienes declarados familiares) o imponiéndole el deber de cumplir con ciertas prestaciones a favor del cónyuge más débil (como por ejemplo, en el caso del pago de alimentos o del pago de compensación económica). Algunas manifestaciones del principio:

- Compensación económica
- Derecho de alimentos entre cónyuges
- Bienes familiares
- Crédito de participación en los gananciales
- "Cláusula de dureza", que permite al juerechazar el divorcio solicitado unilateralmente cuando exista incumplimiento injustificado y reiterado de la obligación de alimentos respecto del cónyuge demandado y de los hijos comunes.
- Control que realiza el juez al aprobar un acuerdo en sede de separación o divorcio, calificándolo de completo y suficiente. Según el artículo 55 inciso 2º de la NLMC, se entenderá que el acuerdo es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos,

procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita.

1.4. PARENTESCO.

Parentesco: relación de familia que existe entre dos personas. Puede ser de dos clases:

a) Por consanguinidad: Art. 28 CC. "Parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados."

b) Por afinidad: Art. 31 inc. 1º CC. "Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge." Se debe tener en cuenta que:

- 1) Los cónyuges no son parientes entre sí.
- 2) El parentesco por afinidad subsiste aún después de la muerte de uno de los cónyuges.

El art. 4 de la ley 20.830, que establece el acuerdo de unión civil señala que entre un conviviente civil y los consanguíneos de la persona con la que está unida por un acuerdo de unión civil, existirá mientras éste se encuentre vigente, parentesco por afinidad. La línea y grado de afinidad se califica por la línea o grado de consanguinidad del conviviente civil.

De esta manera podemos señalar que el actual concepto legal parece incompleto, toda vez que, con la entrada en vigencia de la ley que crea el acuerdo de unión civil, se extiende también el parentesco por afinidad, asimismo, entre un conviviente civil y los parientes consanguíneos del otro. Sin embargo, no bastaría agregar al concepto legal la frase "o conviviente civil" (como en otros aspectos), porque el parentesco por afinidad emanado del matrimonio perdura una vez que éste ha terminado, no como ocurre con el parentesco por afinidad emanado del acuerdo de unión civil.

Línea: serie de parientes que descienden unos de otros (línea recta) o de un tronco común (línea colateral) (Art. 27 inc. 2º CC).

- Línea recta: Abuelo, padre, hijo.
- Línea colateral: Hermanos, primos hermanos, tío. Grado: distancia que existe entre dos parientes.

En el parentesco en línea recta se cuenta por el número de generaciones.

- Ej. Padre e hijo: 1º grado.
 Nieta y abuelo: 2º grado.

En el parentesco colateral, se sube hasta el tronco común, y se baja al pariente cuyo grado se quiere conocer (Art. 27 inc. 1º CC).

Ej: Los hermanos, se encuentran en segundo grado en la línea colateral, porque

en el primer grado se sube de uno de los hijos al padre y después se baja del padre al otro hijo. Por esto, el grado más cercano de parentesco entre dos colaterales es el segundo grado (hermanos), no hay parientes colaterales en primer grado.

La línea y el grado en el parentesco por afinidad se califican por la línea y grado del cónyuge con su respectivo consanguíneo (Art. 31 inc. 2º CC).

CAPÍTULO 2. LOS ESPONSALES.

1. Concepto.

Los esponsales o desposorios son la promesa de matrimonio mutuamente aceptada⁸.

Art. 98 del CC: "Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada, es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y que no produce obligación alguna ante la ley civil. No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para demandar indemnización de perjuicios".

2. Efectos del contrato de esponsales.

La norma sobre los esponsales se entiende bajo la idea de que el legislador prefiere las parejas casadas por sobre el desposorio, esto por motivos de seguridad jurídica. El Código señala que es un hecho privado, es decir, un contrato, que no produce obligación alguna. En consecuencia, no hay acción para exigir el cumplimiento, ni para la indemnización de perjuicios, ni para exigir el pago de una multa eventualmente pactada. Sólo se puede demandar la restitución de las cosas donadas bajo la condición de que se celebrara el matrimonio (regalos).

Art. 100 del CC: "Lo dicho no se opone a que se demande la restitución de las cosas donadas y entregadas bajo la condición de un matrimonio que no se ha efectuado".

Además, el Código señala que en el caso de haberse establecido una multa si el matrimonio no llegaba a celebrarse, esta no vale, pero si se paga, se podrá retener lo pagado.

"Si uno de los que prometió el matrimonio futuro, y no cumplió la promesa pagare, voluntariamente la multa que se hubiera acordado, tal pago es válido, y por ende, cuenta quien recibió dicho pago con una excepción para retener lo pagado".

- Con ello se establece, según Gonzalo Figueroa, una **obligación natural** respecto de la multa ya que no existe acción alguna para cobrarla, pero si se paga se tiene derecho a retener lo obtenido.
- Para otros autores, **estamos simplemente frente a una sanción**, entre ellos Abeliuk, quien sostiene que "la verdad es que el pago de la multa en los esponsales no puede ser obligación natural en la concepción de ésta como obligación civil imperfecta o desvirtuada que adopta nuestro Código, puesto que precisamente el Art.98 ha declarado que ellos no producen obligación alguna, expresión que, por lo demás, incluye tanto a las civiles como a las naturales".

⁸ Cabe mencionar que esto no es dable tratándose del acuerdo de unión civil, ya que el art. 3 de la ley 20.830 señala que el acuerdo de unión civil no puede prometerse. Ver capítulo 13.

- Barrientos está con estos autores “no sólo por razones históricas, sino también porque la disciplina de las obligaciones naturales no queda estrechada solamente en la imposibilidad de accionar y en el nacimiento de una excepción para retener lo pagado voluntariamente, sino por una serie de otros aspectos, que presuponen la existencia de un débito”.
- La multa en los esponsales es problemática toda vez que admite la existencia (con un valor reducido) de una cláusula penal, frente a una obligación principal inexigible que no produce efecto civil alguno.

Art. 99 del CC: “Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido. Pero si se hubiere pagado, no podrá pedirse su devolución”.

CAPÍTULO 3. EL MATRIMONIO

3.1. DEFINICIÓN.

Art. 102 CC. "El *matrimonio* es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente."⁹

Elementos:

1. El matrimonio es un contrato: Sin perjuicio de la definición legal, existen diversas teorías para explicar la naturaleza jurídica del matrimonio:

- 1) Es un contrato, pues el acuerdo de voluntades crea la relación jurídica, aunque es un contrato sui generis.
 - *Crítica:* las normas que limitan la autonomía de la voluntad demuestran la diferencia entre el contrato y el matrimonio. Esta tesis no explica algunas características propias del matrimonio, como su perpetuidad e indisolubilidad.
- 2) Es un acto del Estado, que a través del oficial civil une a las partes en matrimonio.
 - La voluntad de las partes sólo es un presupuesto necesario.
 - En nuestra legislación se aprecia que la función del oficial del Registro Civil es mucho mayor a la de un simple ministro de fe: es él quien los une.
- 3) Es una institución,
 - El acuerdo de voluntades es sólo el acto de fundación que le da origen.
 - Una vez constituida, cobra existencia propia y su estatuto, fijado por la ley civil, no puede ser alterado por la voluntad de los fundadores.

Ramos Pazos cree que es un acto de Estado, lo que no contradice la idea del matrimonio como institución.

2. Es un contrato solemne (La solemnidad de existencia es la presencia de un Oficial Civil, y la solemnidad de validez, la presencia de 2 testigos hábiles).

3. Que celebran dos personas: en virtud de la ley 21.400, ya no es de la esencia del matrimonio la diferencia de sexo.

4. Por el cual se unen actual e indisolublemente y por toda la vida:

- La palabra "actual" descarta las modalidades suspensivas;
- Las expresiones "indisolublemente" y "por toda la vida" no corresponden a la realidad actual del matrimonio.

⁹ Es importante tener presente que esta definición fue modificada por la ley 21.400 que consagra el matrimonio igualitario, dejando sin efecto el requisito fundamental de que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer.

5. Con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente: esto es importante, pues la finalidad no es sólo procrear.

3.2. REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL MATRIMONIO.

Requisitos de existencia son aquellos sin los cuales el matrimonio no existe¹⁰.

- Para Gonzalo Figueroa, la inexistencia, como sanción a los actos jurídicos, se aplica respecto de “los requisitos que son necesarios para que un acto jurídico pueda ser considerado como tal; es decir, que haya nacido a la vida jurídica, y produzca los efectos de tal. Faltando alguno de ellos, no puede hablarse de un acto jurídico, sino que de una apariencia de acto, que carece en absoluto de eficacia, y que no puede producir efecto alguno”.
- Ramos agrega que “distinguir la inexistencia de la nulidad de un matrimonio es importante, porque si el matrimonio es nulo, puede ser putativo y producir los mismo efectos civiles que el válido (...)”
- Nuestra Corte Suprema ha hecho la distinción entre matrimonio nulo e inexistente, afirmando que el primero tiene una existencia imperfecta, por cuanto adolece de vicios en su constitución que pueden traer consigo la nulidad; en cambio el inexistente es sólo una apariencia de matrimonio, porque carece de los elementos sin los cuales no puede concebirse el acto”.

Son requisitos de existencia del matrimonio:

1. Ya no se exige diversidad de sexo entre los contrayentes, en virtud de la ley 21.400, que establece el matrimonio igualitario.

Art. 102 del CC.: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual ~~un hombre y una mujer~~ dos personas se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.

Art. 80 de la LMC: “Los requisitos de forma y fondo del matrimonio serán los que establezca la ley del lugar de su celebración. Así, el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad con las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno, ~~siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer~~”.

2. Consentimiento¹¹: Esto implica que el matrimonio simulado es inexistente por falta de voluntad. Para Barrientos se trata de “un consentimiento de carácter ‘matrimonial’, es decir, dirigido a la formación del matrimonio y no a otro acto o negocio jurídico, pues precisamente está definido por esa voluntad concordante

¹⁰ Es respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo que Zachariae y Aubry et Rau proponen la teoría de la existencia como alternativa a la nulidad

¹¹ Hablamos de consentimiento puro y simple, y no de vicios, los cuales se analizan en el tópico de los requisitos de validez

de 'recibirse el uno al otro como marido y mujer' y, en cuanto tal, implica el ejercicio de ius conubii por parte de ambos contrayentes".

3. Presencia del oficial del registro civil antiguamente debía ser de la comuna de los contrayentes, hoy puede ser cualquier de ellos. Puede estar presente al momento de celebrarse el matrimonio, o ratificándolo dentro de los 8 días posteriores a la celebración de un matrimonio eclesiástico.

Art. 17 inciso primero de la L.M.C.: "El matrimonio se celebrará ante el oficial del Registro Civil que intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información. (...)".

Art. 20 incisos primero y segundo de la L.M.C.: Los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este Capítulo, desde su inscripción ante un Oficial del Registro Civil.

El acta que otorgue la entidad religiosa en que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como el nombre y la edad de los contrayentes y los testigos, la fecha de su celebración, deberá ser presentada por aquellos, o por un mandatario especialmente facultado para este efecto por los contrayentes, ante cualquier Oficial del Registro Civil, dentro de quince días, para su inscripción. Si el último día del plazo fijado en este inciso recae en día sábado, feriado o inhábil, éste pasará al día hábil inmediatamente siguiente. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión u oficio y domicilio de los contrayentes y del mandatario.

4. Se permite el matrimonio por poder.

Art. 103 CC. "El matrimonio podrá celebrarse por mandatario especialmente facultado para este efecto. **El mandato deberá otorgarse por escritura pública**, e indicar el nombre, apellido, profesión y domicilio de los contrayentes y del mandatario."

En consecuencia, el mandato debe ser especial, solemne y determinado.

3.3. REQUISITOS DE VALIDEZ DEL MATRIMONIO.

1. Consentimiento libre y espontaneo.
2. Capacidad de los contrayentes y ausencia de impedimentos dirimentes.
3. Formalidades legales del matrimonio.

3.3.1. CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESPONTÁNEO

Art. 8º LMC. "Falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes casos:"

1) ERROR:

*"1º Si ha habido error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente;
2. º Si ha habido error acerca de alguna de sus cualidades personales que, atendida la naturaleza o los fines del matrimonio, ha de ser estimada como determinante para otorgar el consentimiento, y"*

- El error en la persona: deriva de una institución del derecho civil común: el matrimonio es un contrato intuitu personae. En realidad, sólo

podría suceder en el matrimonio celebrado con un mandatario o por poder, pero no hay jurisprudencia que dé cuenta de este tipo de error.

Error acerca de sus cualidades personales: para Corral abarca la impotencia coeundi. Para Gonzalo Figueroa, al igual que Barrientos, son también determinantes otros temas como la homosexualidad o religión de la pareja. Con ello se puede asegurar que error en la cualidad personal puede recaer sobre asuntos de la más distinta naturaleza, lo esencial es que esa cualidad haya sido determinante para prestar el consentimiento y debe referirse a los fines del matrimonio. "El carácter determinante de la cualidad personal para prestar el consentimiento matrimonial, para los efectos de elevar un error acerca de ella, a la categoría de un elemento que obsta a la libertad y espontaneidad del consentimiento matrimonial, debe referirse necesariamente a la naturaleza o fines del matrimonio". No puede ser un error sobre el régimen patrimonial pues este implica tácticamente que el matrimonio ya fue válidamente celebrado.

2) FUERZA:

"3° Si ha habido fuerza, en los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil, ocasionada por una persona o por una circunstancia externa, que hubiere sido determinante para contraer el vínculo."

De esta manera, si bien la norma realiza una remisión expresa a las reglas del Código Civil, también se establece una importante particularidad para la fuerza matrimonial, la cual consiste en la posibilidad de que sea una *circunstancia externa* la que produzca la fuerza que se invoca como vicio del consentimiento.

3) NO SE COMPRENDE EL DOLO porque si se estableciera el dolo como vicio del consentimiento se pondría en peligro la estabilidad del vínculo matrimonial, puesto que es normal que en las relaciones previas al matrimonio, las partes muestren su mejor faceta.

3.3.2. CAPACIDAD DE LOS CONTRAYENTES Y AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS DIRIMENTES:

- Al igual que las normas del Código Civil, la capacidad es la regla general, siendo la incapacidad la excepción. Por ello, la ley no declara quiénes son capaces, sino quiénes no podrán contraer matrimonio. Con esto, quien reclama la incapacidad deberá probarla.
- No obstante esta similitud, en el matrimonio no se aplican las reglas de capacidad del Código Civil. Ramos Pazos afirma que "en lo concerniente al matrimonio, las incapacidades se llaman impedimentos (...) los impedimentos en nuestra legislación pueden ser de dos clases:
 - **Dirimentes:** que son los que obstan a la celebración del matrimonio, de tal suerte que si no se respetan, la sanción es la nulidad del vínculo matrimonial;
 - **Impedientes:** que nuestro Código Civil llama prohibiciones, cuyo incumplimiento no produce nulidad, sino otro tipo de sanciones.

1) Impedimentos dirimentes: obstan a la celebración del matrimonio, su omisión acarrea la nulidad del matrimonio. Pueden ser absolutos o relativos

i) Absolutos: obstan al matrimonio con cualquier persona. Art. 5º LMC¹². "No podrán contraer matrimonio:"

1. Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto
 - Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto La sanción civil es la nulidad; penalmente tipifica el delito de bigamia (Art. 382 CP).
 - Si el primer matrimonio fue anulado, esa nulidad produce efecto cuando la sentencia está ejecutoriada.
 - Si el nuevo matrimonio se celebra antes de eso, se incurre en el vicio, pero si la sentencia queda ejecutoriada después, se valida retroactivamente, siempre que el primer matrimonio no haya sido putativo.
2. Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil;
3. Los menores de dieciocho años;
4. Los que se hallaren privados del uso de razón; y los que por un trastorno o anomalía psíquica, fehacientemente diagnosticada, sean incapaces de modo absoluto para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio;
5. Los que carecieren de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio, y
6. Los que no pudieren expresar claramente su voluntad por cualquier medio, ya sea en forma oral, escrita o por medio de lenguaje de señas."

ii) Relativos: sólo impiden el matrimonio con determinadas personas.

1. Art. 6º LMC. "No podrán contraer matrimonio entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o por afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado.

Los impedimentos para contraerlo derivados de la adopción se establecen por las leyes especiales que la regulan."

¹² Este artículo fue modificado con la entrada en vigencia de la ley 20.830, que crea el acuerdo de unión que establece como numeral segundo el siguiente: "2º Los que se hallaren ligados por un acuerdo de unión civil vigente, a menos que el matrimonio lo celebre con su conviviente civil", cambiando así el número de los siguientes impedimentos dirimentes absolutos.

De acuerdo a los Arts. 27 Ley 7.613 y 18 Ley 18.703 sobre Adopción, es nulo el matrimonio entre el adoptante y el adoptado, o entre el adoptado y el viudo o viuda del adoptante.

2. Art. 7º LMC. "El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homicidio de su marido o mujer, o con quien hubiere sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ese delito."

2) Impedimentos impedientes o prohibiciones: su incumplimiento no produce nulidad, sino otras sanciones. Es importante mencionar que gran parte de los artículos que regulan los impedimentos impedientes fueron derogados por la ley 21.515, la cual, entre otros cambios, prohíbe el matrimonio de los menores de 18 años, eliminando así la necesidad de solicitar el consentimiento de los ascendientes en los matrimonios de mayores de 16. En concreto, fueron derogados los artículos 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 139 y 154, todos del Código Civil.

i) IMPEDIMENTO DE SEGUNDAS NUPCIAS.

Art. 124 CC. "El que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando y les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o con cualquiera otro título.

Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial."

Art. 127 CC. "El viudo o viuda por cuya negligencia hubiere dejado de hacerse en tiempo oportuno el inventario prevenido en el artículo 124, perderá el derecho de suceder como legitimario o como heredero abintestato al hijo cuyos bienes ha administrado."

También hay sanciones penales para el que obtiene que el oficial del Registro Civil autorice el matrimonio (Art. 384 CP) y también para el oficial que lo autorice sin respetar el impedimento (Art. 388 CP).

ii) IMPEDIMENTO ESPECIAL PARA LA VIUDA O MUJER CUYO MATRIMONIO SE HA DISUELTO O DECLARADO NULO.

Hasta la dictación de la Ley 21.264, promulgada en septiembre del 2020, la mujer cuyo matrimonio se disolvía por cualquiera de las causales que contempla la legislación no podía contraer matrimonio sino hasta después de dar a luz o, en caso de no estar embarazada, hasta 270 días después de la disolución. El fundamento de dicha prohibición era evitar eventuales confusiones en torno a la determinación de la paternidad del no nacido, y la sanción era la indemnización de los perjuicios que la incertidumbre acerca de la paternidad causare.

Los principales argumentos para la derogación de este impedimento especial fueron dos. En primer lugar, la disponibilidad de pericias biológicas elimina el eventual problema de la confusión en la determinación de la filiación. En segundo lugar, un impedimento especial para que la mujer cuyo vínculo matrimonial ha sido disuelto

pueda contraer matrimonio de inmediato se considera una discriminación inaceptable en atención al principio de igualdad entre el hombre y la mujer.

3.3.3. FORMALIDADES LEGALES DEL MATRIMONIO:

1. MATRIMONIO CELEBRADO EN CHILE:

i) Formalidades previas:

a. Manifestación (Art. 9º LMC):

Acto en que los futuros contrayentes dan a conocer al oficial del Registro Civil su intención de contraer matrimonio ante él. Puede ser por escrito, oralmente o por lenguaje de señas. Puede hacerse ante cualquier oficial.

b. Información sobre finalidades del matrimonio (Art. 10 LMC):

El oficial debe proporcionarles información suficiente acerca de las finalidades del matrimonio, de los derechos y deberes recíprocos que produce y de los distintos regímenes patrimoniales. También debe prevenirlos respecto de la necesidad de que el consentimiento sea libre y espontáneo, y comunicarles la existencia de cursos de preparación.

c. Cursos de preparación (Art. 11 LMC):

Persiguen promover la libertad y seriedad del consentimiento matrimonial, y tienen por objeto especialmente que los contrayentes conozcan los derechos y deberes que impone el vínculo. Los contrayentes pueden eximirse de ellos de común acuerdo, si declaran que conocen suficientemente esos derechos y deberes.

d. Información de testigos (Art. 14 LMC):

Comprobación, mediante dos testigos, del hecho que los futuros contrayentes no tienen impedimentos ni prohibiciones para contraer matrimonio.

❖ Situación especial de las personas pertenecientes a una etnia indígena (Art. 13 LMC): pueden solicitar que la manifestación, la información para el matrimonio y la celebración del mismo se realicen en su lengua materna. En este caso, así como en el que alguno o ambos contrayentes no conozcan el idioma castellano o sean sordomudos, las gestiones se harán por medio de un intérprete.

❖ Los matrimonios en artículo de muerte no requieren de los trámites previos (Arts. 10 y 17 inc. final CC).

ii) Formalidades coetáneas:

Art. 15 LMC. "Inmediatamente después de rendida la información y dentro de los noventa días siguientes, deberá procederse a la celebración del matrimonio. Transcurrido dicho plazo sin que el matrimonio se haya efectuado, habrá que repetir las formalidades prescritas en los artículos precedentes."

a. Celebración ante oficial del Registro Civil:

Art. 17 inc. 1º LMC. "El matrimonio se celebrará ante el Oficial del Registro Civil que intervino en la realización de las diligencias de manifestación e información." En consecuencia, todo oficial civil es competente para la celebración del matrimonio.

Lugar (Art. 17 inc. 2º LMC):

1. En el local de la oficina del oficial.
2. En el lugar que señalen los contrayentes, siempre que esté ubicado dentro de su territorio jurisdiccional.

b. Presencia de dos testigos hábiles:

Art. 17 inc. 2º LMC. "La celebración tendrá lugar ante dos testigos, parientes o extraños, ...".

Los testigos deben ser hábiles.

Art. 16 LMC. "No podrán ser testigos en las diligencias previas ni en la celebración del matrimonio:

- 1º Los menores de 18 años;
- 2º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia; 3º Los que se hallaren actualmente privados de razón;
- 4º Los que hubieren sido condenados por delito que merezca pena aflictiva y los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos, y
- 5º Los que no entendieren el idioma castellano o aquellos que estuvieren incapacitados para darse a entender claramente."

iii) Acto de celebración del matrimonio:

Art. 18 LMC. "En el día de la celebración y delante de los contrayentes y testigos, el Oficial del Registro Civil dará lectura a la información mencionada en el artículo 14 y reiterará la prevención indicada en el artículo 10, inciso segundo.

A continuación, leerá los artículos 131, 133 y 134 del Código Civil. Preguntará a los contrayentes si

consienten en recibirse el uno al otro como marido y mujer y, con la respuesta afirmativa, los declarará casados en nombre de la ley."

iv) Formalidades posteriores:

Art. 19 inc. 1º LMC. "El Oficial del Registro Civil levantará acta de todo lo obrado, la que será firmada por él, por los testigos y por los cónyuges, si supieren y pudieren hacerlo. Luego, procederá a hacer la inscripción en los libros del Registro Civil en la forma prescrita en el reglamento."

Los vicios en el acta o en la inscripción del matrimonio no producen la nulidad del mismo.

❖ En el acto del matrimonio se pueden reconocer hijos comunes no matrimoniales, y pactar separación de bienes o participación en los gananciales.

2) MATRIMONIO CELEBRADO ANTE ENTIDADES RELIGIOSAS:

Para que produzca efectos civiles debe cumplir con los siguientes requisitos (Art. 20 LMC):

- 1.** Debe celebrarse ante una entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público.
- 2.** Debe autorizarlo un ministro del culto que estatutariamente tenga facultades para ello.
- 3.** Debe levantarse un acta que acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez (nombre y edad de los contrayentes y testigos y fecha de su celebración).
- 4.** El acta debe estar suscrita por el ministro del culto ante quien se haya celebrado, y debe cumplir las exigencias del Art. 40 bis de la Ley de Registro Civil

Artículo 40 bis.- El acta a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil deberá estar suscrita por el ministro de culto ante quien hubieren contraído matrimonio religioso los requirentes, y deberá expresar la siguiente información:

- 1º La individualización de la entidad religiosa ante la que se celebró el matrimonio, con expresa mención del número del decreto en virtud de la cual goza de personalidad jurídica de derecho público. En el caso de las entidades religiosas reconocidas por el artículo 20 de la ley 19.638, deberán citar esta norma jurídica;
- 2º La fecha y el lugar de la celebración del matrimonio;
- 3º El nombre y los apellidos paterno y materno de los contrayentes, así como sus números de cédula de identidad;
- 4º La fecha y el lugar de nacimiento de los contrayentes;
- 5º Su estado de soltero, divorciado o viudo y, en estos dos últimos casos, el nombre del cónyuge fallecido o de aquél con quien contrajo matrimonio anterior, y el lugar y la fecha de la muerte o sentencia de divorcio, respectivamente;
- 6º Su profesión u oficio;
- 7º Los nombres y apellidos de sus padres, si fueren conocidos;

8º Los nombres y apellidos de dos testigos, así como sus números de cédula de identidad, y su testimonio, bajo juramento, sobre el hecho de no tener ninguno de los contrayentes impedimento o prohibición legal para contraer matrimonio;

9º El nombre y los apellidos del ministro de culto, así como su número de cédula de identidad;

10º El hecho de haberse cumplido las exigencias establecidas en la ley para la validez del matrimonio civil, y

11º La firma de los contrayentes, los testigos y el ministro de culto. Si alguno de los contrayentes no supiere o no pudiere firmar, se dejará testimonio de esta circunstancia. Deberá adjuntarse al acta el documento que acredite la personería del ministro de culto respectivo.

5. El acta debe ser presentada por los contrayentes ante cualquier oficial del Registro Civil dentro de 15 días para su inscripción.

- Quienes pueden presentar el acta son los propios contrayentes, en forma personal, o bien un mandatario especialmente facultado para este efecto por los contrayentes. El mandato deberá otorgarse por escritura pública e indicar el nombre, apellido, profesión u oficio y domicilio de los contrayentes y del mandatario.
- El plazo es de 15 días corridos. Si el último día del plazo recae en día sábado, feriado o inhábil, éste pasará al día hábil inmediatamente siguiente. Es un plazo de caducidad; si no se inscribe, el matrimonio no produce efecto civil alguno, es inexistente.
- El plazo es para presentar el acta y para inscribir el matrimonio.

6. Los comparecientes deben ratificar ante el oficial el consentimiento prestado ante el ministro del culto (sólo se ratifica lo que ya existe, por lo tanto la fecha del matrimonio es la del religioso, pues ahí se prestó el consentimiento).

Requisitos de la inscripción de los matrimonios celebrados ante entidades religiosas
(Art. 40 ter de la Ley de Registro Civil):

1º El Acta de que trata el artículo 40 bis.

2º El documento que acredite la personería del respectivo ministro de culto.

3º El hecho de cumplir el acta con los requisitos establecidos en el artículo 40 bis.

4º La individualización de la entidad religiosa ante la que se celebró el matrimonio, con mención del decreto o disposición legal en virtud de la cual goza de personalidad jurídica de derecho público.

5º Los nombres y apellidos de los contrayentes.

6º Las menciones indicadas en los números 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 39 de la Ley de Registro Civil.

7º El hecho de haberse cumplido con el plazo a que se refiere el artículo 20.

8º El hecho de haberse dado a conocer a los requirentes de la inscripción, los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a la ley.

9º El hecho de haberse otorgado por los requirentes de la inscripción, ante el Oficial del Registro Civil, la ratificación del consentimiento prestado ante el ministro de culto, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la LMC.

10º La firma de los requirentes de la inscripción y del oficial del registro civil.

Son requisitos esenciales de la inscripción de un matrimonio religioso los indicados en los números 1,2, 9 y 10.

Sólo puede negarse la inscripción si resulta evidente que el matrimonio no cumple con alguno de los requisitos exigidos por la ley.

3) MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO (ART. 80 LMC):

i) Requisitos de forma: se rigen por la ley del país en que se celebra el matrimonio.

ii) Requisitos de fondo: también se rigen por la ley del país en que se celebra el matrimonio, con 2 excepciones:

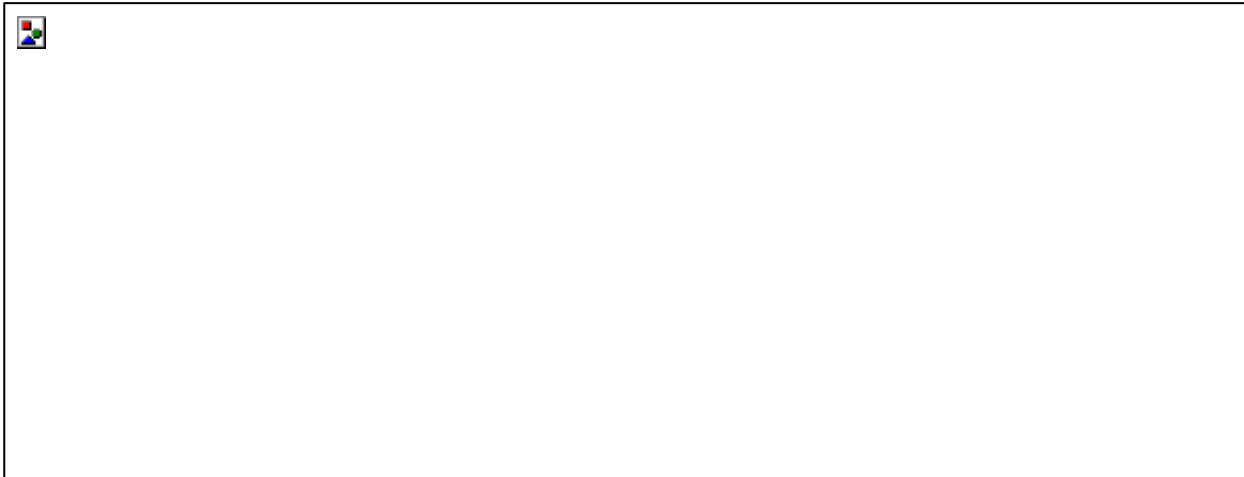
- a. Deben respetarse los impedimentos dirimentes; de lo contrario, puede declararse nulo el matrimonio en Chile.
- b. No tienen valor en Chile los matrimonios en que no hubo consentimiento libre y espontáneo.

iii) Efectos: son los mismos que si se hubiera celebrado en Chile, (ya no se requiere que se trate de un hombre y una mujer, luego de la ley 21.400)

- El cónyuge domiciliado en Chile puede exigir alimentos del otro ante los tribunales chilenos, conforme a la ley chilena, como del mismo modo puede hacerlo el cónyuge residente en el extranjero respecto del cónyuge domiciliado en Chile (Art. 82 LMC).
- Además, hay que tener presente la regla del Art. 135 inc. 3º CC, relativa al régimen matrimonial.

Art. 135 inc. CC: Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. Tratándose de matrimonios entre personas del mismo sexo casadas en país extranjero, sólo podrán pactar el régimen de participación en los gananciales.

CAPÍTULO 4. TÉRMINO DE LA VIDA EN COMÚN DE LOS CÓNYUGES.



I. Terminación de la vida en común sin disolución de vínculo

4.1. SEPARACIÓN DE HECHO:

1. Concepto de separación: situación matrimonial en la que, subsistiendo el vínculo conyugal, se produce un distanciamiento personal entre los cónyuges y se altera, por lo menos parcialmente, el régimen jurídico de sus respectivos derechos y obligaciones.

No existe ni noción ni causales específicas de ella, pues no tiene legislación que la atienda, existiendo muchos casos en los cuales jamás se judicializa. La Ley de Matrimonio Civil lo único que hace es ponerse en el evento que los cónyuges se separaren de hecho. Como el estado de separación de hecho, que supone el cese de la convivencia, se produce sin intervención judicial alguna, la Ley de Matrimonio Civil solo se limita a reconocer tal situación fáctica, y a permitir que los cónyuges que se hallen en tal estado regulen, de común acuerdo, sus relaciones mutuas para tal estado de separación. En subsidio, dicho acuerdo se regula judicialmente. Lo que le interesa a la ley es determinar cuándo se produjo el cese de la convivencia, el cual se toma en cuenta para computar los plazos.

2. Forma de regular las consecuencias de la separación:

i) Regulación de común acuerdo:

Art. 21 LMC. "Si los **cónyuges** se separaren de hecho, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente (1) los alimentos que se deban y (2) las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio.

En todo caso, si hubiere **hijos**, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, (1) el régimen aplicable a los alimentos, (2) al cuidado personal y (3) a la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tuviere bajo su cuidado. En este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido.

Requisitos para que el acuerdo otorgue fecha cierta al cese de la convivencia
(Artículo 22 LM):

- a. Debe constar por escrito en alguno de los siguientes instrumentos:
 - 1) Escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario.
 - 2) Acta extendida ante un oficial del Registro Civil.
 - 3) Transacción aprobada judicialmente.
- b. Si el cumplimiento del acuerdo requiere una inscripción o anotación en un registro, la fecha del cese es aquella en que se cumpla tal formalidad.

ii) Regulación judicial:

A falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges puede pedir la regulación judicial. Puede pedirse en el juicio iniciado respecto de cualquiera de las materias señaladas en el Art. 21 LMC (Art. 23 LMC).

Es de competencia de los Tribunales de Familia, y se sujetan a su procedimiento. Aquí la fecha cierta del cese de la convivencia se produce con la notificación de la demanda (Art. 25 inc. 1º LMC).

3. Resumen sobre los casos que dan fecha cierta del cese de la convivencia:

- 1) Cuando el acuerdo de los cónyuges consta por escrito, por los instrumentos del Art. 22 LMC.
- 2) Cuando a falta de acuerdo, se demanda judicialmente (notificación de la demanda).
- 3) Cuando, habiendo uno de los cónyuges expresado su voluntad de poner fin a la convivencia, se notifique al otro cónyuge.

4. Efectos de la separación de hecho:

Estos no se encuentran regulados en la Ley de Matrimonio Civil, señalando Barrientos los siguientes, y entendiendo la separación de hecho como cese de la convivencia:

- 1) *Causa para solicitar la separación judicial:* Art. 27 inciso 1 de la LMC.:
"Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar al tribunal que declare la separación, cuando hubiere cesado la convivencia".
- 2) *Ineficacia de la alegación de adulterio para impetrar la separación judicial:*
Art. 26 inciso segundo de la LMC:
"No podrá invocarse el adulterio cuando exista previa separación de hecho consentida por ambos cónyuges".
- 3) *Se constituye causal para impetrar el divorcio:* tanto de común acuerdo como unilateralmente. Art. 55 incisos 1 y 3 de la LMC:

- "Sin perjuicio de lo anterior, el divorcio será decretado por el juez si ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor de un año. (...)
- Habrá lugar también divorcio cuando se verifique un cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de, a lo menos tres años, salvo que, a solicitud de la demandante, durante el cese de la convivencia, no ha dado cumplimiento, reiterado, a su obligación de alimentos respecto del cónyuge demandada y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo".

4) *Exclusión del abandono del hogar*: se excluyen las consecuencias civiles y penales, sin que se le pueda considerar una trasgresión grave de los deberes del matrimonio.

Por otro lado, "la separación de hecho, en cuanto estado fáctico que no afecta la naturaleza ni los caracteres de la unión conyugal, si bien significa dotar de cierto ámbito de libertad a ambos cónyuges en la medida en la cual han acordado el cese de la convivencia, no implica que cesen los restantes deberes y derechos recíprocos entre marido y mujer, tales como los de socorro y ayuda mutua".

4.2 SEPARACIÓN JUDICIAL.

1. Causales de separación judicial:

1. Por uno de los cónyuges si mediare falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común (Art. 26 LMC).

2. Por cualquiera de los cónyuges, cuando hubiere cesado la convivencia (Art. 27 LMC).

Si la solicitud es conjunta, deben acompañar un acuerdo que regule sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo debe ser:

- *Completo*: regular todas las materias del Art. 21 LMC.
- *Suficiente*:
 - i. Resguarda el interés superior de los hijos,
 - ii. Procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y
 - iii. Establecer relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges.

2. Tribunal y procedimiento:

Es de competencia de los Tribunales de Familia, y se sujetan a su procedimiento. Pero puede solicitarse en el procedimiento a que dé lugar algunas de las acciones referidas en el Art. 23 LMC o una denuncia por violencia intrafamiliar (Art. 29 LMC).

Art. 23 LMC. A falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el procedimiento judicial que se sustancie para reglar las relaciones mutuas, como los alimentos que se deban, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio; o las relaciones con los hijos, como los alimentos, el cuidado personal o la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o madre que no los tuviere bajo su cuidado, se extienda a otras materias concernientes a sus relaciones mutuas o a sus relaciones con los hijos.

Art. 29 LMC. La separación podrá solicitarse también en el procedimiento a que dé lugar alguna de las acciones a que se refiere el artículo 23, o una denuncia por violencia intrafamiliar producida entre los cónyuges o entre alguno de éstos y los hijos.

La acción para demandar la separación judicial es irrenunciable.

Los cónyuges casados en sociedad conyugal pueden solicitar al tribunal la adopción de las medidas provisorias que estimen conducentes para la protección del patrimonio familiar y el bienestar de sus miembros (Art. 30 LMC).

3. Contenido de la sentencia que declara la separación (Art. 31 LMC):

- 1) Debe pronunciarse sobre cada una de las materias del Art. 21 LMC, a menos que se encuentren reguladas o no proceda la regulación de alguna de ellas. Si las partes lo regularon, el juez debe revisar el acuerdo y subsanar las deficiencias de oficio.
- 2) Debe liquidar el régimen matrimonial existente si así se solicita y se rinda prueba suficiente.

4. Efectos de la separación judicial:

Produce sus efectos desde que queda ejecutoriada la sentencia.

Requisito para que sea oponible: Debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial, momento a partir del cual:

- Es oponible a terceros,
- Los cónyuges adquieren la calidad de separados, que no los habilita para volver a contraer matrimonio (siguen casados, Art. 32 LMC).

1) Se adquiere el estado civil de separado judicialmente¹³.

¹³ Se discute si el estado de separado judicialmente es o no un estado civil.

- Postura a favor: si es un estado civil porque toda vez que, conforme a la LMC, cuando se reanuda la vida en común, se restituye el estado civil de casados.
- Ramos Pazos no está de acuerdo, sosteniendo que los cónyuges separados mantienen su condición de casados. Entre las causales de terminación del matrimonio que indica el artículo 42 no se contempla la sentencia que declara la separación judicial. Cabe señalar que su posición se explica en oposición a considerarlos solteros

2) Subsisten los derechos y deberes entre cónyuges, salvo los incompatibles con la vida separada, que se suspenden (fidelidad y cohabitación) (Art. 33 LMC).

3) Se disuelve la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales (Art. 34 LMC).

4) No se altera el derecho a suceder por causa de muerte, salvo que se hubiere dado lugar a la separación por culpa de un cónyuge (Art. 35 LMC).

5) El cónyuge que dio lugar a la separación pierde el beneficio de competencia a que podría tener derecho (Art. 1626 N° 2 CC).

6) El cónyuge que no haya dado causa a la separación judicial, tendrá derecho para que el otro cónyuge lo provea de alimentos según las reglas generales (Art. 174 CC).

7) El cónyuge que dio causa a la separación por su culpa tiene derecho para que el otro le provea de lo necesario para su modesta sustentación (Art. 175 CC). Pero en este caso el juez reglará la contribución teniendo en especial consideración la conducta que haya observado el alimentario antes y después del divorcio.

8) Ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades (Arts. 178 y 160 CC).

9) El hijo concebido durante la separación no goza de la presunción del Art. 184 CC de tener por padre al marido (Art. 37 CC), pero puede ser inscrito como hijo de los cónyuges, de común acuerdo.

10) Autoriza para revocar las donaciones hechas al cónyuge que dio causa a la separación (Art. 1790 CC).

11) Los cónyuges pueden celebrar contratos de compraventa entre sí (Art. 1796 CC).

12) No se suspende la prescripción a favor de la mujer separada judicialmente de su marido (Art. 2509 CC).

13) No puede concederse la adopción a los cónyuges respecto de los cuales se haya declarado la separación, mientras ésta subsista.

5. Reconciliación o reanudación de la vida en común:

Puede producirse en dos momentos:

- 1) Mientras se tramita el juicio de separación (Art. 38 LMC): basta dejar constancia en el expediente, con lo que se pone fin al procedimiento.
- 2) Cuando ya hay sentencia (Art. 39 LMC): es necesaria una nueva sentencia que, a petición de ambos cónyuges, revoque la anterior.
 - Debe inscribirse al margen de la inscripción matrimonial para que sea oponible a terceros.
 - Pero si la separación se produjo porque uno de los cónyuges la solicitó por haber cesado la convivencia, basta que ambos dejen constancia de la reanudación en acta extendida ante el oficial del Registro Civil, subinscrita al margen de la inscripción matrimonial, para que sea oponible a terceros.

Art. 40 LMC. La reanudación de la vida en común, luego de la separación judicial, no revive la sociedad conyugal ni la participación en los gananciales, pero los cónyuges podrán pactar este último régimen en conformidad con el artículo 1723 del Código Civil.

Art. 41 LMC. La reanudación de la vida en común no impide que los cónyuges puedan volver a solicitar la separación, si ésta se funda en hechos posteriores a la reconciliación de los cónyuges.

6. Situación de las personas divorciadas temporal o perpetuamente.

Las personas que con anterioridad a la vigencia de la LMC se hayan divorciado, temporal o perpetuamente, por sentencia ejecutoriada, tendrán el estado civil de separados, y se registrarán por lo dispuesto en ella para los separados judicialmente respecto del ejercicio de derechos y demás efectos anexos que tengan lugar después de su entrada en vigencia (Art. 6 transitorio LMC)

II. Terminación de la vida en común con disolución de vínculo

TERMINACIÓN DEL MATRIMONIO.

Art. 42 LMC. "El matrimonio termina:
1º Por la muerte de uno de los cónyuges;
2º Por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en el artículo siguiente;
3º Por sentencia firme de nulidad;
4º Por sentencia firme de divorcio, y
5º Por voluntad del cónyuge de la persona que ha obtenido la rectificación de la ley N° 21.120, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19 de dicho cuerpo legal."¹⁴

4.3 POR MUERTE NATURAL

Esta característica deriva de la definición de matrimonio que otorga el Art. 102 del Código Civil, en cuanto éste dura "por toda la vida"¹⁵.

¹⁴ Esta última causal fue incorporada por la ley 21.120 sobre identidad de género. Para más información, revisar anexo IV.

¹⁵ Como estudiamos en persona, el Código Civil no otorga definición alguna de muerte, limitándose a señalar que la persona se termina por su muerte natural. Sin embargo, la

Ley de Trasplante de Órganos define la muerte como la horizontalidad del electroencefalograma, pero sólo para efectos de esa ley.

En tanto que la muerte natural hace cesar el matrimonio, ella también extingue los derechos que derivaban de él, y por regla general, extingue igualmente las obligaciones emanadas del mismo, con la excepción de la obligación de dar sepultura al cadáver.

4.4. POR MUERTE PRESUNTA

La muerte presunta está contemplada en el artículo 80 de nuestro Código.

Art. 80 del CC. "Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive y verificándose las condiciones que van a expresarse".

Para que ponga término al matrimonio deben concurrir los siguientes requisitos:

- 1) Sentencia que declare la presunción de muerte, conforme al procedimiento de los artículos 80 a 94 del Código Civil.
- 2) El transcurso de cierto plazo desde la fecha de las últimas noticias. Si bien la regla general contemplada por el legislador es el plazo de 5 años para que se declare la muerte, respecto del matrimonio deberán transcurrir 10 años desde la última noticia para poder casarse por segunda vez, salvo que el desaparecido tuviere más de 70 años, donde la regla general se mantiene, es decir, 5 años.

Art. 43 de la LMC: "El matrimonio termina por la muerte presunta de uno de los cónyuges, cuando hayan transcurrido diez años desde la fecha de las últimas noticias, fijada en la sentencia que declara la presunción de muerte.

El matrimonio también se termina si, cumplidos cinco años desde la fecha de las últimas noticias, se probare que han transcurrido setenta años desde el nacimiento del desaparecido. El mismo plazo de cinco años se aplicará cuando la presunción de muerte se haya declarada en virtud del número 7 del artículo 81 del Código Civil (herida grave de guerra u otro peligro semejante)

En el caso de los números 8 y 9 del artículo 81 del Código Civil, el matrimonio se termina transcurrido un año desde el día presuntivo de la muerte (pérdida de nave o aeronave o en caso de sismo o catástrofe.)

El posterior matrimonio que haya contraído el cónyuge del desaparecido con un tercero, conservará su validez aun cuando llegare a probarse que el desaparecido murió realmente después de la fecha en dicho matrimonio se contrajo".

Por lo tanto:

- a) 10 años desde la fecha de las últimas noticias.
- b) 5 años desde la fecha de las últimas noticias, si han transcurrido 70 años desde el nacimiento del desaparecido.
- c) 5 años desde la fecha de las últimas noticias en caso de herida grave de guerra u otro peligro semejante.

Por lo mismo, debemos obtener una definición de muerte de acuerdo a las reglas de

interpretación, esto es, según la ciencia o arte respectiva. Para Gonzalo Figueroa habría que considerarse el cese de las funciones cardiorrespiratorias

- d) 1 año desde el día presuntivo de la muerte, en caso de pérdida de nave o aeronave o en caso de sismo o catástrofe.

Declarada la muerte presunta, se extingue el régimen de bienes que hubiere existido entre los cónyuges. Art. 84 CC: "En virtud del decreto de posesión provisoria, quedará disuelta la sociedad conyugal o terminará la participación de los gananciales, según cual hubiera habido con el desaparecido (...)".

4.5. POR SENTENCIA FIRME DE NULIDAD

1. Particularidades de la nulidad matrimonial:

- 1) No hay causales genéricas. La ley señala en forma precisa los vicios que la producen.
- 2) No cabe distinguir entre nulidad absoluta o relativa (opinión mayoritaria).
- 3) En el caso del matrimonio putativo, no se produce el efecto propio de la nulidad de volver las partes al estado anterior.
- 4) No rige la regla de que no puede pedir la nulidad el que contrató sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalidaba (Art. 1683 CC). Sin embargo, algunas sentencias la han aplicado en base a que nadie puede aprovecharse de su propio dolo.
- 5) Por regla general, la acción de nulidad no prescribe, pero debe alegarse en vida de los cónyuges.

2. Causales de nulidad:¹⁶

- 1) Matrimonio celebrado existiendo impedimentos dirimentes (Art. 44 a) LMC).
- 2) Falta de libre y espontáneo consentimiento por parte de alguno de los contrayentes (Art. 44 b) LMC).
- 3) Matrimonio celebrado ante menor número de testigos o de testigos inhábiles (Art. 45 LMC).

3. Acción de nulidad:

Es una acción de derecho de familia, por lo tanto, es inenajenable, intransigible y no cabe a su respecto el llamado a conciliación.

4. Titulares de la acción de nulidad (Art. 46 LMC):

¹⁶ Si se trata de matrimonios celebrados antes de la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Matrimonio Civil, las formalidades y las causales de nulidad se rigen por la ley vigente al tiempo de su celebración, pero no se puede invocar la causal de incompetencia del oficial civil.

Por regla general la acción de nulidad del matrimonio corresponde a cualquiera de los presuntos cónyuges, salvo algunas excepciones que amplían o restringen la calidad de sujetos activos.

El titular de la acción en estas excepciones dependerá de la causal que se invoque para alegar la nulidad:

- La nulidad fundada en el Nº3 del artículo 5, podrá ser demandada por cualquiera de los cónyuges o por cualquier persona, fundándose en el interés superior del niño, niña o adolescente, pero alcanzados los dieciocho años por parte de ambos contrayentes, la acción se radicará únicamente en el o los que contrajeron sin tener esa edad.
- Falta de consentimiento libre y espontáneo por error o fuerza: la acción corresponde exclusivamente al sujeto que sufrió el vicio, sea error o fuerza.
- Matrimonio de persona moribunda: puede pedir la nulidad el sobreviviente y los herederos del cónyuge difunto, éstos últimos incluso después de su fallecimiento. La Ley habla de los "demás herederos" reconociendo así también el derecho del cónyuge sobreviviente.
- Vínculo matrimonial no disuelto: le corresponde al cónyuge anterior y a los herederos de éste. Se evitó expresamente entregar la titularidad a un representante de la sociedad (Ministerio Público), como se ha hecho en otros países.
- En el caso de la nulidad interpuesta a propósito de los artículos 6 y 7: podrá ser solicitada, además, por cualquier persona, en interés de la moral o de la ley. Con ello se asemeja a la nulidad absoluta pese a que la Ley de Matrimonio Civil habla simplemente de nulidad.

5. Prescripción de la acción de nulidad (Art. 48 LMC):

Regla general: es imprescriptible.

Excepciones:

- Acción por error o fuerza: si bien en el resto de la legislación civil es de 4 años desde la celebración del contrato o desde que la fuerza haya cesado, en el matrimonio la acción prescribe en el plazo de 3 años desde el momento desapareció el vicio.
- Acción por matrimonio de muerte: 1 año desde el fallecimiento del cónyuge moribundo.
- Acción por bigamia (vínculo anterior no disuelto): prescribe en 1 año desde el fallecimiento de uno de los cónyuges.

- Acción por falta de testigos hábiles: prescribe en el plazo de 1 año desde la celebración del contrato.

6. Plazo para interponer la acción de nulidad:

Sólo puede intentarse en vida de los cónyuges, excepto en el caso del matrimonio en artículo de muerte o de vínculo matrimonial no disuelto.

7. Sentencia que declara la nulidad.

La sentencia que declara la nulidad debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial (Art. 50 inc. 2º LMC).

8. Estatuto jurídico a aplicar: ¿Nulidad absoluta o relativa?

Para algunas materias, la nulidad matrimonial se asemeja a la nulidad absoluta, pero en otras a la relativa. La distinción es importante a la hora de querer ratificar el contrato aparentemente nulo. El matrimonio se entiende válido hasta que se declare nulo. Incluso, en materias patrimoniales se ha establecido expresamente que la nulidad relativa se puede ratificar. ¿Puede acaso ratificarse el matrimonio?

- Claro Solar y Corral sostienen que debe aplicarse la regla general, que es la nulidad relativa, procediendo por lo tanto, la ratificación.

- Para el artículo 1694 CC, la forma de ratificar el contrato es casándose nuevamente con las formalidades legales. Es por esto por lo que Figueroa sostiene que técnicamente no existe ratificación, sino que estamos en presencia de un contrato nuevo.

Art. 1694 del CC: "Para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto o contrato que se ratifica".

- Barrientos se aleja de estos autores, sosteniendo que es improcedente distinguir entre nulidad absoluta y relativa. Señala que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ha tendido a uniformarse en cuanto a que en sede de nulidad matrimonial no es aplicable la distinción del derecho común que diferencia, en relación con los actos de carácter patrimonial, entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

(...) El referido considerando 4º de la sentencia de la Corte Suprema, con carácter general, declaraba:

"Que , además, los jueces del mérito han cometido una falsa aplicación de la ley al decidir la litis con normas del Código Civil, que son propias del ámbito patrimonial, las que han sido usadas de un modo improcedente en el derecho de familia (...) como ocurre en la especie con la nulidad del matrimonio, que se rige por preceptos propios, de orden público (...) es evidente que las normas de la Ley de Matrimonio Civil, en cuanto regulan la nulidad y establecen los titulares de la acción, son privativas y contrarias a las del Código

Civil las que, por consiguiente, no resultan procedentes en estas materias, precisamente por mandato de ese precepto legal .

9. Efectos de la declaración de nulidad del matrimonio.

Los **cónyuges quedan en la misma situación que tenían al momento de casarse**. La nulidad retrotrae las cosas al estado anterior. Su declaración tiene efecto retroactivo.

Estos efectos se producen:

- Entre las partes desde que la sentencia queda ejecutoriada.
- Para que produzca efectos respecto de terceros, debe inscribirse marginalmente la sentencia de nulidad en la inscripción del matrimonio. Antes de ello es inoponible.

Art. 50 de la LMC La nulidad produce sus efectos desde la fecha en que queda ejecutoriada la sentencia que la declara, retrotrayéndose las partes al estado en que se encontraban al momento de contraer el vínculo matrimonial, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo y en los dos artículos siguientes.

La sentencia ejecutoriada en que se declare la nulidad de matrimonio, deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial y no será oponible a terceros sino desde que esta subinscripción se verifique.

Consecuencias:

- 1) Si después de la celebración del matrimonio que se anuló, uno de los cónyuges contrajo un nuevo matrimonio, éste último es válido.
- 2) No se ha producido parentesco por afinidad.
- 3) No han habido derechos hereditarios entre los cónyuges.
- 4) Las capitulaciones matrimoniales caducan.
- 5) No ha habido sociedad conyugal; se formó una comunidad. No debe haber reparto de gananciales.
- 6) La mujer no ha tenido el privilegio de la cuarta clase.
- 7) ¿La filiación sería extramatrimonial? Importante: no afecta nunca la filiación ya determinada. Fácil es entender la gravedad que toda esta situación supone. Por ello, y pensando especialmente en la filiación de los hijos, ha nacido la institución del matrimonio putativo, que pretende justamente evitar que se produzcan los efectos propios de la declaración de nulidad.

No obstante:

1. Es procedente la compensación económica. Ella se predica tanto del matrimonio nulo como del divorcio. Consiste en compensar al cónyuge que realiza labores domésticas y deja de percibir sus ingresos.

2. Puede dar origen al matrimonio putativo, aquel que parece ser matrimonio aunque no lo sea.

4.5.1 MATRIMONIO PUTATIVO

1. Concepto:

Es aquel que, siendo nulo, pero habiéndose celebrado o ratificado ante Oficial del Registro Civil, la ley considera que produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, si bien dejará de producir los efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges.

2. Requisitos:

- 1) Matrimonio nulo (si es inexistente, no cabe el matrimonio putativo).
- 2) Debe celebrarse ante oficial del Registro Civil.
- 3) Buena fe, a lo menos, de uno de los cónyuges (conciencia de estar celebrando un matrimonio sin vicios). El matrimonio conserva el carácter de putativo mientras dura la buena fe.
- 4) Justa causa de error (error excusable).

Se presume que los cónyuges han contraído matrimonio de buena fe y con justa causa de error.

3. Efectos:

Produce los mismos efectos civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo. Hay que distinguir:

1) Efectos en relación con los hijos: El hijo concebido durante el matrimonio putativo de los padres conserva la filiación matrimonial. Los efectos son permanentes, aunque desaparezca la putatividad.

2) Efectos en relación con los cónyuges: Son los mismos que el válido mientras se mantenga la buena fe a lo menos en uno de los cónyuges.

La buena fe cesa,

- Respecto del cónyuge que demanda la nulidad, por el sólo hecho de presentar la demanda,
 - Respecto del otro cónyuge, con la contestación de la demanda.
 - Todo esto sin perjuicio de probarse que la buena fe se perdió antes.
- Si sólo uno de los cónyuges contrajo matrimonio de buena fe, puede optar entre:

- Reclamar la disolución y liquidación del régimen de bienes que hubiere tenido hasta ese momento, o
- Someterse a las reglas de la comunidad.

El cónyuge de buena fe puede conservar las donaciones que por causa del matrimonio le hizo o prometió hacer el otro.

4.6. POR SENTENCIA FIRME DE DIVORCIO.¹

1. Concepto:

Consiste en la terminación del vínculo matrimonial por las causales expresadas en la ley, ya sea por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común o por cese de convivencia durante los plazos establecidos en la ley.

Aquí se contemplan 3 tipos de divorcio:

- Divorcio con causal imputable al otro.
- Divorcio de común acuerdo.
- Divorcio unilateral.

4.6.1 DIVORCIO CON CAUSAL IMPUTABLE AL OTRO, DIVORCIO SANCIÓN O POR CULPA:

De acuerdo al Art. 54 LMC el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges, por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común.

Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos:

1º Atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos;

2º Trasgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común es una forma de trasgresión grave de los deberes del matrimonio;

3º Condena ejecutoriada por a comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública, o contra las personas, previstos en el Libro II, Títulos VII y VIII, del Código Penal, que involucre una grave ruptura de la armonía conyugal;

4º ~~Conducta homosexual~~; (causal derogada por ley 21.637, promulgada el 6 de

¹ En el anexo 5 al final de este apunte se encuentran las normas transitorias de la ley 21515, que regulan los divorcios de menores de edad casados bajo la vigencia de la antigua ley.

agosto de 2021).

5° Alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre éstos y los hijos, y

6° Tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos.

Frente a la demanda, el juez debe ponderar si hubo incumplimiento de los deberes (elemento objetivo), y si este incumplimiento es de tal entidad que haga intolerable la vida en común (elemento subjetivo).

- Las causales enumeradas no son taxativas.
- En estos casos, no es necesario un plazo del cese de la convivencia.

4.6.2. DIVORCIO DE COMÚN ACUERDO (DIVORCIO REMEDIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO)

Hablamos de divorcio remedio porque el divorcio se acepta como la solución a una crisis proveniente de la ruptura definitiva de la armonía conyugal. Requiere:

- 1) El transcurso de un año desde el cese de convivencia.**
- 2) La solicitud conjunta de los cónyuges.**
- 3) La presentación de un acuerdo regulador de las relaciones mutuas y para con los hijos, completo y suficiente.**

Si bien el legislador quiso señalar que la causal era el cese de la convivencia y no la solicitud de mutuo acuerdo, para que pueda ejercitarse la acción de divorcio se requiere el mutuo consentimiento de los cónyuges, pues de lo contrario no puede ejercerse, aunque haya existido el cese de la convivencia, de lo cual resulta, que el cese de la convivencia es simplemente un requisito añadido a la verdadera causa para accionar. Por el contrario, aunque exista cese de la convivencia, no puede ejercerse la acción de divorcio si no hay mutuo consentimiento.

Art. 55 incisos 1 y 2 de la LMC: "Sin perjuicio de lo anterior, el divorcio será decretado por el juez si ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo y acreditan que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor de un año.

En este caso, los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que, ajustándose a la ley, regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. El acuerdo será completo si regula todas y cada una de las materias indicadas en el artículo 21. Se entenderá que es suficiente si resguarda el interés superior de los hijos, procura aminorar el menoscabo económico que pudo causar la ruptura y establece relaciones equitativas, hacia el futuro, entre los cónyuges cuyo divorcio se solicita".

4.6.3 DIVORCIO UNILATERAL (DIVORCIO REMEDIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL)

Cuando lo solicite cualquiera de los cónyuges por haberse producido un cese efectivo de la convivencia conyugal, durante a lo menos **3 años**. Requisitos:

1) Cese efectivo de la convivencia conyugal: no basta el hecho material de la separación; se requiere el animus separationis (intención de no querer hacer vida común).

2) Que el cese haya durado a lo menos 3 años. Esto sólo puede probarse:

1. Por alguno de los instrumentos del Art. 22 LMC
 - Escritura pública o acta protocolizada ante notario,
 - Acta ante oficial del Registro Civil,
 - Transacción aprobada judicialmente).
2. Por la notificación de la demanda de regulación de sus relaciones mutuas (Art. 25 inc. 1º LMC).
3. Cuando uno de los cónyuges haya expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de cualquiera de los instrumentos del Art. 22 LMC y se haya notificado al otro cónyuge (Art. 25 inc. 2º LMC).
4. Cuando uno de los cónyuges ha dejado constancia de su intención de poner fin a la convivencia ante el juzgado correspondiente y ello sea notificado al otro cónyuge (Art. 25 inc. 2º LMC).

*** Si se trata de matrimonios celebrados antes de la entrada en vigencia de la LMC no rigen las limitaciones de los Arts. 22 y 25 LMC; el cese de la convivencia se puede probar por medios distintos a los señalados, salvo la confesión.

3) Que el actor haya cumplido con su obligación alimenticia respecto de su cónyuge e hijos. Cláusula de dureza.

Contiene una especie de excepción a la acción de divorcio. Si el cónyuge que lo pide no ha cumplido con las obligaciones de alimentos, no podrá solicitar el divorcio unilateral. El problema es que la Corte Suprema ha sostenido que se deben los alimentos desde el momento que existe una sentencia que los establece. La doctrina y jurisprudencia chilenas, en otras sedes, han sostenido que es necesario que exista una declaración judicial previa que declare concretamente la obligación de pagar alimentos para que pueda considerarse la procedencia del incumplimiento del deber de alimentos. Para Gonzalo Figueroa, los alimentos se deben desde mucho antes.

- Esta exigencia rige sólo si la parte demandada lo solicita.
- El incumplimiento reiterado e injustificado hará que la demanda sea rechazada.

2. Características de la acción de divorcio.

- 1) Pertenece exclusivamente a los cónyuges (Art. 56 inc. 1º LMC).
- 2) Corresponde a ambos cónyuges, salvo que el divorcio sea por culpa de uno de ellos.
- 3) Es irrenunciable e imprescriptible (Art. 57 LMC).

4) Tiene que intentarse en vida de los cónyuges. El cónyuge interdicto por disipación puede ejercerla por sí mismo (Art. 58 LMC).

3. Efectos del divorcio.

- 1)** Al igual que en la nulidad y la separación, **los efectos se producen entre las partes desde que la sentencia que declara el divorcio se encuentra ejecutoriada**. Respecto de terceros, el divorcio es oponible a terceros una vez que se anota marginalmente en la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, la sentencia que declara el divorcio.

Art. 59 de la LMC: "El divorcio producirá efectos entre los cónyuges desde que quede ejecutoriada la sentencia que lo declare.

Sin perjuicio de ello, la sentencia ejecutoriada en que se declare el divorcio deberá subinscribirse al margen de la respectiva inscripción matrimonial. Efectuada la subinscripción, la sentencia será oponible a terceros y los cónyuges adquirirán el estado civil de divorciados, con lo que podrán volver a contraer matrimonio".

- 2)** El divorcio **pone término al matrimonio sin efecto retroactivo**. En consecuencia, se acaban los derechos entre los cónyuges. Así, no se deben alimentos ni tienen derechos hereditarios entre sí.

Art. 53 de la LMC: "El divorcio pone término al matrimonio, pero no afectará en modo alguno la filiación ya determinada ni los derechos y obligaciones que emanan de ella".

Art. 60 de la LMC: "El divorcio pone fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el Párrafo 1 del Capítulo siguiente".

- 3)** **Se pone término al régimen patrimonial legal** establecido para el matrimonio, sin importar cuál fuere.
- 4)** **Se adquiere el estado civil de divorciado** y se recupera el ejercicio del ius conubii. Para Ramos Pazos, el estado civil de divorciados se adquiere desde el momento en que queda ejecutoriada la sentencia, sin que sea necesario que se inscriba la sentencia de divorcio al margen de la inscripción matrimonial.
- 5)** **Puede decretarse la compensación económica** si el juez la estime procedente y la parte afectada la reclama.
- 6)** Autoriza para **revocar las donaciones** que por causa de matrimonio se haya hecho al cónyuge que dio causa al divorcio por su culpa (Art. 1790 CC).
- 7)** Habilita al cónyuge para pedir la **desafección de un bien** de su propiedad que esté declarado como bien familiar (Art. 145 inc. final CC).

4. Divorcio obtenido en el extranjero (Art. 83 LMC).

1) El divorcio está sujeto a la ley aplicable a la relación matrimonial al tiempo de interponerse la acción (de acuerdo a las reglas de derecho internacional privado).

2) Las sentencias de divorcio y nulidad dictadas en el extranjero serán reconocidas en Chile de acuerdo a las reglas generales, es decir, debe darse el exequátur. Pero no tienen valor en los siguientes casos:

- i. Cuando el divorcio o nulidad no ha sido declarado por resolución judicial.
- ii. Cuando se opone al orden público chileno.
- iii. Cuando se ha obtenido con fraude a la ley.

Presunción de derecho de fraude a la ley: cuando el divorcio ha sido declarado bajo una jurisdicción distinta a la chilena a pesar de que los cónyuges han tenido domicilio en Chile durante cualquiera de los 3 años anteriores a la sentencia si:

- Ambos aceptan que su convivencia ha cesado a lo menos ese lapso, o
- Durante cualquiera de los 5 años anteriores a la sentencia, si discrepan en el plazo del cese de la convivencia.

5. Facultad para el juez de actuar de oficio.

El Art. 91 de la LMC establece que cuando se haya interpuesto solicitud de divorcio, en cualquier momento en que el juez advierta antecedentes que revelen que el matrimonio podría estar afectado en su origen por un defecto de validez, se los hará saber a los cónyuges, sin emitir opinión. Si en la audiencia, o dentro de los treinta días siguientes, alguno de los cónyuges solicita la declaración de nulidad, el procedimiento comprenderá ambas acciones y el juez, en la sentencia definitiva, se pronunciará primero sobre la de nulidad

CAPÍTULO 5. REGLAS COMUNES A CIERTOS CASOS DE SEPARACION, NULIDAD Y DIVORCIO.

5.1 COMPENSACIÓN ECONÓMICA

1. Ámbito de aplicación¹⁷.

Tiene lugar tanto en la declaración de nulidad de matrimonio y en el divorcio, pero no tiene lugar en la separación judicial porque el matrimonio no ha terminado.

2. Concepto.

Es el derecho que asiste a uno de los cónyuges (normalmente la mujer) cuando por haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar no pudo durante el matrimonio desarrollar una actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, para que se le compense el menoscabo económico que, producido el divorcio o la nulidad, sufrirá por esta causa (Art. 61 LMC).

3. Rubros a los que hay que atender para su fijación (Art. 62 LMC).

1. Duración del matrimonio y de la vida en común.
2. Buena o mala fe.
3. Edad y estado de salud del cónyuge beneficiario.
4. Situación provisional y beneficios de salud.
5. Cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral.
6. Colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

4. Determinación de la procedencia y monto de la compensación.

- 1) Fijación por las partes (Art. 63 LMC):
 - Deben ser mayores de edad,
 - Debe hacerse mediante escritura pública o acta de avenimiento, que se somete a la aprobación del tribunal.
- 2) Fijación por el tribunal (Art. 64 LMC): si no hay acuerdo, se puede pedir en la demanda o con posterioridad.

5. Forma de pago de la compensación (Art. 65 LMC).

El juez debe señalarla en la sentencia, y puede establecer las siguientes modalidades:

- 1) Entrega de una suma de dinero, acciones y otros bienes. Si es dinero, se pueden fijar una o varias cuotas.

¹⁷ La ley 20.830, que incorpora el acuerdo de unión civil, regula en el artículo 27 una compensación económica casi idéntica a la regulada en la LMC, a la que esta ley hace referencia respecto de su regulación y determinación. Ver capítulo 13

2) Constituir un derecho de usufructo, uso o habitación respecto de bienes que sean del cónyuge deudor. Si no tiene bienes suficientes, el juez puede dividirlo en las cuotas que sean necesarias (Art. 66 LMC).

6. En caso del divorcio-sanción.

Debe considerarse la culpabilidad del cónyuge: el juez puede denegar o disminuir prudencialmente el monto de la compensación que habría correspondido al cónyuge que dio lugar a la causal (Art. 62 inc. 2º LMC).

7. Cuando la compensación se fija en cuotas.

Éstas se asimilan a los alimentos para efectos de su cumplimiento (a menos que se dé suficiente garantía de su efectivo y oportuno pago): el cónyuge deudor puede ser apremiado con multas, se puede decretar orden de arraigo, etc. (Art. 66 inc. 2º LMC)

8. Calificación de la compensación económica (Ver material del profesor Carlos Pizarro).

La fisonomía de la compensación económica permite plantearse si ésta presenta un carácter alimenticio o se trata de una verdadera indemnización con carácter compensatorio.

1) Compensación económica y alimentos.

Por varias razones uno podría tender a pensar que la compensación económica constituye una pensión de alimentos a favor del cónyuge débil una vez decretada la nulidad o el divorcio:

- En este sentido, la ley establece que si el cónyuge deudor carece de bienes suficientes para solucionar la compensación, el juez puede dividirla en cuantas cuotas fuere necesario.
- Para fijar la compensación el juez tomará en cuenta la capacidad económica del cónyuge deudor. Este mismo criterio, figura entre los parámetros que debe considerar el juez para fijar el monto de la compensación económica: "la situación patrimonial de ambos". Si no se tratara de alimentos, sino de la simple compensación del menoscabo económico sufrido por el cónyuge débil, no habría razón para considerar la situación patrimonial del cónyuge deudor. En este caso bastaría calcular el desmedro económico con independencia de la situación patrimonial del beneficiario.
- Si la compensación se fijó en cuotas, éstas se considerarán alimentos, dice la ley, "para el efecto de su cumplimiento" (art. 66 incº2 LMC). Salvo que se hubieren otorgado garantías para el cumplimiento. Por lo tanto, cuando se fije la compensación económica en cuotas y el cónyuge deudor no haya ofrecido

garantías para su cumplimiento, procederán todos los apremios aplicables al alimentario contumaz en conformidad a la Ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias.

Críticas: No corresponde calificarla como alimentos por los siguientes motivos:

1. La mirada para determinar la procedencia de la compensación económica está volcada hacia el pasado. El juez debe considerar el sacrificio de alguno de los cónyuges en la vida marital, ya que por cuidar los hijos o dedicarse a las labores propias del hogar no pudo desarrollar una actividad remunerada o lo hizo en una menor medida de lo que podía y quería. En principio no se trata de evaluar las necesidades futuras del cónyuge beneficiario, sino de todo aquello que no pudo ingresar a su patrimonio en razón del sacrificio durante el matrimonio.

Esto no tiene nada que ver con los alimentos, los cuales se vinculan al deber de socorro y se fijan en base a las necesidades económicas del alimentario y las facultades económicas del alimentante.

2. La compensación económica se fija por una vez y por siempre, no siendo posible su revisión por ninguna causa. Ni siquiera una excepcional precariedad en la situación patrimonial del cónyuge deudor con posterioridad a su fijación puede justificar la revisión de la compensación económica. Tampoco una mejora en el estándar de vida del cónyuge beneficiario altera el quantum de la compensación fijada. La razón, parece ser, que el monto fijado compensa un perjuicio hacia el pasado sin relación con la situación patrimonial futura de los cónyuges.

3. Por último, la propia expresión compensación conlleva de manera inevitable la idea de indemnización. El texto legal señala que se trata de “compensar” el “menoscabo económico”. La compensación involucra una pérdida consumada o, al menos, previsible, en razón de un hecho acaecido con anterioridad. En este sentido la compensación económica se asemeja al lucro cesante, entendido este, como las ganancias no percibidas en razón de un ilícito civil. Surge la necesidad, entonces, de evaluar la relación entre la compensación económica y la responsabilidad civil.

2) Compensación económica y responsabilidad civil.

Si bien las características de la compensación económica involucran una semejanza con el lucro cesante no cabe confundir ambas instituciones.

Críticas:

1. No podría considerarse una genuina indemnización de perjuicios, pues ésta no exige culpa del cónyuge deudor. La compensación económica procede en todas las hipótesis de divorcio aún en el más inocuo solicitado por ambos cónyuges por cese de la convivencia por un plazo superior a un año.

2. Además, en la responsabilidad civil la indemnización se fija en consideración a la extensión del daño, sin considerar la buena o mala fe del

victimario, al menos en el ámbito extracontractual. Si la buena o mala fe del cónyuge deudor resulta relevante para fijar la compensación económica no es posible hablar de una genuina indemnización de perjuicios.

3. Por otra parte, no hay que olvidar que, al menos en el derecho comparado, el divorcio ha estado vinculado a genuinas hipótesis de responsabilidad civil. La compensación económica no cubre el daño moral, pues se refiere a un perjuicio material y en ningún caso de índole extrapatrimonial o moral.

3) La compensación económica y el enriquecimiento a expensas de otro.

La compensación económica consiste en el menoscabo patrimonial avaluado en dinero a favor de uno de los cónyuges que en razón de haberse dedicado más que el otro al cuidado personal de los hijos o a labores propias del hogar no desarrolló una actividad lucrativa o sus ingresos fueron inferiores a los que habría podido obtener. La "compensación económica" presenta un marcado carácter indemnizatorio por el enriquecimiento del cónyuge deudor y el empobrecimiento del cónyuge beneficiario. De ahí que su naturaleza jurídica pueda explicarse a través del enriquecimiento a expensas de otro.

El pago de la compensación económica se justifica en la pérdida del cónyuge beneficiario de un estándar de vida al cual accedía durante la vida conyugal al haberse dedicado a la crianza de los hijos o a las tareas del hogar. El trabajo desempeñado por el cónyuge beneficiario significó un enriquecimiento del cónyuge deudor, puesto que este último gozaba de un nivel de vida en razón del sacrificio del cónyuge beneficiario. La voz "enriquecimiento" corresponde entenderla no sólo como el incremento patrimonial, sino que comprende, también, la exclusión de un pasivo en el patrimonio del enriquecido. Por lo mismo, el empobrecimiento del cónyuge beneficiario puede consistir en una merma económica o en la ausencia de ingresos a su patrimonio.

La explicación más apropiada consiste en la compensación del menoscabo económico del cónyuge beneficiario y el enriquecimiento injusto del cónyuge deudor, ambos elementos propios del enriquecimiento a expensas de otro.

Si bien el menoscabo económico justifica la admisión de la compensación económica, los parámetros para fijar su monto están más bien centrados en la situación actual del cónyuge beneficiario y su futura vida.

Al momento de analizar la procedencia de la compensación económica la ley no distingue si la decisión de contribuir a la familia con trabajo doméstico o la crianza de los hijos fue voluntaria o impuesta. Sólo tendrá relevancia, la aptitud profesional del cónyuge beneficiario al momento de fijar el monto.

Salvo acuerdo de los cónyuges, el juez debe establecer en una cantidad fija de dinero el menoscabo económico del cónyuge beneficiario. No se trata de una pensión basada en deberes de socorro o auxilio, sino de una

“compensación” del daño patrimonial destinada a mantener un cierto nivel de vida al cual el cónyuge beneficiario tiene derecho en virtud del sacrificio realizado durante el matrimonio.

Existe, entonces, un compromiso en la ley que toma en cuenta el empobrecimiento del cónyuge beneficiario, pero al momento de determinar el monto de la compensación no se lleva a cabo un cálculo en base a dicha merma en el patrimonio, sino una cuestión distinta, se evalúa la situación actual del cónyuge beneficiario al momento de la ruptura y las perspectivas de vida hacia el futuro. Este compromiso permite explicar la compensación económica en la nueva legislación.

5.2. CONCILIACIÓN.

Solicitada la separación o el divorcio, se debe llamar a las partes a una audiencia de conciliación especial, que persigue 2 objetivos:

1. Tratar de superar el conflicto de la pareja, y
2. Si ello no es factible, acordar las medidas relativas a:
 - Los alimentos de los cónyuges e hijos,
 - Su cuidado personal,
 - La relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o la madre que no los tenga a su cuidado,
 - El ejercicio de la patria potestad (Art. 67 LMC).

No cabe que la parte demandada pueda en esta audiencia aceptar la demanda, o que ambas partes acuerden el divorcio.

Terminada la conciliación, y logrado un acuerdo, será revisado por el Juez del tribunal correspondiente, y una vez aprobada, tendrá el mismo valor que una sentencia definitiva firme y ejecutoriada.

5.3. MEDIACIÓN.

La mediación previa es **obligatoria** en los juicios de Alimentos, Relación Directa y Regular (visitas) o Cuidado Personal (tuición).

Según el art. 106 Ley N° 19.968, a partir del año 2009, si una persona quiere demandar judicialmente por algunas de las materias señaladas en la letra A., necesariamente debe intentar previamente un proceso de Mediación Familiar, sea en un Centro de Mediación contratado por el Estado o en un Centro de Mediación Privado. En definitiva, lo relevante es que la mediación debe ser guiada por un mediador/a registrado en el Registro Único de Mediadores Familiares del Ministerio de Justicia, conforme lo establece la ley.

Las formas en las que puede iniciar la mediación son: 1) derivación por el propio Tribunal en el que se intentó demandar; 2) asistiendo directamente a uno de los Centros contratados; 3) derivación de la Corporación de Asistencia Judicial.

En caso de ser aprobados posteriormente por un tribunal, los acuerdos de mediación, tienen el mismo valor jurídico que una sentencia. Si el acuerdo no es logrado, el juicio sigue su curso normal y se dará tramitación a la demanda, para lo que será necesario contar con un Certificado de Mediación Frustrada, otorgado por el propio mediador.

Existen casos de mediación **prohibida** como: Estado civil (salvo hipótesis de la Ley de matrimonio civil), declaración de interdicción, maltrato de niños/as y adolescentes, adopción y Violencia intrafamiliar (salvo inciso final artículo 106 ley 19.968).

La mediación será **facultativa** o voluntaria, cuando las partes sin necesidad del mandato de un juez o imposición de la ley, puedan acudir a un mediador: Aspectos educativos de crianza de los hijos, patria potestad, autorización para salir del país, compensación económica, declaración de bien familiar y separación judicial de bienes. No procede respecto de divorcio común acuerdo, ya que para ello siempre se requiere una declaración judicial.

CAPÍTULO 6. EFECTOS DEL MATRIMONIO.

- 1. Relaciones personales de los cónyuges
- 2. Régimen matrimonial
- 3. Alimentos
- 4. Derechos sucesorios

6.1. RELACIONES PERSONALES DE LOS CÓNYUGES.

1. Derechos y obligaciones personales entre los cónyuges.

Constituyen un conjunto complejo de deberes y facultades situados en la persona de cada uno de los cónyuges, desprendidos, por así decirlo, inmediatamente de la naturaleza y esencia íntima de la institución. Estos derechos y deberes tienen un contenido eminentemente moral.

Art. 131 CC. "Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos."

Art. 133 CC. "Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le asista razones graves para no hacerlo."

Art. 134 CC. "El marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medie. El juez, si fuere necesario, reglará la contribución."

2. Características.

Tienen características especiales:

- a) En general son deberes positivos.
- b) Afectan sólo a los cónyuges.
- c) Tienen un marcado carácter ético, quedando su cumplimiento entregado fundamentalmente a la conciencia de los cónyuges.

3. Enumeración.

1. DEBER DE FIDELIDAD.

Esto significa no tener relaciones sexuales con terceros.

Art. 132 inc. 1º CC. "El adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé."

Sanciones:

- a) Si el incumplimiento al deber de fidelidad es grave y reiterado, haciendo intolerable la vida en común, es causal de separación judicial y de divorcio.
- b) La mujer casada bajo sociedad conyugal puede pedir la separación de bienes.

2. DEBER DE SOCORRO.

Se deben alimentos de acuerdo al Art. 32 N° CC. Pueden darse diversas situaciones de los cónyuges:

- 1) Casados bajo sociedad conyugal y en estado de normalidad matrimonial: el marido debe proporcionar alimentos a la mujer, con cargo a la sociedad conyugal (Art. 1740 N° 5 CC).
- 2) Separados de bienes o participación en los gananciales: los cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común, atendiendo a sus facultades económicas (Arts. 134 y 160 CC).
- 3) Separados judicialmente: el cónyuge que dio lugar a la separación por su culpa tiene derecho a que el otro le provea de lo necesario para su modesta sustentación (Art. 175 CC).
- 4) Separados de hecho: igual que los separados de bienes.
- 5) Matrimonio nulo: cesa la obligación de prestarse alimentos.
- 6) Divorciados: también cesa la obligación.

Sanciones:

- 1) La mujer puede pedir la separación judicial de bienes.
- 2) Si el incumplimiento es grave y reiterado, haciendo intolerable la vida en común, el cónyuge afectado puede demandar la separación judicial o el divorcio.

3. DEBER DE AYUDA MUTUA.

Consiste en los cuidados personales y constantes que los cónyuges se deben recíprocamente.

Sanción: autoriza a la mujer para pedir la separación judicial de bienes.

4. DEBER DE RESPETO RECÍPROCO.

El incumplimiento grave de este deber, si torna intolerable la vida en común, constituye causal para demandar la separación judicial. Si lo incumple el marido, la mujer puede pedir la separación de bienes.

5. DEBER DE PROTECCIÓN RECÍPROCA.

Misma sanción que el anterior.

6. DERECHO Y DEBER DE VIVIR EN EL HOGAR COMÚN.

En cuanto a la sanción por el incumplimiento, se han dado diversas soluciones:

- 1) El cónyuge incumplidor debe pagar una indemnización. No es buena solución por la dificultad de precisar los perjuicios.
- 2) Se puede exigir el cumplimiento con auxilio de la fuerza pública. Tampoco es buena, porque se requeriría el permanente auxilio de la fuerza pública, lo que la hace impracticable. Además, es contraria a la libertad personal.
- 3) Si es la mujer la que incumple, cesaría la obligación del marido de darle alimentos (la mora purga la mora). Esta sanción no se ajusta al incumplimiento de obligaciones derivadas del Derecho de Familia.

En todo caso, puede llegar a constituir una causal de separación judicial y de divorcio.

La excepción al deber ("que a alguno de ellos le asistan graves razones para no hacerlo") debe ser apreciada por el juez en cada caso.

7. DEBER DE COHABITACIÓN.

Es la obligación que tienen los cónyuges de tener relaciones sexuales entre sí. El incumplimiento grave y reiterado de este deber puede llegar a constituir una causal para demandar la separación judicial y el divorcio.

8. AUXILIOS Y EXPENSAS PARA LA LITIS.

Art. 136 CC. "Los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. El marido deberá, además, si está casado en sociedad conyugal, proveer a la mujer de las expensas para la litis que ésta siga en su contra, si no tiene los bienes a que se refieren los artículos 150, 166 y 167, o ellos fueren insuficientes."

1. Obligación recíproca de proporcionarse auxilios para sus acciones y defensas judiciales: ha sido entendida no como obligación de suministrar expensas, sino otro tipo de auxilios. Ej. Colaborar en la obtención de medios de prueba. Pero esto es discutido, pues algunos piensan que incluye las expensas.

2. Obligación del marido de dar expensas para la litis a su mujer, para que atienda los juicios que ésta siga en contra de él. Requisitos:

- 1) Pleitos seguidos entre marido y mujer, sin que importe la naturaleza de la acción deducida ni la condición procesal de cada uno.
- 2) Sólo cabe si los cónyuges están casados en sociedad conyugal.
- 3) La mujer debe carecer de bienes suficientes para atender por sí misma este gasto.

6.2. RÉGIMEN MATRIMONIAL.

1. Definición.

Régimen matrimonial: estatuto jurídico que regula las relaciones pecuniarias de los cónyuges entre sí y respecto de terceros.

Consecuencias:

1. El régimen matrimonial es en su esencia un estatuto de disciplinamiento, es decir, un conjunto de normas jurídicas articuladas en un sistema base del ordenamiento económico del lugar.
2. Este estatuto regula los intereses económicos de los cónyuges entre sí. Las relaciones extrañas, aunque sean laterales o concomitantes, no forman parte del régimen matrimonial.
3. El régimen matrimonial actúa también como medida de protección de los terceros.

2. Distintos regímenes matrimoniales.

1. RÉGIMEN DE COMUNIDAD DE BIENES: todos los bienes que los cónyuges aportan al matrimonio y los que adquieren durante él constituyen una masa común que pertenece a ambos, y que se divide una vez disuelta la comunidad.

1) Comunidad universal: todos los bienes, sin distinción alguna, forman el fondo común.

2) Comunidad restringida: sólo algunos bienes pasan a ser comunes.

i) *Comunidad restringida de bienes muebles y ganancias*: se excluyen los bienes raíces aportados y los adquiridos durante el matrimonio a título gratuito.

ii) *Comunidad restringida de ganancias únicamente*: sólo ingresan al haber común los bienes muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, y los frutos de estos y de los bienes propios. A este régimen corresponde la sociedad conyugal chilena.

2. RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES: hay 2 patrimonios; el del marido y el de la mujer. No hay patrimonio común. En Chile, existe como régimen alternativo.

3. RÉGIMEN SIN COMUNIDAD: cada cónyuge conserva sus bienes, pero todos son administrados por el marido, salvo los reservados, que administra la mujer.

4. RÉGIMEN DOTAL: hay dos clases de bienes:

- Los dotales, que la mujer aporta al matrimonio,
- Los parafernales, que la mujer conserva en su poder y administra.

5. RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES: durante la vigencia del régimen, cada cónyuge tiene su propio patrimonio, que administra con libertad. Pero a su extinción, el cónyuge que ha adquirido bienes de mayor valor, debe compensar al que ha obtenido menos.

- 1) Comunidad diferida: terminado el régimen, se produce ipso iure una comunidad que integran todos los bienes adquiridos a título oneroso por los cónyuges, y que se reparten por partes iguales.
- 2) Variante crediticia.

6.3. SOCIEDAD CONYUGAL.

1. Concepto.

Sociedad conyugal: sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio (Art. 135 inc. 1º CC).

La sociedad conyugal comienza con el matrimonio y cualquier estipulación en contra es nula. Excepción: personas casadas en el extranjero se miran en Chile como separadas de bienes, salvo que inscriban su matrimonio y pacten la sociedad conyugal (Art. 135 inc. 2º CC).

Art. 135 CC. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que se expondrán en el título De la sociedad conyugal.

Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción.

2. Naturaleza Jurídica.

a) ES UNA SOCIEDAD. Pero hay muchas diferencias esenciales:

- 1) Debe existir diferencia de sexo.
- 2) No hay obligación de hacer aportes.
- 3) La administra siempre el marido.
- 4) Las utilidades se reparten por mitades.
- 5) No se puede pactar por un plazo determinado.

b) ES UNA COMUNIDAD. Pero es muy distinta:

- 1) Mientras dura, la mujer no tiene ningún derecho sobre los bienes sociales.
- 2) La comunidad nace precisamente al momento en que la sociedad conyugal se disuelve.

c) ES UNA PERSONA JURÍDICA. Pero esto no es cierto, porque frente a los terceros sólo existe el marido.

d) SE TRATA DE UNA INSTITUCIÓN SUI GENERIS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS. Tal vez a lo que más se parece es a un patrimonio de afectación.

Se trata de un fenómeno o una institución especial que reviste aspectos distintos entre los cónyuges y frente a terceros.

❖ Entre los cónyuges existen claramente 3 patrimonios: el propio de cada cónyuge y el patrimonio social. Pero la mujer carece de derechos sobre sus bienes propios mientras subsista la sociedad conyugal, aunque no pierde por ello la titularidad de los bienes.

❖ Frente a terceros existen únicamente dos patrimonios: El del marido (donde se confunden los bienes sociales con los bienes propios de él) y el de la mujer. En consecuencia, en el régimen de sociedad conyugal pueden existir diversos patrimonios sujetos a una regulación o estatuto jurídico distinto:

- El patrimonio de la sociedad conyugal (haber y pasivo absoluto y relativo).
- El patrimonio propio de cada cónyuge.
- Eventualmente, el patrimonio reservado de la mujer.

3. Es exclusiva de los matrimonios heterosexuales. "Los esposos del mismo sexo podrán celebrar capitulaciones matrimoniales, pero en caso alguno podrán pactar el régimen de sociedad conyugal." (art. 1715 incº3 CC).

6.3.1 CAPITULACIONES MATRIMONIALES.

1) Concepto.

Son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración (Art. 1715 inc. 1º CC).

2) Características.

- 1) Son convenciones (pueden ser contratos si realmente crean derechos y obligaciones).
- 2) Obligan no sólo a los esposos, sino también a los terceros que contraten con ellos.
- 3) Constituyen un acto jurídico dependiente.
- 4) Por regla general, son inmutables.

3) Consentimiento y capacidad.

El consentimiento puede prestarse personalmente o a través de mandatarios, pero no a través de un representante legal.

La capacidad es la misma que se requiere para casarse, pero:

- Si se halla bajo curaduría, requiere la autorización de las personas que deben consentir en el matrimonio (Art. 1721 CC),

4) Solemnidades (Art. 1716 inc. 1º CC).

- 1) Si se celebran antes del matrimonio:
 - i) Escritura pública.
 - ii) Subinscripción al margen de la inscripción matrimonial (esto es solemnidad, no requisito de publicidad).
 - iii) Que la subinscripción se practique al momento de celebrarse el matrimonio o dentro de los 30 días siguientes.
- 2) Si se celebran en el acto del matrimonio: basta que el pacto conste en la inscripción del matrimonio.

5) Modificación. Inmutabilidad.

Sólo pueden modificarse antes de celebrarse el matrimonio, con las mismas solemnidades con que se otorgaron (Art. 1722 CC).

La excepción está en el Art. 1723 CC, que permite modificar el régimen matrimonial bajo el cual se casaron:

- 1) Si se casaron en sociedad conyugal, pueden sustituirlo por cualquiera de los otros.
 - 2) Si se casaron con separación de bienes, pueden sustituirlo por participación en los gananciales.
 - 3) Si se casaron en participación en los gananciales, pueden sustituirlo por separación de bienes.
- Está expresamente prohibido volver a la sociedad conyugal.

6) Objeto.

1. Capitulaciones celebradas en el acto del matrimonio: sólo pueden tener por objeto pactar la separación total de bienes o el régimen de participación en los gananciales.
2. Capitulaciones celebradas antes del matrimonio: pueden tener variados objetos. (Ej. Acordar separación total o parcial de bienes; renuncia de los gananciales, etc.). El límite es que no pueden contener estipulaciones contrarias a las buenas costumbres ni a las leyes, ni ir en detrimento de los derechos y obligaciones legales de los cónyuges entre ellos y respecto de los hijos (Art. 1717 CC).

6.3.2 HABERES EN LA SOCIEDAD CONYUGAL.

Para determinar los bienes que componen el activo de la sociedad conyugal, hay que distinguir el haber absoluto y el relativo:

- **Haber absoluto** lo forman todos aquellos bienes que ingresan definitivamente a la sociedad conyugal de manera irrevocable y sin cargo de recompensa.
- **Haber relativo o aparente**, está formado por aquellos bienes que ingresan a la sociedad otorgando al cónyuge aportante un derecho de recompensa (crédito) que éste hará valer al momento de la liquidación de la sociedad conyugal. Por ejemplo, los bienes muebles que los cónyuges tenían antes de contraer matrimonio. Así, el automóvil ingresa a la sociedad, pero el cónyuge aportante tiene un crédito en contra de ella para que se le pague su valor actualizado a la fecha de la liquidación.

6.3.2.1 HABER ABSOLUTO.

Lo forman todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal en forma definitiva, sin derecho a recompensa.

Está integrado por los bienes a que se refieren los artículos 1725 N° 1, 2 y 5, Art. 1730 y 1731 CC.

1) SALARIOS Y EMOLUMENTOS DE TODO GÉNERO DE EMPLEOS Y OFICIOS, DEVENGADOS DURANTE EL MATRIMONIO (Art. 1725 N° 1 CC):

- Es decir, cualquier remuneración que perciban los cónyuges durante el matrimonio (honorarios, sueldos, gratificaciones, etc.).
- Es el producto del trabajo, cualquiera sea su duración, importancia o forma.
- Lo importante es que deben “devengarse” durante el matrimonio y no “pagarse” durante el matrimonio.
- La ÚNICA EXCEPCIÓN A ESTA REGLA es la remuneración de la mujer en el ejercicio de una actividad separada de su marido: Ingresa al patrimonio reservado de la mujer (Art. 150) de manera que esos recursos serán administrados por la mujer. Sin embargo, lo anterior no le quita el carácter de sociales a estos bienes, pues su destino definitivo a la disolución de la sociedad será la de ingresar a la masa de gananciales (salvo que la mujer renuncie a ellos).
- **SERVICIOS PRESTADOS COMO SOLTEROS Y FINALIZADOS COMO CASADOS:** El problema se plantea respecto de trabajos que se comienzan a ejecutar siendo solteros y se terminan siendo casados. Por ejemplo, el abogado cuyos honorarios se van devengando conforme al avance del juicio. La doctrina soluciona este tema atendiendo a la divisibilidad o no del trabajo.

- Si el trabajo no es divisible, el honorario se devengará al final del mismo y entrará a la sociedad conyugal si al tiempo de finalizarlo estaban ya casados.
 - Si el trabajo es divisible: corresponde a la sociedad conyugal la parte del honorario devengada durante la vigencia.
- DONACIONES REMUNERATORIAS: Otro problema relacionado a este número es el de las donaciones remuneratorias (definidas en el art. 1433). El art. 1738 resuelve este tema.

Art. 1433 CC. Se entenderán por donaciones remuneratorias las que expresamente se hicieren en remuneración de servicios específicos, siempre que éstos sean de los que suelen pagarse.

Para determinar el destino de estas donaciones hay que distinguir (Art. 1738 CC):

- i) Donación inmueble:
 - a. Si corresponde a servicios que dan acción: ingresa al haber absoluto.
 - b. Si no dan acción: ingresa al haber propio.
 - ii) Donación mueble:
 - a. Si dan acción: ingresa al haber absoluto.
 - b. Si no dan acción: ingresan al haber relativo.
- DINEROS OBTENIDOS EN JUEGO: Ingresan al haber absoluto, sin importar si son juegos de azar, destreza física o intelectual.
 - INGRESOS PROVENIENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: Se discute si ingresan al absoluto o al relativo.
 - Algunos (Alessandri) dicen que las utilidades pecuniarias que provienen de su explotación durante la sociedad conyugal ingresan al haber absoluto, aunque la propiedad intelectual se haya constituido antes. Pero el derecho de autor constituido por la propiedad intelectual antes del matrimonio ingresa al haber relativo, pues se trata de un derecho mueble aportado por el cónyuge al matrimonio.
 - Otros autores sostienen que el derecho de autor en sí mismo, es decir, la facultad de explotar exclusivamente una obra de ingenio o del talento con un fin de lucro no ingresa al haber de la sociedad conyugal. Es un bien propio de cada cónyuge, por su carácter de exclusividad. Él sólo puede autorizar a otro la explotación de dicha obra; pero los frutos o réditos de la explotación de la obra ingresan al haber social.

2) TODOS LOS FRUTOS, RÉDITOS, PENSIONES, INTERESES Y LUCROS DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE PROVENGAN, SEA DE LOS BIENES SOCIALES, SEA DE LOS BIENES PROPIOS DE CADA UNO DE LOS CÓNYUGES, Y QUE SE DEVENGUEN DURANTE EL MATRIMONIO (Art. 1725 N° 2 CC).

- FUNDAMENTO DE QUE SE INCLUYAN:

- 1) Están destinados a atender las necesidades de la familia.
- 2) Si la sociedad es obligada a pagar las cargas y reparaciones fructuarias de los bienes propios y sociales, es razonable que los frutos ingresen a la sociedad.

- MODO DE ADQUIRIR ESTOS FRUTOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD CONYUGAL:

- i) Fruto producido por un bien social: accesión.
- ii) Fruto producido por un bien propio: ley.

- USUFRUCTO DEL MARIDO SOBRE LOS BIENES DE LA MUJER (ART. 810 CC): la doctrina sostiene que no se trata realmente de un derecho de usufructo. Si así fuera, cuando el marido enajena los bienes de la mujer, estaría enajenando la nuda propiedad, lo que no es cierto.

En cuanto a la inembargabilidad de este usufructo, lo que es inembargable es el usufructo en sí mismo (Art. 2466 CC), pero los terceros pueden embargar los frutos (que han ingresado al haber absoluto), con la limitación de que no pueden privar al marido de lo que necesite para atender las cargas de familia.

3) TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES ADQUIERA DURANTE EL MATRIMONIO A TÍTULO ONEROSO.

No importa si se adquiere a nombre del marido o de la mujer, lo importante es que (1) el título traslativo se haya celebrado durante la vigencia de la sociedad conyugal, y (2) que sea oneroso. Para determinar lo anterior, debe atenderse a la causa o título de adquisición y no a la incorporación definitiva del bien (ejemplos de esto los encontramos en el Art. 1736 CC).

EXCEPCIONES: bienes que no entran al haber absoluto de la sociedad, aunque se adquieran a título oneroso durante ella (se supone que no se adquirieron con bienes sociales).

1. El inmueble que fuera debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los cónyuges (por ejemplo, vende la casa que tenía antes de casarse y con la plata de la venta compra otra) Art. 1727.
 2. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinado a ello en las capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio (art. 1727)
 3. Los bienes adquiridos por la mujer en el ejercicio de una actividad separada del marido. Ingresan al patrimonio reservado, aunque recordemos que estos bienes tienen vocación de ser sociales.
- Aplicaciones especiales:
 - 1) Cuando se adquiere durante la vigencia de la sociedad conyugal, a título oneroso, un inmueble contiguo al inmueble propio de uno de los cónyuges, el bien adquirido ingresa a la sociedad conyugal, a menos que con el propio forme una heredad o edificio de que el terreno adquirido no pueda desmembrarse sin daño (pierden su individualidad). En este caso, la sociedad y el dueño del inmueble propio pasan a ser copropietarios del todo, a prorrata de los valores al tiempo de la incorporación (Art. 1728 CC).

2) Si el cónyuge es comunero con otras personas de un bien propio, y vigente la sociedad conyugal adquiere las demás cuotas a título oneroso, se mantiene la indivisión entre ese cónyuge y la sociedad conyugal, a prorrata del valor de la cuota que pertenecía al cónyuge y lo que le haya costado la adquisición del resto (Art. 1729 CC).

4) LAS MINAS DENUNCIADAS POR UNO O AMBOS CÓNYUGES DURANTE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL (Art. 1730 CC), a menos que sea aplicable el Art. 150 CC.

5) LA PARTE DEL TESORO QUE CORRESPONDE AL DUEÑO DEL SITIO EN QUE SE ENCUENTRA, CUANDO EL TESORO ES HALLADO EN UN TERRENO SOCIAL.

6.3.2.2 HABER RELATIVO.

Lo forman aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal otorgando al cónyuge aportante o adquirente un derecho de recompensa que éste hará valer al momento de la liquidación.

Está compuesto por:

1) DINERO APORTADO O ADQUIRIDO POR UNO DE LOS CÓNYUGES A TÍTULO GRATUITO DURANTE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL (Art. 1725 N° 3 CC).

- Se debe pagar la correspondiente recompensa, que de acuerdo al Art. 1734 CC, debe enterarse de manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo.
- Pese a que el Art. 1725 N° 3 CC no dice que la adquisición deba hacerse a título gratuito, esto es lógico porque, de lo contrario, ingresaría al haber absoluto.

2) BIENES MUEBLES APORTADOS O ADQUIRIDOS A TÍTULO GRATUITO POR CUALQUIER CÓNYUGE DURANTE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL (Art. 1725 N° 4 CC).

- Aquí tampoco dice que deba ser a título gratuito, pero ello está establecido en los Arts. 1726 inc. 2º y 1732 inc. 2º CC.
- La recompensa se entera en valor reajustado.
- Los cónyuges pueden eximir de este ingreso al haber relativo una parte de sus bienes muebles, designándolos en las capitulaciones matrimoniales.

3) TESORO (Art. 1731 CC).

- La parte del tesoro que corresponde al descubridor (50%) ingresa al haber relativo.

- La parte del tesoro que corresponde al dueño del terreno (50%):
 - i. Ingresa al haber relativo si el terreno era propio de un cónyuge.
 - ii. Ingresa al haber absoluto si el terreno era social, como veíamos antes.

4) DONACIÓN REMUNERATORIA MUEBLE QUE SE HACE A UNO DE LOS CÓNYUGES, CUANDO EL SERVICIO PRESTADO NO DABA ACCIÓN EN CONTRA DE LA PERSONA SERVIDA (Art. 1738 inc. 2º CC).

5) BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS POR UN CÓNYUGE DURANTE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO LA CAUSA O TÍTULO DE LA ADQUISICIÓN HA PRECEDIDO A ELLA.

6.3.2.3 HABER PROPIO O PERSONAL DE CADA CÓNYUGE.

Está compuesto por:

1) BIENES INMUEBLES QUE UN CÓNYUGE TIENE AL MOMENTO DEL MATRIMONIO.

Se deduce por exclusión: la ley no los menciona expresamente, pero el Art. 1725 N° 3 y 4 dispone que ingresan al haber relativo los bienes muebles tenidos al tiempo del matrimonio.

- Da igual que naturaleza tenga el título de adquisición (si es gratuito u oneroso).
- Da igual si lo adquirieron ambos conjuntamente: en tal caso tienen un derecho de dominio cuotativo sobre el bien raíz, que permanece en su patrimonio.

Si el bien se adquiere durante la sociedad conyugal, aunque sea a título oneroso, no pertenece a ella cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a ella (Art. 1736 CC). En consecuencia, no pertenecen a la sociedad:

- 1.** Las especies que uno de los cónyuges poseía a *título de señor* antes de ella, aunque la prescripción (por prescripción se retrotrae a la fecha en que se comenzó a poseer) o transacción (título declarativo de un derecho preexistente) con que las haya hecho verdaderamente suyas se complete o verifique en ella (Art. 1736 N° 1 CC).
- 2.** Los bienes (raíces) que los cónyuges poseían antes de ella por un *título vicioso*, pero cuyo vicio se ha purgado durante ella por la ratificación o por otro medio legal (Art. 1736 N° 2 CC).
- 3.** Los bienes que vuelven a uno de los cónyuges por *(1) nulidad o (2) resolución de un contrato, o (3) por haberse revocado una donación* (Art. 1736 N° 3 CC).
- 4.** Los *bienes litigiosos* y de que durante la sociedad ha adquirido uno de los cónyuges la posesión pacífica (Art. 1736 N° 4 CC).
- 5.** El *derecho de usufructo* (sobre un bien raíz) que se consolida con la propiedad que pertenece al mismo cónyuge (Art. 1736 N° 5 CC).

6. Lo que se paga (inmueble) a cualquiera de los cónyuges por *capitales de créditos* constituidos antes del matrimonio. Lo mismo se aplica a los intereses devengados por uno de los cónyuges antes del matrimonio y pagados después (Art. 1736 N° 6 CC).

- La única manera de aplicar esto es que se pague el crédito con un inmueble haciendo así una dación en pago. Porque si es mueble, aplicando el Art. 1736 inciso final, tiene que ingresar haber relativo.
- Lo mismo se aplica a los intereses devengados antes del matrimonio y pagados durante él con un bien raíz. (Todo interés devengado durante el matrimonio ingresa al haber absoluto y si paga en dinero o bien mueble ingresa al haber relativo).

7. Los bienes que un cónyuge adquiera durante la sociedad en virtud de un *acto o contrato cuya celebración se haya prometido con anterioridad a ella*, siempre que la promesa conste de un instrumento público, o de instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros de acuerdo con el Art. 1703 CC. Aquí lo que se ha querido es que se trate de una promesa oponible a terceros, sea por el Art. 1703 CC o por el Art. 419 COT.

Esta disposición no es taxativa.

Si el bien raíz se adquiere con bienes de la sociedad y del cónyuge, éste deberá la respectiva recompensa.

2) INMUEBLE ADQUIRIDO A TÍTULO GRATUITO POR UNO DE LOS CÓNYUGES DURANTE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL (ARTS. 1726 Y 1732 CC).

Las adquisiciones a título gratuito hechas por ambos cónyuges simultáneamente no aumentan el haber social, sino el de cada cónyuge.

3) BIENES MUEBLES QUE LOS CÓNYUGES EXCLUYEN DE LA SOCIEDAD EN LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES (ART. 1725 N° 4 INC. 2° CC).

Por regla general, los muebles que los cónyuges poseían antes del matrimonio ingresan al haber relativo de la sociedad conyugal. El inc. 2° del N° 4 del Art. 1725, permite excluir determinados bienes de la sociedad.

- Sólo puede referirse a exclusiones de bienes propios del cónyuge (no los del haber absoluto).
- Deben ser designados: Especificar los bienes excluidos.
- Los muebles permanecen en el haber propio del cónyuge y solo deben restituirse en especie al final.

4) AUMENTOS QUE EXPERIMENTEN LOS BIENES PROPIOS DE LOS CÓNYUGES (ART. 1727 N° 3 CC).

- i) Si el aumento es por causas naturales: el cónyuge no debe nada a la sociedad (Art. 1771 inc. 2° CC).

- ii) Si el aumento proviene de la mano del hombre: se genera una recompensa para la sociedad conyugal (Art. 1746 CC).

5) CRÉDITOS O RECOMPENSAS QUE LOS CÓNYUGES ADQUIEREN CONTRA LA SOCIEDAD Y QUE PUEDEN HACER VALER AL MOMENTO DE LA DISOLUCIÓN.

Es el caso de los créditos que adquieren los cónyuges por los bienes que aportan a la sociedad y que ingresan al haber relativo, con cargo de recompensa. El cónyuge aportante adquiere, entonces, un crédito contra la sociedad que hará efectivo al tiempo de la disolución. Ese crédito es un bien propio del cónyuge aportante.

6) INMUEBLES SUBROGADOS A UN INMUEBLE PROPIO DE UNO DE LOS CÓNYUGES O A VALORES (ART. 1727 N° 1 Y 2 CC).

La subrogación es el reemplazo de una cosa o de una persona por otra (subrogada) que pasa a ocupar su mismo lugar jurídico.

La regla general (Art. 1725 N° 5) es que, si durante la sociedad uno de los cónyuges adquiere un bien raíz a título oneroso, este bien ingresa al haber social. Excepción: Cuando el inmueble es debidamente subrogado:

- A otro inmueble propio del cónyuge.
- O a valores propios de un cónyuge, destinados a ello en las capitulaciones o en una donación por causa de matrimonio.

Clases de subrogación

a) Subrogación de inmueble a inmueble (por permuta o por compra).

1. *Por permuta.* El inmueble propio del cónyuge se cambia por otro que ocupa su lugar.

Condiciones para que opere.

- i. Sea un inmueble propio de uno de los cónyuges (si es de la mujer, se requiere su consentimiento)
- ii. Que la permuta se verifique durante la sociedad conyugal.
- iii. Que la permuta conste de escritura pública (porque a la permuta se le aplican las mismas reglas que a la compraventa)
- iv. Que en la misma escritura se exprese (puede o no ser con palabras sacramentales) el ánimo de subrogar.
- v. Debe existir proporcionalidad entre el bien que sale y el que se recibe (Art. 1733 inc. 6°)

2. *Por compraventa:* Vendo un inmueble propio y compro otro con el producto de la venta.

Condiciones para que opere.

- i. Inmueble que se vende es propio de un cónyuge.

- ii. Con el precio se compra otro inmueble. (El Código no contempla la subrogación por anticipación; esto es, que se compre primero y luego se vende el bien propio para pagar el precio del primero. Para Alessandri no hay subrogación, porque al comprar el primer bien raíz, entra al haber absoluto. Es una norma de excepción y por ende de derecho estricto).
- iii. Tanto en las escrituras de compra y de venta debe expresarse el ánimo de subrogar. (En la compra señalar que se hace con valores adquiridos por la venta de inmueble propio).
- iv. Proporcionalidad.
- v. Autorización de la mujer si se vende un bien propio de ella.

b) Subrogación de inmueble a valores.

Importante: No existe en Chile la subrogación de bienes muebles ni de mueble a inmuebles.

Con valores propios de un cónyuge se compra un inmueble (la ley habla de compradas, por lo que quedaría fuera la hipótesis de permuta).

Requisitos:

- i. Valores sean propios.
- ii. Destinados a adquirir un inmueble en:
 - Capitulación matrimonial: Si los valores los aporta un cónyuge en las capitulaciones anteriores al matrimonio debe destinarlos a la subrogación.
 - Donación por causa del matrimonio: Si un cónyuge dona valores al otro debe destinarlos en las capitulaciones matrimoniales anteriores al matrimonio. Si los dona un tercero, puede darles el destino antes o durante el matrimonio.
- iii. Que en la escritura de compra del inmueble aparezca en ella el ánimo de subrogar y la inversión de los valores ("el inmueble ha sido financiado con tales valores").
- iv. Proporcionalidad.
- v. Autorización de la mujer, sin son valores de ella.

Regla de la Proporcionalidad. Art. 1733 inc. 6° CC

La ley no exige que los inmuebles o valores subrogados sean del mismo valor al de la finca que se recibe o se compra. La ley acepta una diferencia de cierta magnitud.

Para saber si se cumple o no con el requisito de proporcionalidad, la ley da la regla.

1. Si el saldo a favor o en contra de la sociedad excede a la mitad del precio de la finca que se recibe, no hay subrogación, por lo que la finca ingresará al haber absoluto de la sociedad.

- El elemento clave: Precio finca recibida.

- Precio: La mitad del precio marca el límite para determinar si hay o no subrogación.
- Opciones:
 - i. La sociedad queda obligada a pagar una recompensa por el precio de la finca propia que enajenó o por los valores invertidos.
 - ii. O el cónyuge puede realizar la subrogación comprando otra finca.

2. *Si el saldo no excede de la mitad precio:* Hay subrogación por lo tanto la finca recibida será bien propio.

Con respecto al saldo habrá que distinguir:

- i. Si el bien que se adquiere es de menor valor que el inmueble o valores que se enajenan, el cónyuge subrogante adquiere una recompensa contra la sociedad por la diferencia (pues queda un saldo de dinero por la venta o permuta del bien propio; saldo que ingresa al haber relativo de la sociedad).
- ii. Si el bien que se adquiere es de mayor valor que el inmueble o valores que se enajenan, el cónyuge subrogante deberá pagar a la sociedad la correspondiente recompensa (pues se entiende que este mayor valor lo paga con bienes sociales).

Ventajas de la subrogación

1. Para la mujer y marido

- No se confunden sus bienes propios.
- Mujer no responde con sus bienes de las deudas.
- Marido dispone libremente de sus bienes.

2. Bienes propios se retiran en especie.

RESUMEN

Regla general:

	INMUEBLES	MUEBLES
TÍT. ONEROSO	HABER ABSOLUTO	HABER ABSOLUTO
TÍT. GRATUITO	HABER PROPIO	HABER RELATIVO

Excepciones:

1. Art. 1736 CC. La especie adquirida durante la sociedad no pertenece a ella aunque se haya adquirido a título oneroso, cuando la causa o título de la adquisición ha precedido a la formación de la sociedad conyugal.
2. Bienes muebles que los cónyuges excluyen de la sociedad conyugal en las capitulaciones matrimoniales.
3. Inmuebles subrogados a un inmueble propio de uno de los cónyuges o valores.

BIENES MUEBLES

- Aportados (haber relativo)
- Adquiridos durante el matrimonio con causa anterior (haber relativo)
- Adquiridos durante el matrimonio a título gratuito (haber relativo)
- Adquiridos durante el matrimonio a título oneroso (haber absoluto)
- Excluidos en las capitulaciones matrimoniales (haber propio)

BIENES INMUEBLES

- Aportados (haber propio)
- Adquiridos durante el matrimonio con causa anterior (haber propio)
- Adquiridos durante el matrimonio a título gratuito (haber propio)
- Adquiridos durante el matrimonio a título oneroso (haber absoluto)
- Subrogados (haber propio)

6.3.3. PRESUNCIONES DE DOMINIO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

Existen 3 presunciones de dominio, simplemente legales en relación al activo de la sociedad conyugal:

a) La consagrada en el artículo 1739 inc. 1º cc.

Frente a terceros, cuando el marido contrata obliga los bienes propios y los bienes sociales. Para proteger a estos terceros, existe una presunción de dominio de la sociedad conyugal. Art. 1739.

Esta presunción comprende toda clase de bienes que existan en poder de los cónyuges durante la sociedad conyugal o al disolverse. Se presumen pertenecer a la sociedad:

- cantidad de dinero
- de cosas fungibles
- especies
- créditos
- derechos
- acciones

Se trata de una presunción simplemente legal, que favorece a los terceros cuando demandan bienes sociales.

El cónyuge interesado en demostrar que se trata de un bien propio, debe destruirla. Vale cualquier medio de prueba, salvo:

- Respecto a los actos que debieron otorgarse por instrumento público.
- Confesión del cónyuge interesado o la declaración del otro no son prueba suficiente para destruir la presunción, pero la confesión se mirará como donación revocable: es donación revocable por lo tanto no transforma al donatario en dueño inmediatamente, pero puede serlo a futuro, si el donante muere sin revocarla. Antes de la muerte el bien sigue siendo social.

Tratándose de bienes muebles:

- Objeto del contrato debe ser un bien mueble.
- Los terceros que contraten con el cónyuge a título oneroso quedan cubiertos de toda reclamación fundada en que el bien es social o del otro cónyuge.
- Siempre que esté de buena fe.
- Cónyuge le haya hecho la tradición o entrega del bien respectivo.
- Entrega: comodato, depósito, etc.
- Tradición: Compraventa del bien.
- La buena fe se presume, por lo tanto, el cónyuge debe probar que el tercero sabía que el bien no le pertenecía. Salvo que el bien objeto del contrato figure inscrito a nombre del otro cónyuge en un registro abierto al público.
 - o Automóviles.
 - o Acciones Sociedad Anónima.
 - o Naves y aeronaves, etc.
 - o Se presume la mala fe.

b) Art. 1739 inc. Final cc:

"Se presume que todo bien adquirido a título oneroso por cualquier cónyuge después de disuelta la sociedad conyugal y antes de su liquidación, se ha adquirido con bienes sociales. El cónyuge deberá por lo tanto recompensa a la sociedad, a menos que pruebe haberlo adquirido con bienes propios o provenientes de su sola actividad personal".

- Están en comunidad y adquieren un bien a título oneroso.
- Bien es propio, pero se supone que lo compró con bienes de la comunidad por lo tanto debe recompensa, lo que no significa que el bien sea común.
- Consagración: Teoría de la apariencia. 1739 inciso 4º.

c) Art. 1737 cc:

Genera el efecto de incorporar a la comunidad aquellos bienes que adquiridos por uno de los cónyuges, corresponden a la sociedad en atención a que el título de adquisición se remonta a la época de existencia de la sociedad conyugal. Por ejemplo, dividendos de acciones devengados pero no cobrados.

6.3.4. PASIVO DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

I. Obligación a la deuda: Se refiere a la situación de los terceros acreedores en relación con la sociedad conyugal. Recordemos que para los terceros no hay pasivo social. Es decir, como para ellos no existe sociedad conyugal, pueden demandar al marido o a la mujer en sus bienes.

En consecuencia, la obligación a la deuda consiste en determinar qué obligaciones pueden ser demandadas al marido y cuáles a la mujer.

II. Contribución a la deuda: Una vez pagada la deuda, deberá determinarse a que patrimonio imputarla definitivamente, por lo regula la situación patrimonial entre los cónyuges solamente; los ajustes económicos que deben producirse entre ellos al liquidar la sociedad conyugal; y es ahí donde debemos distinguir pasivo absoluto y pasivo relativo.

6.3.4.1 PASIVO REAL O ABSOLUTO:

Lo forman aquellas deudas que la sociedad conyugal debe pagar sin derecho a recompensa. La deuda es social tanto desde el punto de vista de la obligación como de la contribución a la deuda.

Está constituido por:

1. PENSIONES E INTERESES QUE CORRAN, SEA CONTRA LA SOCIEDAD, SEA CONTRA CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y QUE SE DEVENGUEN DURANTE LA SOCIEDAD (ART. 1740 N° 1 CC).

- Contrapartida del derecho a los frutos que pertenece la sociedad.

- Los "intereses" pueden ser de cualquier tipo, civiles y naturales y provenir de cualquier deuda, sea que se contraiga antes o durante la sociedad.

Lo importante es que el interés se devengue durante ella.

2. DEUDAS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS DURANTE EL MATRIMONIO POR EL MARIDO, O LA MUJER CON AUTORIZACIÓN DEL MARIDO, O DE LA JUSTICIA EN SUBSIDIO, Y QUE NO FUEREN PERSONALES DE AQUÉL O DE ÉSTA (ART. 1740 N° 2 CC):

- 1) Deuda contraída por el marido: situación normal, porque administra la sociedad conyugal.
- 2) Deuda contraída por la mujer con autorización del marido: hoy en día, no tiene sentido a menos de entender que se trata de un mandato.
- 3) Deuda contraída por la mujer con autorización judicial: se relaciona con el Art. 138 CC, que autoriza a la mujer para actuar respecto de los bienes del marido, sociales y de los suyos que administre el marido, con autorización del juez, cuando al marido le afecta un impedimento que no es de larga o indefinida duración. En este caso, la mujer obliga al marido respecto de sus bienes y de los sociales como si el acto fuera del marido, y se obliga ella en sus bienes propios hasta concurrencia del beneficio que le reporte el acto.
- 4) Deudas contraídas por la mujer con mandato general o especial del marido (Art. 1751 CC): esta deuda es, respecto de terceros, deuda del marido y por consiguiente, de la sociedad. Pero si la mujer contrata a nombre propio, la deuda sólo puede hacerse efectiva en su patrimonio reservado (Art. 2151 CC).
- 5) Deudas contraídas conjunta, solidaria o subsidiariamente por el marido y la mujer: deben cobrarse a la sociedad conyugal, salvo en cuanto se pruebe que el contrato cedió en utilidad personal de la mujer (Art. 1751 inc. final CC).
- 6) Deudas provenientes de compras al fiado, que haga la mujer, de bienes muebles destinados al consumo ordinario de la familia (Art. 137 inc. 2º CC).

3. DEUDAS GENERADAS POR CONTRATOS ACCESORIOS (ART. 1740 N° 2 INC. 2º CC):

- 1) El marido garantiza con prenda, hipoteca o fianza una obligación de la sociedad conyugal: la sociedad es obligada al pago de la deuda.
- 2) El marido garantiza con prenda, hipoteca o fianza una obligación ajena: requiere de autorización de la mujer. Si no la obtiene, obliga sus bienes propios; si la obtiene, la deuda es de la sociedad conyugal, sin derecho a recompensa.
- 3) El marido garantiza con prenda, hipoteca o fianza una obligación personal de uno de los cónyuges: la sociedad está obligada al pago, con derecho a recompensa (pasivo relativo).

4. CARGAS Y REPARACIONES USUFRUCTUARIAS DE LOS BIENES SOCIALES O DE CADA CÓNYUGE (ART. 1740 N° 4 CC):

Debe aplicarse las normas del usufructo: corresponden a la sociedad conyugal las expensas ordinarias de conservación y cultivo (Art. 795 CC), y las cargas periódicas (Art. 796 CC).

En cuanto a las reparaciones mayores, corresponden a la sociedad si se trata de un bien social; si el bien es propio de un cónyuge, también corresponden a ella, pero con derecho a recompensa.

5. GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS CÓNYUGES; DE MANTENIMIENTO EDUCACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS DESCENDIENTES COMUNES; Y DE TODA OTRA CARGA DE FAMILIA (Art. 1740 N° 5 CC):

1) Gastos de mantenimiento de los cónyuges: son de cargo de la sociedad conyugal.

2) Gastos de mantenimiento, educación y establecimiento de los descendientes comunes: de acuerdo al Art. 230 CC, son de cargo de la sociedad conyugal.

a. Gastos de mantenimiento: alimentación, habitación, vestido, salud, etc.

b. Gastos de educación: enseñanza básica, media y profesional o universitaria.

1. Ordinarios: son de cargo de la sociedad conyugal, aunque el hijo tenga bienes propios. Sólo se pueden sacar bienes del hijo en caso necesario.

2. Extraordinarios: deben pagarse con los bienes del hijo, si los tiene, y sólo en cuanto le hayan sido efectivamente útiles. Si no, debe pagarlos la sociedad conyugal.

c. Gastos de establecimiento: son de cargo de la sociedad conyugal cuando el hijo carece de bienes propios y no conste de modo auténtico que los cónyuges han querido que se saquen de sus bienes propios.

3) Gastos para atender a otras cargas de familia: alimentos que uno de los cónyuges esté por ley obligado a dar a sus descendientes o ascendientes, aunque no lo sean de ambos cónyuges, pero el juez puede moderar este gasto si le parece excesivo. Si son excesivos y los paga la sociedad conyugal, es con derecho a recompensa por el exceso.

6. PAGO QUE, EN CONFORMIDAD A LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES, DEBE HACERSE A LA MUJER PARA QUE PUEDA DISPONER A SU ARBITRIO (ART. 1740 INC. FINAL CC).

Son de cargo de la sociedad conyugal, a menos de haberse convenido en las mismas capitulaciones que serían de cargo del marido.

6.3.4.2 PASIVO APARENTE O RELATIVO:

Lo forman aquellas deudas que la sociedad conyugal debe pagar, pero no soportar, adquiriendo una recompensa en contra del cónyuge deudor.

La deuda es:

- social desde el punto de vista de la obligación a la deuda,
- pero es personal del cónyuge desde el punto de vista de la contribución a la deuda.

Está integrado por las deudas personales de los cónyuges (Art. 1740 N° 3 CC). Ej.

1) DEUDAS ANTERIORES AL MATRIMONIO.

2) DEUDAS CONTRAÍDAS DURANTE EL MATRIMONIO QUE CEDEN EN BENEFICIO EXCLUSIVO DE UNO DE LOS CÓNYUGES.

3) DEUDAS PROVENIENTES DE MULTAS O REPARACIONES PECUNIARIAS A QUE FUERE CONDENADO UNO DE LOS CÓNYUGES POR UN DELITO O CUASIDELITO.

4) DEUDAS HEREDITARIAS O TESTAMENTARIAS PROVENIENTES DE UNA HERENCIA ADQUIRIDA POR UNO DE LOS CÓNYUGES.

5) TODA EROGACIÓN GRATUITA Y CUANTIOSA A FAVOR DE UN TERCERO QUE NO SEA DESCENDIENTE COMÚN. (ART. 1747 EN RELACIÓN AL ART. 1742)

6) LAS EXPENSAS HECHAS EN LOS BIENES PROPIOS DE LOS CÓNYUGES CUANDO ELLAS HAYAN AUMENTADO EL VALOR DE LOS BIENES Y ESTE AUMENTO SUBSISTA A LA FECHA DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD (ART. 1746).

Se debe el aumento del valor que la cosa haya experimentado como consecuencia de las expensas, pero si el aumento es superior al monto de las expensas, sólo se debe el importe de éstas.

7) CUANDO LA SOCIEDAD DEBA PAGAR LA DIFERENCIA QUE SE PRODUCE ENTRE EL PRECIO DE VENTA DEL BIEN PROPIO DEL CÓNYUGE Y EL BIEN ADQUIRIDO EN EL CASO DE LA SUBROGACIÓN.

6.3.5. RECOMPENSAS

1. Concepto:

Son el (1) conjunto de créditos o indemnizaciones en dinero (2) que se hacen valer al momento de liquidar la sociedad conyugal, (3) a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden.

2. Objetivos:

- 1) Evitar todo enriquecimiento, a menudo involuntario, de un patrimonio a expensas de otro.
- 2) Evitar que los cónyuges se hagan donaciones disimuladas.
- 3) Mantener la inmutabilidad del régimen matrimonial y el equilibrio entre los 3 patrimonios. Pues la composición de cada uno de los patrimonios está determinada por la ley o en las capitulaciones celebradas con anterioridad al matrimonio, por lo que lo que salga de un patrimonio para ingresar a otro debe ser reemplazado por uno equivalente.
- 4) Proteger a la mujer contra los abusos del marido.

3. Clasificación:

1) Recompensa adeudada por uno de los cónyuges a la sociedad conyugal.

Cada vez que uno de ellos se enriquece injustamente a expensas del patrimonio social y especialmente:

1. La sociedad pagó una deuda personal (Art. 1740 N° 3 CC).
2. El cónyuge adquirió un inmueble subrogándolo, y el valor del bien adquirido es mayor al que subrogó (Art. 1733 CC).
3. Se hicieron mejoras no usufructuarias en un bien propio, que aumentó el valor de la cosa (Art. 1746 CC).
4. El cónyuge adquirió una herencia y la sociedad pagó las deudas (Art. 1745 CC).
5. El cónyuge hizo una erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común.
6. La sociedad pagó una multa o indemnización generada por un delito o cuasidelito del cónyuge (Art. 1748 CC).
7. Precios, saldos, costas y expensas que se hicieron en la adquisición o cobro de los bienes o créditos del cónyuge (Art. 1745 CC).

2) Recompensa debida por la sociedad conyugal al cónyuge.

En general, cuando el cónyuge paga con recursos propios obligaciones de la sociedad conyugal, o cuando la sociedad se enriquece a expensas del patrimonio de un cónyuge. La ley señala especialmente.

1. Especies muebles o dineros que aportó o adquirió a título gratuito (Art. 1725 N° 3 y 4 CC).
2. Enajenación de un bien propio durante la vigencia de la sociedad conyugal (Art. 1741 CC).
3. Subrogación en que el bien adquirido era de menor valor (Art. 1733 CC).
4. Expensas de educación o establecimiento de un cónyuge se sacaron de los bienes propios de un cónyuge, sin que aparezca el ánimo de éste de soportarlas (Art. 1744 CC).

3) **Recompensas debidas por los cónyuges entre sí:** cuando se han beneficiado indebidamente a costa del otro, o cuando con dolo o culpa se han causado perjuicios.

1. Con bienes de uno se paga deudas personales del otro.
2. Deterioro en bienes propios de un cónyuge causados por dolo o culpa grave del otro.
3. Cualquier otro perjuicio que uno cause al otro.

4. Prueba:

El que alega una recompensa debe probar los hechos en que se funda (Art. 1698 CC). Sirven todos los medios de prueba, salvo la confesión, que se mirará, no obstante, como una donación revocable (Art. 1739 CC).

5. Cómo se pagan las recompensas:

- Reajustadas al tiempo de la liquidación.
- En dinero. Art. 1734, pero nada obsta a que pueda aceptarse otra forma de pago.
- Valor: "De manera que la suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa". ("en lo posible": No aparece ser en mandato absoluto del legislador).
- Debe lograrse acuerdo entre hombre y mujer.
- Y de no existir, decide el Juez partidario (arbitro arbitrador) que aplica la norma según la equidad.
- Pueden renunciarse, pero no durante la sociedad conyugal, pues ello implicaría una mutación del régimen.
- La renuncia a los gananciales por parte de la mujer no afecta sus derechos y obligaciones en materia de recompensas.

6.3.6. ADMINISTRACIÓN ORDINARIA DE LA SOCIEDAD CONUGAL.

- Es la que la ley encomienda al marido como jefe de la sociedad conyugal (Art. 1749 y 1752).
- Le corresponde al marido por el sólo hecho del matrimonio, de pleno derecho.
- Esta administración dura hasta la disolución de la sociedad conyugal o antes si el marido cae en interdicción, se ausenta o quiebra, caso en el cual se da paso a la administración extraordinaria.
- Estas normas sobre la duración de la administración son de orden público y no puede modificarse por los cónyuges en las capitulaciones matrimoniales.
- Esta administración comprende los siguientes bienes:

- Los sociales.
 - Los propios del marido.
 - Los propios de la mujer.
- Pero en cada caso las facultades son diferentes.

- ¿Debe el marido rendir cuenta de su gestión?
 - La mayor parte de la doctrina sostiene que no, ya que la ley no le impone esta obligación. Por el contrario, la ley dice que administra como dueño de los bienes sociales.
 - Sin embargo, esto es discutible porque es un principio general del derecho que cada vez que se administran bienes ajenos o que se posean en condominio se debe rendir cuenta, por lo que el marido debiera hacerlo al liquidar la sociedad conyugal. Además, el marido es responsable de daños y perjuicios causados a la mujer y a la sociedad por dolo o culpa.

6.3.6.1. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES:

PRINCIPIO GENERAL: el marido es el jefe de la sociedad conyugal, y en tal carácter administra esos bienes (Art. 1749 CC).

LIMITACIONES:

Después de la dictación del C.C. se han ido introduciendo mayores limitaciones en la administración de los bienes sociales para proteger los intereses de la mujer.

La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales pero se va a necesitar su autorización en muchos actos importantes, y sin esta autorización el acto será nulo o inoponible según el caso.

1) Limitaciones impuestas en las capitulaciones matrimoniales: no pueden tener una amplitud tan grande que priven al marido de la administración.

2) Limitaciones impuestas en el Título XXII del Libro IV: el marido necesita la autorización de la mujer para realizar los siguientes actos:

1. Enajenación voluntaria de bienes raíces sociales (Art. 1749 inc. 3º CC):
 - a. Se refiere exclusivamente a la enajenación voluntaria, no a la forzada.
 - b. Sólo se refiere a los bienes raíces, y sociales. Puede ser una cosa corporal o incorporeal.
 - c. La autorización debe darse para la celebración del título traslativo que antecede a la tradición.
 - d. La jurisprudencia también ha exigido la autorización para rescindir la compraventa de un bien raíz.
2. Gravamen voluntario de bienes raíces sociales (Art. 1749 inc. 3º CC).

3. Promesa de enajenación o gravamen de un bien raíz social (Art. 1749 inc. 3º CC).
4. Enajenación o gravamen voluntario o promesa de enajenación o gravamen sobre derechos hereditarios de la mujer (Art. 1749 inc. 3º CC).
5. Disposición gratuita, por acto entre vivos, de bienes sociales (Art. 1749 inc. 4º CC): el marido no puede hacer donaciones de bienes sociales sin autorización de la mujer, salvo que fueren de poca monta (Art. 1735 CC).
6. Arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces sociales por más de 5 años si se trata de predios urbanos, o más de 8 años si se trata de predios rústicos (Art. 1749 inc. 4º CC): deben computarse las prórrogas para el cálculo.
7. Constitución de avales u obligaciones accesorias para garantizar obligaciones de terceros (Art. 1749 incs. 5º y 6º CC). No es necesaria la autorización de la mujer en los casos en que la celebración de un contrato genera, como efecto del mismo contrato, la responsabilidad solidaria o subsidiaria (Ej. Endoso de la letra de cambio).

❖ **Características de la autorización de la mujer** (Art. 1749 inc. 7º CC):

- i) Específica: la que se da para celebrar un acto jurídico determinado en condiciones también determinadas.
- ii) Solemne: otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exige esta solemnidad.
- iii) Puede darse personalmente o por mandatario, que debe ser especial y solemne, en los términos recién señalados.
- iv) Puede ser suplida por la justicia (Art. 1749 inc. final CC). 2 casos:
 - a. Negativa de la mujer sin justo motivo.
 - b. Impedimento de la mujer, si de la demora se siguiere perjuicio.
- v) Debe ser previa: anterior al acto o simultánea con su celebración.

❖ **Autorización tácita:** Se entiende dada la autorización cuando la mujer interviene expresa y directamente de cualquier modo en el acto, ya sea como parte o de otra manera (Ej. Testigo). Si el acto consta por escrito, la mujer debe comparecer y suscribir el instrumento.

❖ **Sanción si se omite la autorización:**

- i) Regla general: nulidad relativa (Art. 1757 CC).
- ii) Excepciones:
 - a. En el caso del arrendamiento, la sanción es la inoponibilidad más allá de los plazos señalados.
 - b. En el caso de las cauciones, la sanción es que el marido sólo obliga sus bienes propios.

❖ **Titulares de la acción de nulidad o inoponibilidad y plazos:** pueden entablarlas la mujer, sus herederos o cesionarios. El cuadrienio de la nulidad se cuenta desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad del titular, pero no se puede pedir pasados 10 años de la celebración del acto (Art. 1757 CC).

❖ **Situación de la mujer que celebra un contrato de sociedad:**

i) Si era socia al momento de casarse: sus derechos en la sociedad son muebles, por lo que ingresan al haber relativo y los administra el marido. Pero esto puede no convenir a los socios, por lo que se puede pactar, al celebrar la sociedad, que si la mujer se casa, la sociedad se extinga. Si nada se dice, el marido ejerce los derechos. Si la mujer era administradora de la sociedad, ella continúa administrando.

ii) Si lo celebra casada:

a. Puede actuar dentro de su patrimonio reservado, caso en que se rige por el Art. 150 CC.

b. Si no tiene este patrimonio, no va a poder cumplir con su obligación de hacer los aportes (porque no tiene bienes bajo su administración), a menos que el marido consienta. Si no acepta, los demás pueden pedir la disolución de la sociedad.

c. Si tiene algunos de los patrimonios especiales de los Arts. 166 o 167 CC, puede celebrar el contrato obligando esos bienes.

❖ **Situaciones excepcionales en que la mujer participa en la administración de los bienes sociales y los obliga:**

1) Compras que la mujer haga al fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia (Art. 137 inc. 2º CC).

2) Caso de la administración extraordinaria de la sociedad (Art. 138 inc. 1º CC).

3) Caso de impedimento del marido que no sea de larga o indefinida duración y de la demora se sigue perjuicio (Art. 138 inc. 2º CC): requiere autorización judicial.

4) Caso de la mujer que actúa con mandato general o especial del marido.

5) Caso en que la mujer contrata respecto de bienes muebles, en que el tercero está de buena fe y se le ha hecho la tradición del bien, siempre que no se trate de bienes sujetos a régimen de inscripción (Art. 1739 incs. 4º y 5º CC).

6.3.6.2. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PROPIOS:

1. Del marido: Conserva las mismas facultades de cuando estaba soltero, pero los frutos de los bienes ingresan a la sociedad conyugal.

2. De la mujer: (Art. 1749 inc. 1º):

- La mujer no pierde el dominio sobre dichos bienes, solo pasa su administración, de pleno derecho, al marido.
- Esta facultad no es de orden público. Los cónyuges podrían alterarla en las capitulaciones matrimoniales, sea ampliando las facultades o restringiéndolas u otorgando a la mujer la plena administración de sus bienes propios.

1) Fundamento de la administración del marido: Como la sociedad se hace dueña de los frutos de los bienes propios de los cónyuges, el marido en su calidad de administrador de la sociedad conyugal, pasa a tener un derecho de goce legal sobre estos bienes y quien tiene el goce debe tener la administración de los bienes productores de los frutos.

2) Facultades del marido: son más limitadas, porque administra bienes ajenos.

- i) Responde de culpa leve.
- ii) La mujer puede obligarlo a rendir cuenta.

Limitaciones: Consiste en la autorización de la mujer. El marido no comparece en representación legal de la mujer, porque ella es capaz, sino como administrador de la sociedad conyugal).

1. Aceptación y repudiación de una herencia o legado deferido a la mujer: requiere consentimiento de la mujer (Art. 1225 CC). Sanción: nulidad relativa.

2. Aceptación o repudiación de una donación hecha a la mujer: requiere su consentimiento (Art. 1411 CC). Misma sanción.

3. Nombramiento de partidor en bienes en que tiene interés la mujer: requiere su consentimiento o de la justicia en subsidio (Art. 1326 CC). Sanción: nulidad relativa. Puede también pedirla la mujer, porque es la forma de hacer efectiva la acción de partición, y la mujer es plenamente capaz para intentar acciones.

4. Partición de bienes en que tiene interés la mujer: para provocar la partición, requiere el consentimiento de la mujer, si no está imposibilitada, o de la justicia en subsidio (Art. 1322 CC). Sanción: nulidad relativa. Puede también pedirla la mujer.

5. Enajenación de bienes muebles que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie: requiere consentimiento de la mujer, o de la justicia en subsidio si está imposibilitada (Art. 1755 CC). Sanción: nulidad relativa.

6. Arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces de la mujer, por más de 5 u 8 años, según se trate de predios urbanos y rústicos: requiere autorización de la mujer, o de la justicia en subsidio si está impedida o imposibilitada (Art. 1756 CC). Sanción: inoponibilidad.

7. Enajenación o gravamen de bienes raíces propios de la mujer: requiere su consentimiento, con los mismos requisitos que cuando se trata de un bien social (Art. 1754 CC). Sanción: nulidad relativa.

3) Intervención de la mujer en la administración de sus bienes propios.

Art. 1754 inc. final CC. "La mujer, por su parte, no podrá enajenar o gravar ni dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido, sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis."

No tiene la mujer ninguna participación en sus bienes propios.

Si la mujer realiza un acto sobre sus bienes propios, dicho acto adolece de nulidad.

- La CS en algunos casos ha dicho que la nulidad es absoluta.
- Pero la sanción debiera ser la nulidad relativa, ya que:
 - i. No existe una prohibición total de enajenar, sino que debe hacerlo a través del marido. Incluso puede solicitar la autorización subsidiaria de la justicia, en los casos del art. 138 bis.
 - ii. Es una formalidad establecida en atención al estado de la mujer casada en sociedad conyugal.
 - iii. Existen algunos fallos que han aceptado la posibilidad de ratificación del marido de estos actos ejecutados por la mujer (por lo que la sanción sería la nulidad relativa).

4) Autorización supletoria de la justicia para el caso que el marido se oponga a la enajenación de un bien propio de la mujer:

Art. 138 bis incs. 1º y 2º CC. "Si el marido se negare injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, el juez, previa citación del marido, podrá autorizarla para actuar por sí misma.
En tal caso, la mujer sólo obligará sus bienes propios y los activos de sus patrimonios reservados o especiales de los artículos 150, 166 y 167, mas no obligará al haber social ni a los bienes propios del marido, sino hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubieran reportado del acto."

Ahora, si el marido está impedido para dar la autorización, la mujer puede pedir autorización al juez, de acuerdo al Art. 138 CC.

Por lo tanto, situaciones especiales:

- a. art. 138: Si se suspende la administración del marido por impedimento de larga o indefinida duración y la administración pasa a la mujer. Si no es indefinido o larga duración, la puede ejercer la mujer con autorización del juez.
- b. Art. 138 bis: Si el marido se niega injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato respecto de un bien propio de la mujer, ella puede pedir autorización judicial para actuar por ella misma.
- c. La mujer puede aceptar o rechazar una herencia, legado o donación libremente (Antes de la Ley 18.802 debía actuar el marido con autorización de la mujer).

6.3.7. ADMINISTRACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

Art. 138 inc. 1º CC. "Si **por impedimento de larga o indefinida duración**, como (1) el de interdicción, (2) el de prolongada ausencia, o (3) desaparecimiento, se suspende la administración del marido, se observará lo dispuesto en el párrafo 4.º del título De la sociedad conyugal."

Art. 1758 CC. "La **mujer** que en el caso de interdicción del marido, o por larga ausencia de éste sin comunicación con su familia, hubiere sido nombrada curadora del marido, o curadora de sus bienes, **tendrá por el mismo hecho la administración de la sociedad conyugal**.
Si por incapacidad o excusa de la mujer se encargaren estas curadurías a otra persona, dirigirá el curador la administración de la sociedad conyugal."

Lo que tipifica a la administración extraordinaria es que la ejerce un curador del marido o de sus bienes. Normalmente será la mujer.

1) Casos en que tiene lugar la administración extraordinaria: cuando se ha designado un curador al marido, lo que ocurre por las siguientes razones:

- i. Por estar declarado en interdicción.
- ii. Por encontrarse ausente.

2) A quién corresponde la administración:

1) A la mujer: cuando sea nombrada curadora, lo que ocurre cuando el marido es:

- i) Demente.
- ii) Sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente.

2) A un tercero: cuando sea nombrado curador, lo que ocurre por las siguientes razones:

- i) Incapacidad o excusa de la mujer para ser ella curadora. En este caso, puede pedir la separación judicial de bienes, siempre que ambos cónyuges sean mayores de edad (Art. 1762 CC).
- ii) Marido declarado en interdicción por disipación.

3) Facultades con que se ejerce la administración:

1) Administración por un tercero: se trata simplemente de un curador que está administrando bienes ajenos; se rige por las reglas propias de los curadores.

2) Administración por la mujer:

i) Administración de los bienes sociales:

a. Regla general: administra con las mismas facultades del marido.

b. Limitaciones: requiere autorización judicial con conocimiento de causa para realizar los siguientes actos:

1. (1) Enajenar o (2) gravar voluntariamente o (3) prometer gravar o enajenar bienes raíces sociales (Art. 1759 inc. 2º CC).
2. Disponer entre vivos a título gratuito de los bienes sociales (Art. 1759 inc. 3º CC), pero no para donaciones de poca monta.
3. Otorgar cauciones respecto de terceros (Art. 1759 inc. 6º CC).
4. Dar en arriendo o ceder la tenencia de bienes raíces sociales, por más de 5 u 8 años según se trate de predios urbanos o rústicos (Art. 1761 CC).

- La sanción a los 2 primeros es la nulidad relativa.
- En el tercero, sólo obliga sus bienes de los Arts. 150, 166 y 167 CC.
- Para el último, es la inoponibilidad al marido o sus herederos.

Los actos realizados sin infracción, obligan a la sociedad y al marido, salvo que se hagan en negocio personal de la mujer.

ii) Administración de los bienes propios del marido: los administra de acuerdo a las reglas de los curadores, por lo que debe rendir cuentas.

4) Término de la administración extraordinaria: Art. 1763 CC. "Cesando la causa de la administración extraordinaria de que hablan los artículos precedentes, recobrará el marido sus facultades administrativas, previo decreto judicial."

6.3.8 DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

I. CAUSALES:

- 1)** Muerte natural de uno de los cónyuges (Art. 1764 N° 1 CC): Se disuelve el matrimonio y, por vía de consecuencia, la sociedad conyugal.
- 2)** Decreto que concede la posesión provisoria o definitiva de los bienes del cónyuge desaparecido (Art. 1764 N° 2 CC): La sociedad se reputa disuelta en el día presuntivo de la muerte, y hay que estarse a esa fecha para efectos de proceder a la liquidación.
- 3)** Sentencia de separación judicial (Art. 1764 N° 3 CC).
- 4)** Sentencia de separación total de bienes (Art. 1764 N° 3 CC): La disolución se produce de pleno derecho, sin retroactividad, tanto respecto de los cónyuges como de terceros, en el momento mismo en que la sentencia ejecutoriada se subinscribe al margen de la inscripción matrimonial, sin necesidad de que el juez la declare disuelta.
- 5)** Sentencia que declara la nulidad del matrimonio (Art. 1764 N° 4 CC): Esto ocurre sólo cuando el matrimonio fue putativo, pues en caso contrario, no hubo sociedad conyugal.
- 6)** Sentencia de divorcio (Art. 1764 N° 1 CC): Se disuelve el matrimonio y, por vía de consecuencia, la sociedad conyugal.
- 7)** Pacto de participación en los gananciales (Art. 1764 N° 5 CC): De acuerdo al Art. 1792-1 inc. 1º CC, los cónyuges pueden, con sujeción a lo dispuesto en el Art. 1723, sustituir el régimen de sociedad conyugal por el de participación en los gananciales.
- 8)** Pacto de separación total de bienes celebrado de acuerdo al Art. 1723 CC (Art. 1764 N° 5 CC): De acuerdo al Art. 1723 CC, los cónyuges mayores de edad pueden sustituir el régimen de sociedad conyugal por el de separación total.

Características del pacto del pacto del Art. 1723 CC:

- 1.** Es solemne:
 - a. Debe otorgarse por escritura pública.
 - b. Debe subinscribirse al margen de la inscripción matrimonial (solemnidad, no requisito de publicidad).
 - c. La subinscripción debe practicarse dentro del plazo fatal de 30 días desde la escritura.

2. No puede perjudicar el interés de terceros: no puede afectar los derechos válidamente adquiridos por ellos respecto del marido o de la mujer. Los terceros a los cuales se refiere son los acreedores.

3. Es irrevocable: no puede dejarse sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. Pero no resulta claro si lo que se quiere es sólo evitar la vuelta a la sociedad conyugal, o obsta también a que los cónyuges que se separaron de bienes puedan sustituir este nuevo régimen por el de participación en los gananciales.

4. No es susceptible de condición, plazo ni modo alguno.

En la misma escritura del pacto puede liquidarse la sociedad conyugal y acordar otros actos. Pero hay que tener presente que se están celebrando actos distintos, pues si bien la subinscripción es solemnidad del pacto, no lo es de la liquidación.

II. EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN:

1) Se genera una comunidad entre los cónyuges o, en su caso, entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido:

Es una comunidad a título universal.

- El activo está formado por los bienes que eran sociales, incluidos los bienes reservados y los frutos de los que administraba la mujer.
- El pasivo lo conforman las deudas sociales, incluidas las contraídas por la mujer en su patrimonio reservado. Pero si la mujer renuncia a los gananciales, el activo y pasivo de su patrimonio reservado no ingresan a la comunidad.

De esto surgen como consecuencias los dos efectos siguientes.

2) La comunidad es administrada por todos los comuneros.

El marido ya no sigue administrando los bienes sociales; si los grava o enajena, tales actos son inoponibles a la mujer.

3) Quedan fijados irrevocablemente el activo y pasivo social.

- i) Activo:
 - Todos los bienes que eran sociales al momento de la disolución.
 - Si se adquiere un nuevo bien entre la disolución y la liquidación, se presume (en forma simplemente legal) que el bien fue adquirido con bienes sociales, por lo que el cónyuge adquirente debe recompensa (Art. 1739 CC).
- ii) Pasivo: deudas que a ese momento eran sociales y las de la mujer en su patrimonio reservado.

4) Cesa el derecho de goce que la sociedad tenía sobre los bienes de los cónyuges.

1. Frutos naturales: los pendientes al tiempo de la disolución y los percibidos después de ella pertenecen al dueño del bien que los produce (Art. 1772 CC).
2. Frutos civiles: pertenecen a la sociedad día por día, es decir, hasta el día de la disolución.

5) Debe procederse a la liquidación de la sociedad conyugal:

1. Concepto: **(1)** conjunto de operaciones **(2)** que tienen por objeto establecer si existen o no gananciales, **(3)** y en caso afirmativo, partirlos por mitad entre los cónyuges, **(4)** reintegrar las recompensas que la sociedad adeude a los cónyuges o que éstos adeuden a la sociedad; **(5)** y reglamentar el pasivo de la sociedad.

2. Operaciones:

- 1) Facción de inventario de los bienes (Art. 1765 CC)
- 2) Tasación de los bienes.
- 3)
 - Formación del acervo común o bruto;
 - Retiro de los bienes propios y
 - Pago de los precios, saldos y recompensas.
- 4) Liquidación de las recompensas que recíprocamente se adeuden sociedad y cónyuges.
- 5) Reparto de los gananciales. Art. 1774 Regla general: Se dividen los gananciales por mitades entre los cónyuges.
Excepciones:
 - a) Si en las capitulaciones se estipuló un modo diferente de dividirlo.
 - b) Si alguno de los cónyuges incurre en la acción del 1768 pierde su porción en la cosa oculta o distraída.
 - c) Si la mujer renuncia a un porcentaje del activo.
 - d) Art. 1775 CC. No se imputa a los gananciales del cónyuge sobreviviente las asignaciones testamentarias que le haya hecho el cónyuge difunto. Salvo que el causante lo haya ordenado así, caso en el cual el sobreviviente podrá repudiarlas si prefiere esperar el resultado de la partición. (Ej.: si muere el marido y le correspondían 50 de gananciales pero hace testamento dejándole 25 a su mujer, los 25 se suman a los 50 que a ella le tocan por gananciales. No se completan los 50 con los 25).

6) División del pasivo social.

Rige el Principio de División de las deudas. Deben dividírselas por mitades. Esto se desprende del 1778 CC que hace responsable al marido por el total frente a los acreedores, pero deja a salvo su acción para cobrar a la mujer el reintegro de la mitad de estas deudas.

Este principio de división de las deudas se altera sí.

- a) Los cónyuges pactan otra forma de división.
- b) En el caso de ejercer el Beneficio de Emolumento de la mujer.
- c) Tratándose de deudas personales:
 - Si un cónyuge paga toda su propia deuda no tiene derecho a perseguir el reintegro de la mitad del otro.
 - Si uno paga toda la deuda del otro, puede exigirle el reintegro del total.

6.3.9. BENEFICIO DE EMOLUMENTO

A) Propiamente tal: Es el que goza la mujer por el art. 1777 CC, en virtud del cual no es responsable frente a terceros de las deudas de la sociedad sino hasta la concurrencia de su mitad de gananciales. No puede ser renunciado en las capitulaciones, pero nada impide que se renuncie después de la disolución.

Puede ser opuesto contra:

- Los terceros acreedores que la demande por un monto mayor a lo recibido por concepto de gananciales. Siempre como excepción.
- El marido sea como acción (por ejemplo, si ella paga más de lo que recibió por concepto de gananciales puede accionar por el reintegro contra el marido. Problema: ¿no habrá renuncia al beneficio? Sólo respecto del acreedor) o como excepción (Caso en que el marido la demanda por reintegro de una deuda que pagó él totalmente).

En consecuencia, este beneficio consiste en que la mujer no puede ser perseguida por un monto mayor al valor de lo que recibió por gananciales. No es que responda "con lo que recibió por gananciales", sino hasta el valor de ello: el valor fija el límite de su responsabilidad. Este beneficio no opera de pleno derecho, debe invocarse u oponerse.

REQUISITO fundamental para ello: Que la mujer pruebe el exceso de la contribución que se le exige sobre su mitad de gananciales, ya sea:

- Probar que no recibió gananciales.
- Probar que hubo gananciales pero lo demandado excede el valor de lo recibido.
- Probar que ya consumió el valor de los gananciales pagando una deuda de la sociedad.

Esto se acredita mediante el Inventario y Tasación o por otros documentos auténticos (públicos). Si el inventario es privado, sólo será oponible al acreedor que lo firmó.

Opera respecto de cualquier tipo de deudas, sean sociales o personales.
EXCEPTO:

1) Tratándose de deudas personales de la mujer: pueden ser perseguidas directamente contra ella y sobre todos sus bienes, sin que pueda excepcionarse.

2) Obligaciones indivisibles: ellas se cumplen íntegramente o no se cumplen, por lo tanto, si el acreedor demanda a la mujer puede hacerlo por el total de la obligación.

3) Obligaciones prendarias e hipotecarias: Se hacen efectivas en contra del cónyuge adjudicatario de la especie empeñada o hipotecada, de quien quiera sea la obligación que cauciona.

Si la mujer es demandada debe cumplir con el total del bien, pero si la obligación fuera social puede pedir reintegro por la mitad que le toca pagar al marido. Y si fuera obligación personal del marido, lo puede demandar por el total.

4) Cuando se ha pactado una forma de dividir las deudas diferente. Podría haberse hecho cargo la mujer del total de una deuda, caso en el cual no puede después invocar el beneficio.

B) Pequeño Beneficio de Emolumento: Es el que tiene el marido por las deudas que contrajo la mujer actuando bajo su Patrimonio Reservado.

6) La mujer que no hubiere renunciado a los gananciales en las capitulaciones matrimoniales puede hacerlo ahora:

Es un beneficio que la ley da a la mujer y que consiste en que no responde de las deudas sociales.

Art. 1781 CC. "Disuelta la sociedad, la mujer o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieron derecho.
--

1. Oportunidad: Puede hacerse en cualquier momento, desde que se disuelve la sociedad y mientras no ingrese ningún bien social al patrimonio de la mujer. El hecho de recibir bienes a título de gananciales importa la aceptación de éstos.

2. Características de la renuncia:

- a. Acto jurídico unilateral.
- b. Consensual.

c. Puro y simple.

d. Irrevocable. Pero se puede dejar sin efectos:

1. Si la mujer o herederos fueron inducidos a renunciar por engaño (nulidad relativa por dolo).
2. Si renunciaron por un justificable error acerca del verdadero estado de los negocios sociales (nulidad relativa por error).
3. Si renunciaron violentados por la fuerza (nulidad relativa por fuerza).
4. Si la renuncia se hizo en fraude de los acreedores del renunciante.

3. Forma de renunciar: la ley no da norma especial, así que puede ser en forma expresa o tácita.

4. Efectos de la renuncia:

a. Los derechos de la sociedad y el marido se confunden, aun respecto de los cónyuges (Art. 1783 CC). Consecuencias:

1. A la disolución, todos los bienes pertenecen al marido; no hay comunidad que liquidar.
2. La mujer no tiene derecho alguno en el haber social.
3. La mujer no responde de las deudas sociales.

b. Los bienes del patrimonio reservado le pertenecen a ella exclusivamente (Art. 150 inc. 7º CC), así como los frutos de los bienes que administra en virtud de los Arts. 166 y 167 CC.

c. La mujer conserva sus derechos y obligaciones a las recompensas e indemnizaciones (Art. 1784 CC).

5. Aceptación de los gananciales: la ley no da norma especial, así que puede ser en forma expresa o tácita.

❖ El derecho de los herederos a renunciar a los gananciales es divisible (Art. 1785 CC).

6.3.10. PATRIMONIO RESERVADO DE LA MUJER CASADA.

1. CONCEPTO: Son los que la mujer adquiere con su trabajo separado del marido, los que adquiere con ellos y los frutos de unos y otros. Se rigen por el Art. 150 CC.

Art. 150 CC. La mujer casada de cualquiera edad podrá **dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria.**

La mujer casada, que desempeñe algún empleo o que ejerza una profesión, oficio o industria, separados de los de su marido, se considerará separada de bienes respecto del ejercicio de ese empleo, oficio, profesión o industria y de lo que en ellos obtenga, no obstante cualquiera estipulación en contrario.

Incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros, el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Para este efecto podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley.

Los terceros que contraten con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que pudieren interponer ella o el marido, sus herederos o cesionarios, fundada en la circunstancia de haber obrado la mujer fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755, se haya acreditado por la mujer, mediante instrumentos públicos o privados, a los que se hará referencia en el instrumento que se otorgue al efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido.

Los actos o contratos celebrados por la mujer en esta administración separada, obligarán los bienes comprendidos en ella y los que administre con arreglo a las disposiciones de los artículos 166 y 167, y no obligarán los del marido sino con arreglo al artículo 161.

Los acreedores del marido no tendrán acción sobre los bienes que la mujer administre en virtud de este artículo, a menos que probaren que el contrato celebrado por él cedió en utilidad de la mujer o de la familia común.

Disuelta la sociedad conyugal, los bienes a que este artículo se refiere entrarán en **la partición de los gananciales**; a menos que la mujer o sus herederos renunciaren a estos últimos, en cuyo caso el marido no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada.

Si la mujer o sus herederos aceptaren los gananciales, el marido responderá a esas obligaciones hasta concurrencia del valor de la mitad de esos bienes que existan al disolverse la sociedad. Mas, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige con arreglo al artículo 1777.

2. CARACTERÍSTICAS:

- 1) Forman un patrimonio especial con activo y pasivo propios.
- 2) Constituyen un régimen especial de administrar un conjunto de bienes sociales. El hecho de que los administre la mujer no les quita el carácter de sociales.
- 3) Constituyen una protección que la ley otorga a la mujer que trabaja. Son privativos de la mujer.
- 4) Opera de pleno derecho.
- 5) Es una institución de orden público; la mujer no puede renunciar a tener un patrimonio reservado en las capitulaciones matrimoniales (Art. 1717 CC).

3. REQUISITOS:

- 1) Trabajo de la mujer: los bienes que adquiera por otro medio no ingresan a este patrimonio.
- 2) Trabajo remunerado.
- 3) Trabajo desarrollado durante la vigencia de la sociedad conyugal:
 - Si la mujer trabajaba antes, los bienes que adquirió no forman parte del patrimonio reservado.
 - Para determinar si un bien es reservado hay que atender al momento en que se presta el servicio.
 - Si la mujer se retira o jubila, el patrimonio no desaparece.
- 4) Trabajo separado de su marido: que no haya entre ellos una relación directa, personal y privada de colaboración y ayuda, aunque reciban una remuneración común.

❖ El marido no puede oponerse a que la mujer trabaje. El derecho de la mujer a ejercer una actividad separada del marido es un derecho absoluto.

4. ACTIVO:

- 1) Bienes provenientes del trabajo de la mujer: todas las remuneraciones obtenidas por la mujer en su trabajo.
- 2) Bienes que adquiere con el trabajo: esto es así aunque en la escritura de compra no se haga referencia a su trabajo (esa referencia tiene fines probatorios).
- 3) Frutos del producto del trabajo o de los bienes adquiridos con ese producto.

5. PASIVO (deudas que se pueden hacer efectivas en este patrimonio):

Provenientes de:

- 1) Actos y contratos celebrados por la mujer dentro de este patrimonio (Art. 150 inc. 5º CC).
 - 2) Actos y contratos celebrados por la mujer aunque actúe fuera de los bienes reservados (Art. 137 inc. 1º CC).
 - 3) Actos o contratos celebrados por la mujer respecto de un bien propio autorizada por la justicia por negativa del marido (Art. 138 bis CC).
 - 4) Obligaciones contraídas por el marido cuando se pruebe que el contrato cedió en utilidad de la mujer o de la familia común (Art. 150 inc. 6º CC).
- ❖ Las obligaciones personales de la mujer no se pueden hacer efectivas sobre el patrimonio reservado, salvo en el caso del Art. 137 inc. 1º CC.

6. CASOS EN QUE RESPONDEN BIENES AJENOS AL PATRIMONIO RESERVADO DE DEUDAS PROVENIENTES DE ESE PATRIMONIO:

- 1) Bienes del marido responden de la deuda (Art. 161 CC):
 - a) Cuando el marido ha accedido como fiador o de otro modo a las obligaciones contraídas por la mujer.
 - b) Cuando el marido ha obtenido un beneficio de las obligaciones contraídas por la mujer.
- 2) La mujer tiene bajo su administración bienes de acuerdo a arts. 166 y 167 CC.

7. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES RESERVADOS: la ejerce la mujer con amplias facultades;

- La ley la considera para estos efectos como separada de bienes.

8. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES RESERVADOS HECHA POR EL MARIDO:

- La mujer puede conferir mandato a su marido para que administre (Art. 162 CC).
- En caso de incapacidad por demencia o sordomudez de la mujer, el marido puede ser designado su curador y en ese carácter administra el patrimonio reservado.
- Si está interdicta por disipación, el marido no puede ser su curador.

9. PRUEBA DE LOS BIENES RESERVADOS:

Los terceros que contratan con la mujer no saben que tiene patrimonio reservado y por tanto van a exigir la intervención del marido para contratar con ella. Para evitar este problema el Art. 150 regula la prueba del patrimonio reservado en dos aspectos: en cuanto a la capacidad y en cuanto al dominio.

Esta prueba interesa a todos:

- Al marido porque los acreedores no se dirigirán contra él.
- A la mujer, porque se evita que el marido pretenda ejercer derechos que no le corresponde.
- A terceros, porque quedarán amparados de las alegaciones que ella o el marido intenten en determinados supuestos del art. 150 CC.

1º Prueba de la capacidad de la mujer (atiende a determinar si la mujer puede celebrar el contrato específico)

a) La mujer: Como la regla general es que la mujer casada en sociedad conyugal carece de facultades para administrar y disponer de sus bienes, ella deberá acreditar lo contrario, mediante cualquier medio de prueba. La prueba generalmente consistirá en documentos que acrediten la actividad separada del marido que ella realiza, como contratos, patentes, decretos, etc. El tercero no está obligado a conformarse con esta prueba y puede exigir otra más convincente.

b) El tercero: Puede verse obligado a producir esta prueba en el evento que la mujer o el marido pretendan desconocer la validez de los contratos que ella celebró. Frente a esto la ley lo ampara con una presunción de derecho si se cumplen las siguientes condiciones:

- i. Que el bien objeto del contrato no sea un bien propio de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie (O sea que no sea del art. 1754 y 1755)

- ii. Que la mujer ejerza una industria u oficio separado de su marido, lo que debe acreditar mediante instrumento público o privado (la ley limita el medio de prueba para hacer aplicable la presunción).
- iii. Que el acto o contrato se otorgue por escrito y en dicho contrato se haga referencia al instrumento referido anteriormente.

2º Prueba del dominio (Se refiere a acreditar la calidad de reservado del bien que es objeto del contrato)

De conformidad al art. 150 inc. 3º incumbe a la mujer acreditar frente al marido y frente a terceros el origen y dominio de los bienes adquiridos en virtud del artículo 150, pudiendo hacerlo mediante todos los medios de prueba legales. Ex: No es admisible la confesión de los cónyuges (Por aplicación del art. 1739)

10. SUERTE DE LOS BIENES A LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL:

1) Si la mujer o sus herederos aceptan los gananciales:

- Los bienes reservados entran a formar parte de los gananciales.
- En este caso, el marido tiene un verdadero derecho de emolumento, pues sólo responde hasta el valor de la mitad de esos bienes.

2) La mujer o sus herederos renuncian a los gananciales:

- i) Los bienes reservados no entran a los gananciales.
- ii) El marido no responde por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada.
- iii) Los acreedores del marido o de la sociedad no pueden perseguir los bienes reservados, salvo que prueben que la obligación contraída por el marido cedió en utilidad de la mujer o de la familia común.

6.3.11. MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LA MUJER CASADA EN SOCIEDAD CONYUGAL FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL MARIDO.

- 1)** Renuncia a los gananciales.
- 2)** Autorización de la mujer para actos de administración del marido.
- 3)** Recompensas.
- 4)** Separación judicial.
- 5)** Beneficio de emolumento.
- 6)** Patrimonio reservado.

- 7) Suspensión de la prescripción a favor de la mujer casada en sociedad conyugal, mientras dure esta.

6.3.12. PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA SOCIEDAD CONYUGAL.

1. Estado del proyecto.

El proyecto fue ingresado en junio de 2011 y actualmente está en el segundo trámite constitucional en el Senado.

2. Principios¹⁸.

El proyecto de ley se basa en tres principios: (i) igualdad ante la ley de marido y mujer, (ii) plena capacidad de ambos cónyuges –marido y mujer son plenamente capaces- y (iii) protección económica del cónyuge que se ha dedicado al cuidado de los hijos o del hogar o que ha trabajado en menor medida de lo que hubiese querido o podido por estas causas.

3. Objetivos principales.

1. Reconocer la plena capacidad de la mujer de desempeñar funciones y la igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, reconocida en nuestra Constitución.

Para esto, se faculta a la mujer casada bajo sociedad conyugal para administrar la sociedad conyugal y sus bienes propios.

- Respecto de la administración de la sociedad conyugal: se elimina la concepción del marido como el jefe de la sociedad conyugal y ésta podrá ser administrada por marido o mujer, a elección de ellos. Solo a falta de acuerdo, la administración será ejercida conjuntamente entre ambos.
- Respecto de los bienes propios: que cada uno de los cónyuges administre sus bienes

propios, eliminado la administración que hoy tiene el marido de los de la mujer.

2. Dejar a la sociedad conyugal como régimen legal matrimonial supletorio.

- Es un régimen que reconoce el valor que significa -para el matrimonio y para el desarrollo profesional del otro cónyuge- el aporte de quién más tiempo destina al cuidado de los hijos y del hogar.
- Es un régimen que protege a ese cónyuge que más tiempo ha dedicado al cuidado de los hijos y del hogar (que es por lo general es la mujer), mediante el derecho a la mitad de lo ganado durante el matrimonio.

3. Mantener las protecciones a la mujer.

- Faculta a la mujer a administrar la sociedad conyugal.
- Faculta a la mujer a administrar sus bienes propios.

¹⁸ Ver apartado sobre los principios del derecho de familia, en el capítulo 1

- Aumenta la cantidad de bienes propios y que por lo tanto administra, ya que el actual haber relativo pasa a ser propio y administrado por cada cónyuge separadamente.
- Se mantiene como única titular del patrimonio reservado, en caso de administración del marido.
- Se establece la administración extraordinaria provisoria en caso de ausencia o incapacidad del cónyuge administrador, a fin de que se pueda disponer de bienes para satisfacer las necesidades de la familia.

Todas estas facultades (salvo la existencia del patrimonio reservado) son para el cónyuge no administrador o administrador en su caso, por lo que el marido también las tiene. Esto, en cuanto el proyecto siempre vela por la igualdad de derechos entre ambos, pero protegiendo a quién más tiempo ha dedicado al cuidado de los hijos y del hogar.

4. Aumentar los bienes que administra cada cónyuge: se elimina el haber relativo de la sociedad conyugal (el dinero o bienes muebles que tienen antes del matrimonio o que adquieren a título gratuito durante su vigencia, entre otros), pasando los bienes que lo componen a ser propios de cada cónyuge y así administrados por ellos y no exclusivamente por el marido, como es en la actual legislación.

5. Facultar al cónyuge no administrador a disponer de bienes en caso de urgencia: en caso de ausencia o incapacidad del administrador, el cónyuge no administrador pueda disponer de bienes para cubrir las necesidades de la familia común, mediante la administración extraordinaria provisoria.

6.4. PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES

1. Concepto.

El régimen de participación en los gananciales es una fórmula ecléctica entre el régimen de sociedad conyugal y el de separación de bienes, que concilia dos aspectos fundamentales del matrimonio:

- a) La comunidad de intereses que implica la vida matrimonial.
- b) El respeto de la personalidad individual de cada cónyuge.

2. Momentos en que se puede convenir este régimen.

- 1) En las capitulaciones matrimoniales que se celebren antes del matrimonio.
- 2) En las capitulaciones matrimoniales que se celebren al momento del matrimonio.
- 3) Mediante el pacto del Art. 1723 CC, durante la vigencia del matrimonio.

3. Variantes del régimen de participación en los gananciales.

	Sistema de comunidad	Sistema crediticio (o con compensación de beneficios)
RÉGIMEN VIGENTE	Cada cónyuge tiene su propio patrimonio, que administra con libertad.	Cada cónyuge tiene su propio patrimonio, que administra con libertad.
EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN	Se forma una comunidad respecto de los bienes que cada uno adquirió durante el matrimonio a título oneroso.	El cónyuge que ha adquirido bienes a título oneroso por menos valor, tiene un crédito de participación en contra del otro cónyuge.
DIVISIÓN	La comunidad se divide por partes iguales.	No se produce comunidad.

4. Características del sistema chileno.

Se acoge la variante crediticia (Art. 1792-19 inc. 3º CC). Ley 19.335 sobre Régimen de Participación en los Gananciales (23/09/1994).

- 1) Régimen alternativo a la sociedad conyugal y la separación de bienes.
- 2) Convencional.
- 3) Variante crediticia.

5. Funcionamiento durante la vigencia del régimen.

Cada cónyuge es dueño de sus bienes, que administra con libertad. Limitaciones:

- 1) Ninguno de ellos puede otorgar cauciones personales a obligaciones de terceros sin el consentimiento del otro cónyuge (Art. 1792-3 CC).
- 2) Si un bien es declarado bien familiar, el cónyuge propietario no puede enajenarlo sin la autorización del otro cónyuge, o del juez (Art. 1792-3 CC).

Si se incumplen, la sanción es la nulidad relativa (Art. 1792-4 CC).

6.4.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A LA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN

1) GANANCIALES:

Diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge (Art. 1792-6 inc. 1º CC).

2) PATRIMONIO ORIGINARIO:

Es el patrimonio existente al momento de optar por el régimen (Art. 1792-6 inc. 2º).

1) DETERMINACIÓN:

- i) Se deducen del activo de los bienes que el cónyuge tiene al inicio del régimen, las obligaciones de que sea deudor en esa misma fecha (Art. 1792-7 CC).
- ii) Se agregan las adquisiciones a título gratuito efectuadas durante la vigencia del régimen (Art. 1792-7 inc. 2º CC).
- iii) Se agregan las adquisiciones a título oneroso hechas durante la vigencia del régimen, si la causa o título de la adquisición es anterior al inicio del régimen (Art. 1792-8 CC, que contiene una enumeración no taxativa de casos, que reproduce con leves modificaciones la del Art. 1736 CC).
- iv) No integran el patrimonio originario (1) los frutos de los bienes originarios, (2) las minas denunciadas por uno de los cónyuges, (3) ni las donaciones remuneratorias por servicios que dan acción (Art. 1792-9 CC).
- v) Adquisiciones hechas en común:
 - Las adquisiciones hechas en común por ambos cónyuges, a título oneroso, generan una comunidad entre ellos.
 - Si es a título gratuito, los derechos se agregan a los respectivos patrimonios originarios en la proporción que establezca el título respectivo (Art. 1792-10 CC).

2) OBLIGACIÓN DE PRACTICAR INVENTARIO (Art. 1792-11 CC):

Deben realizar inventario simple de los bienes que componen el patrimonio originario, al momento de pactar el régimen.

A falta de inventario, el patrimonio originario puede probarse por otros instrumentos, o en último caso, otros medios de prueba.

3) VALORIZACIÓN DEL ACTIVO ORIGINARIO (Art. 1792-13 CC):

- i) Forma: según su estado al momento de entrar en vigencia el régimen, prudencialmente actualizado a la fecha de la terminación del régimen.
- ii) Quién la práctica: los cónyuges o un tercero designado por ellos. En subsidio, el juez.

3) PATRIMONIO FINAL:

Es el patrimonio existente al término del régimen (Art. 1792-6 inc. 2º CC).

1) DETERMINACIÓN:

- i) Se deduce del valor total de los bienes que el cónyuge sea dueño al término del régimen, el valor total de las obligaciones que tenga en esa misma fecha (Art. 1792-14 CC).
- ii) Se agregan imaginariamente los montos de las disminuciones del activo que sean consecuencia de los siguientes actos ejecutados, durante la vigencia del régimen, sin autorización del otro cónyuge (Art. 1792-15 CC):
 - a. Donaciones irrevocables que no corresponden al cumplimiento proporcionado de deberes morales o usos sociales.
 - b. Cualquier especie de actos fraudulentos o de dilapidación en perjuicio del otro cónyuge.
 - c. Pago de precios de rentas vitalicias u otros gastos que persigan asegurar una renta futura al cónyuge que ha incurrido en ellos.

2) INVENTARIO VALORADO DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO FINAL (ART. 1792-16 CC):

- Cada cónyuge debe proporcionárselo al otro, dentro de los 3 meses siguientes al término del régimen.
- El inventario será normalmente simple.

3) AVALUACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO DEL PATRIMONIO FINAL (Art. 1792-17 CC):

- i) Forma: según su estado al momento de la terminación del régimen.
- ii) Quién la práctica: mismas reglas del patrimonio originario.

4) SANCIÓN AL CÓNYUGE QUE OCULTA O DISTRAE BIENES O SIMULA OBLIGACIONES CON EL FIN DE DISMINUIR LOS GANANCIALES (ART. 1792-18 CC):

Se suma a su patrimonio final el doble del valor de lo ocultado o simulado.

SITUACIONES QUE SE SIGUEN AL EXISTIR DIFERENCIAS ENTRE EL PATRIMONIO ORIGINARIO Y EL PATRIMONIO FINAL (ART. 1792-19 CC).

1) Que el patrimonio final de un cónyuge sea inferior al originario: sólo él soporta la pérdida.

2) Que sólo uno de los cónyuges haya obtenido gananciales: el otro participa de la mitad.

3) Que ambos hayan logrado gananciales: se compensan hasta concurrencia de los de menor valor y aquel que haya obtenido menores gananciales tiene derecho a que el otro le pague, a título de participación, la mitad del excedente.

6.4.2 DEL CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN

a) CONCEPTO:

Es (1) el que la ley otorga al cónyuge que, a la expiración del régimen de participación en los gananciales, ha obtenido gananciales por un monto inferior a los del otro cónyuge, (2) con el objeto de que este último le pague, en dinero efectivo, a título de participación, la mitad del exceso.

b) CARACTERÍSTICAS:

- 1) Se origina al término del régimen (Art. 1792-20 CC). Su determinación resulta una vez que se liquidan los gananciales, lo que se debe demandar en juicio sumario.
- 2) Durante la vigencia del régimen, es eventual. Por ello es inenajenable e irrenunciable (Art. 1792-20 inc. 2º CC).
- 3) Es puro y simple (Art. 1792-21 CC):
 - Determinado el crédito, el cónyuge beneficiado puede pedir el pago de inmediato.
 - Excepción: si ello causa grave perjuicio al cónyuge deudor o a los hijos comunes, el juez puede conceder plazo de hasta 1 año para el pago.
- 4) Se paga en dinero, pero nada obsta a que los cónyuges acuerden lo contrario (Art. 1792-22 CC).
- 5) Goza de preferencia de cuarta clase (Art. 2481 Nº 3 CC).
- 6) No constituye renta.

c) PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR EL PAGO DEL CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN:

El Art. 1792-26 CC establece que la acción para pedir la liquidación prescribe en 5 años contados desde la extinción del régimen, pero no da normas sobre el plazo de la acción para cobrar el crédito. En consecuencia, se aplican las reglas generales.

d) BIENES SOBRE LOS CUALES SE PUEDE HACER EFECTIVO EL CRÉDITO (ART. 1792-24 CC):

El cónyuge acreedor debe perseguir primero el dinero del deudor. Si es insuficiente, los muebles, y en subsidio los inmuebles.

e) INSUFICIENCIA DEL CÓNYUGE DEUDOR (ART. 1792-24 INC. 2º CC):

El acreedor puede perseguir su crédito en los bienes donados entre vivos sin su consentimiento (acción de inoficiosa donación) o enajenados en fraude de sus derechos (acción pauliana).

f) LOS CRÉDITOS DE TERCEROS, ANTERIORES A LA EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN, PREFIEREN AL CRÉDITO DE PARTICIPACIÓN (Art. 1792-25 CC).

g) RELACIÓN ENTRE EL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES Y LOS BIENES FAMILIARES (ART. 1792-23 CC):

Para determinar los créditos, las atribuciones de derechos sobre bienes familiares efectuadas a uno de los cónyuges deben ser valoradas prudencialmente por el juez.

6.4.3 EXTINCIÓN DEL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES (ART. 1792-27 CC).

- 1) Muerte de uno de los cónyuges.
- 2) Presunción de muerte de uno de los cónyuges (con el decreto de posesión provisoria, salvo que no haya, caso en que será con el de posesión definitiva).
- 3) Declaración de nulidad del matrimonio o sentencia de divorcio (respecto de la nulidad, sólo se extingue si el matrimonio era putativo; si no, no hubo régimen).
- 4) Separación judicial de los cónyuges (como el matrimonio se mantiene, es necesario un régimen: separación de bienes).
- 5) Sentencia que declare la separación de bienes.
- 6) Pacto de separación de bienes.

6.5. SEPARACIÓN DE BIENES

1. Concepto.

Art. 152 CC. "Separación de bienes (1) es la que se efectúa sin separación judicial, (2) en virtud de decreto de tribunal competente, por disposición de la ley o por convención de las partes."

Este régimen se caracteriza porque cada cónyuge tiene su propio patrimonio, que administra con absoluta libertad (Art. 159 CC).

2. Clases de separación de bienes.

1. Separación de bienes legal.
2. Separación de bienes judicial.
3. Separación de bienes convencional.

6.5.1. SEPARACIÓN DE BIENES LEGAL.

1) TOTAL:

i) Sentencia de separación judicial:

- Es un caso de separación legal porque, aunque hay una sentencia judicial, los cónyuges han litigado sobre otra materia.

- El matrimonio subsiste, debe existir un régimen matrimonial, que no puede ser otro que el de separación de bienes (Art. 173 CC).
- La separación legal de bienes es irrevocable, y no puede quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial (Art. 165 inc. 1º CC).
- En este caso, aunque la ley no lo diga, se aplican los Arts. 161, 162 y 163 CC:
 - Los acreedores de la mujer sólo pueden dirigirse sobre sus bienes. El marido responde sólo cuando:
 - Se obliga como codeudor conjunto, solidario o subsidiario de la mujer.
 - Las obligaciones de la mujer ceden en su beneficio o de la familia común.
 - Los acreedores del marido sólo pueden dirigirse sobre los bienes de éste, con las mismas excepciones.
 - Si la mujer confiere poder a su marido para que administre parte de sus bienes, el marido es obligado como simple mandatario.
 - A los cónyuges se les da un curador para la administración de sus bienes en todos los casos en que siendo solteros necesitarían de un curador, pero por tratarse de separación total, no pueden ser curadores el uno del otro.

ii) Personas casadas en el extranjero:

Se miran como separadas de bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago, y pacten sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales (Art. 135 inc. 2º CC).

- Este es el único caso en que la sociedad conyugal puede comenzar con posterioridad al matrimonio.
- Además, es excepcional en cuanto se trata de una sociedad conyugal convenida.
- En esta situación, el régimen que se elija sólo opera hacia el futuro.

2) PARCIAL:

i) Patrimonio reservado de la mujer del Art. 150 CC.

ii) Separación legal parcial de Art. 166 CC:

Se refiere a los bienes que adquiere la mujer por haber aceptado una donación, herencia o legado que se le hizo con la condición precisa de que no los administre el marido.

Respecto de ellos, la mujer se considera separada de bienes:

1. Tiene las mismas facultades que la separada judicialmente: administra con independencia del marido.
2. Ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades.
3. Los actos que la mujer celebre sólo dan acción sobre los bienes que componen este patrimonio, sin que tenga responsabilidad el marido, a menos que:
 - Se haya obligado conjunta, solidaria o subsidiariamente con la mujer.
 - Se haya beneficiado la familia común.
4. Los acreedores del marido no pueden dirigirse en contra de estos bienes, a menos que prueben que el contrato cedió en utilidad de la mujer o de la familia.
5. Estos bienes responden en caso de que la mujer realice un acto respecto de un bien propio, autorizada por la justicia.
6. Si la mujer confiere al marido la administración de una parte de estos bienes, responde como simple administrador.
7. Si la mujer es incapaz, se le da un curador para que administre, que puede ser el marido.
8. Los frutos producidos por estos bienes y todo lo que con ellos adquiera pertenece a la mujer, pero disuelta la sociedad conyugal, ingresan a los gananciales, a menos que la mujer renuncie a los gananciales.

6.5.2. SEPARACIÓN DE BIENES JUDICIAL.

1) Características:

1. Sólo puede demandarla la mujer (Excepto caso Art. 19 Ley 14.908)
2. La facultad de pedirla es irrenunciable e imprescriptible (Art. 153 CC).
3. Sólo opera por las causales taxativamente señaladas en la ley.
4. Es siempre total.
5. Es irrevocable (Art. 165 CC).

2) Causales:

- 1.** Interdicción o larga ausencia del marido, si la mujer no quiere tomar sobre sí la administración extraordinaria de la sociedad conyugal ni someterse a un curador (Art. 1762 CC).

2. Cónyuge condenado a pagar una pensión de alimentos al otro cónyuge o a los hijos comunes, que ha sido apremiado dos veces (Art. 19 Ley 14.908). Este es el único caso en que la puede pedir el marido.

3. Insolvencia del marido (Art. 155 inc. 1º CC).

4. Administración fraudulenta del marido (Art. 155 inc. 1º CC).

5. Mal estado de los negocios del marido, producto de especulaciones aventuradas o de una administración errónea o descuidada (Art. 155 inc. 4º CC). Incluso se puede pedir si existe riesgo inminente de ello (Art. 155 inc. final CC), pero el marido puede oponerse a la separación prestando garantías que aseguren suficientemente los intereses de la mujer.

6. Incumplimiento culpable del marido de las obligaciones que le imponen los Arts. 131 y 134 CC (Art. 155 inc. 2º CC): fidelidad, socorro, ayuda mutua, protección y respeto, y proveer a las necesidades de la familia común.

7. Marido que incurre en alguna causal de separación judicial (Art. 155 inc. 2º CC).

8. Ausencia injustificada del marido por más de un año (Art. 155 inc. 3º CC).

9. Separación de hecho por un año o más (Art. 155 inc. 3º CC), sin importar los motivos o quién tiene la responsabilidad en la separación.

3) Medidas precautorias en favor de la mujer: demandada la separación de bienes, el juez puede, a petición de la mujer, tomar las providencias que estime conducentes a la seguridad de sus intereses, mientras dure el juicio (Art. 156 CC).

4) Efectos:

Produce efectos sólo hacia el futuro, y debe inscribirse al margen de la inscripción matrimonial para que afecte a terceros.

1. Produce la disolución de la sociedad conyugal o régimen de participación en los gananciales.

2. Cada cónyuge administra con plena independencia los bienes que tenía antes del matrimonio y los que adquieran durante éste a cualquier título. Comprende lo obtenido como producto de la liquidación del régimen.

3. La mujer debe concurrir a proveer a las necesidades de la familia común en proporción a sus facultades.

4. Los acreedores de la mujer sólo tienen acción sobre sus bienes, no sobre los del marido, salvo que:

1. Él se haya obligado conjunta, solidaria o subsidiariamente con la mujer.
2. El acto le haya reportado un beneficio a él o a la familia común.

5. Si la mujer le da poder al marido para administrar una parte de sus bienes, se obliga como simple mandatario.

6. Si la mujer es incapaz, se le debe dar un curador, que no puede ser el marido.

7. Una vez decretada la separación, es irrevocable.

6.5.3 SEPARACIÓN DE BIENES CONVENCIONAL

1) Momentos en que se puede acordar:

1. En las capitulaciones matrimoniales celebradas ante del matrimonio. En este caso, la separación puede ser total o parcial.
2. En las capitulaciones matrimoniales celebradas en el acto del matrimonio. En este caso, sólo puede ser total.
3. Durante el matrimonio, por el pacto del Art. 1723 CC pueden los cónyuges mayores de edad pactar la separación total.

2) Efectos:

Los mismos que en la judicial, pero el marido puede ser curador de la mujer. Además, en este caso los cónyuges pueden pactar la separación en los gananciales, lo que no se puede hacer en la separación judicial.

CAPÍTULO 7. BIENES FAMILIARES

7.1. CUESTIONES GENERALES.

1. Fundamento de la institución

Persigue asegurar a la familia un hogar físico estable donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con normalidad, aun después de disuelto el matrimonio.

La declaración de bien familiar presupone la existencia del matrimonio o de acuerdo de unión civil según lo dispuesto en el art. 15, inciso final de la ley 20.830 que establece que "cualquiera sea el régimen de bienes que exista entre los convivientes civiles tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 141 a 149 del Código Civil".

De esta forma, lo que dice del matrimonio opera de igual forma respecto de los convivientes civiles.

- Disuelto el matrimonio o el acuerdo de unión civil, no se puede pedir que se declare un bien como familiar.
- Pero si vigente el matrimonio o el acuerdo de unión civil, y se declaró un bien como familiar, el hecho de que el matrimonio se extinga no produce la desafectación de pleno derecho.

2. Ámbito de aplicación.

Los bienes familiares tienen cabida cualquiera sea el régimen matrimonial (Art. 141 inc. 1º CC). Sus normas son de orden público, por lo que la voluntad de los cónyuges no las puede modificar o derogar (Art. 149 CC).

3. Bienes que pueden ser declarados familiares.

1. Inmueble de propiedad de uno o de ambos cónyuges, que sirva de residencia principal a la familia (Art. 141 CC).

2. Muebles que guarnecen el hogar (Art. 141 CC), entendidos en general por la doctrina como aquellos señalados en el Art. 574 CC). Estos bienes pueden ser declarados como familiares siempre que sean de propiedad de uno o ambos cónyuges, aunque la familia tenga su hogar en un inmueble arrendado.

3. Derechos o acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias del inmueble que sea residencia principal de la familia (Art. 146 CC)

7.2. FORMA DE CONSTITUIR UN BIEN COMO FAMILIAR.

1. Inmueble de propiedad de uno de los cónyuges:

La declaración la hace el juez:

Desde el año 2004, es competencia de los Juzgados de Familia (Art. 8, nº14, letra b de la ley nº19.968 que crea los tribunales de Familia) y el procedimiento a seguir es el siguiente:

- 1) demanda de alguno de los cónyuges (frecuentemente será el no propietario)
- 2) Citación a audiencia preparatoria, en la cual el juez resolverá en la misma audiencia, salvo:
 - A) haya oposición
 - B) considere que faltan antecedentes para resolver; caso en que cita a audiencia de juicio.

Constitución provisoria De todas maneras se mantiene la declaración provisoria de bien familiar. El juez, de oficio, ordenará al CBR respectivo que realice la sub-inscripción necesaria al margen de la inscripción respectiva con el objetivo de que se haga oponible a terceros, inscripción que se llevará a cabo con el solo mérito del decreto.

2. Muebles que guarnecen el hogar:

La ley no prevé el caso de que la declaración recaiga sólo sobre estos muebles. Se concluye que debe hacerse igual que en el caso anterior, pero atendida la naturaleza de estos bienes, no procede inscripción alguna.

3. Acciones y derechos del cónyuge en la sociedad propietaria del inmueble:

Se hace por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública. Debe:

- anotarse al margen de la inscripción social respectiva (si la hay), si se trata de una sociedad de personas,
- o inscribirse en el registro de accionistas, si es una S.A. (Art. 146 inc. 3º CC).

7.3. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE UN BIEN COMO FAMILIAR.

No lo transforma en inembargable, sino que se producen los siguientes efectos:

1) Se limita la facultad de disposición del propietario.

2) Otorga al cónyuge en cuyo favor se hace la declaración, un beneficio de excusión.

1) LIMITACIÓN A LA FACULTAD DE DISPOSICIÓN.

1. Inmueble que sirva de residencia a la familia o muebles que guarnecen el hogar:

No se puede:

(1) enajenar o (2) gravar voluntariamente, (3) ni prometer gravar o enajenar, (4) ni celebrar contratos de arrendamiento, comodato o cualquiera que conceda derechos personales de uso o goce sobre ellos, sino con la autorización del cónyuge no propietario (Art. 142 inc. 1º CC).

2. Acciones o derechos sobre la sociedad propietaria:

Se requiere la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista, que tenga relación con el bien familiar (Art. 146 inc. 2º CC). Además, no puede disponer de los derechos o acciones en la sociedad sino con autorización del otro cónyuge.

- **Autorización del cónyuge no propietario.**

- a) Forma como se presta:

- Debe ser específica y otorgada por escrito,
 - o por escritura pública si el acto requiere esa solemnidad,
 - o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo.
 - Puede prestarse por mandato especial y solemne (Art. 142 inc. 2º CC).

- b) Autorización judicial subsidiaria:

La voluntad del cónyuge puede ser suplida por el juez en caso de:

- Imposibilidad.
 - Negativa que no se funde en el interés de la familia (Art. 144 CC).
 - Esta disposición se refiere sólo al Art. 142 CC (bienes inmuebles y muebles), no al Art. 146 CC (derechos y acciones).

- **Sanción para el caso de que se realicen estos actos sin la autorización del cónyuge.**

La sanción es la nulidad relativa; el titular es el cónyuge no propietario (Art. 143 inc. 1º CC).

En cuanto a los terceros adquirentes del bien familiar, se los considera de mala fe para efectos de las obligaciones restitutorias que la declaración de nulidad origine (Art. 143 inc. 2º CC). Esta es una presunción de derecho que rige sólo para los inmuebles, porque respecto de los muebles no hay inscripción.

2) BENEFICIO DE EXCUSIÓN EN FAVOR DEL CÓNYUGE BENEFICIADO CON LA DECLARACIÓN DE BIEN FAMILIAR.

Este cónyuge puede exigir que, antes de proceder contra los bienes familiares, se persiga el crédito en otros bienes del deudor (Art. 148 CC). Para que pueda plantear este beneficio, se le debe notificar el mandamiento de ejecución.

Por otro lado, durante el matrimonio, el juez puede constituir derechos de usufructo, uso o habitación a favor del cónyuge no propietario, teniendo en cuenta en su constitución y duración, el interés de los hijos y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges (Art. 147 CC). El título de estos derechos reales lo constituye la resolución judicial, que debe inscribirse en el registro de Hipotecas y Gravámenes.

- La sentencia debe determinar plazo de término.
- La sentencia puede establecer otras obligaciones y modalidades si así parece equitativo.
- Estos gravámenes no pueden afectar los derechos de los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha de su constitución.
- No aprovechan a los acreedores del cónyuge en cuyo favor se constituyen estos derechos, es decir, son inembargables y los acreedores no pueden subrogarse en su ejercicio.
- Estos gravámenes no son propiamente una obligación alimenticia, pero tienen una naturaleza alimenticia, porque el juez debe considerar las fuerzas patrimoniales al determinarlo, y los acreedores del cónyuge beneficiado no los puede embargar.

7.4. DESAFECTACIÓN DEL BIEN FAMILIAR.

a) Acuerdo de los cónyuges (Art. 145 inc. 1º CC):

- Si se trata de un inmueble, debe constar por escritura pública y anotarse al margen de la inscripción respectiva.
- No se dice nada respecto de las acciones y derechos.

b) Resolución judicial recaída en juicio seguido por el cónyuge propietario en contra del no propietario, fundado en que el bien no está destinado a los fines que indica el Art. 141 CC (Art. 145 inc. 2º CC).

c) Resolución judicial cuando el matrimonio ha sido declarado nulo, o ha terminado por la muerte de alguno de los cónyuges o por divorcio (Art. 145 inc. 3º CC).

d) Enajenación voluntaria o forzada del bien familiar.

CAPÍTULO 8. FILIACIÓN.

8.1. ASPECTOS GENERALES.

1. Concepto.

Es la relación de descendencia entre dos personas, una de la cuales es padre o madre de la otra.

El fundamento de toda filiación es el vínculo de sangre existente entre el padre y el hijo, proveniente de las relaciones sexuales de los padres. Excepción: filiación adoptiva.

2. Ideas centrales de las reformas introducidas por la ley 19.585.

a) Derecho de toda persona a conocer sus orígenes (derecho a la identidad): toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus padres. Para ello, la ley asegura una amplia investigación de la paternidad y maternidad.

b) Trato igualitario a todos los hijos, Art. 33 CC: todos los hijos tienen los mismos derechos, con lo que se cumple el mandato del Art. 1º inc. 1º CPR.

c) Prioridad del interés del hijo:

Art. 222 inc. 2º CC. "La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades."

8.2. CLASES DE FILIACIÓN.

1. Filiación por naturaleza. (Art. 179 inc. 1º CC).

1) FILIACIÓN DETERMINADA: es aquella que tiene reconocimiento jurídico, sea respecto de ambos padres, sea respecto de uno de ellos. La filiación puede entonces estar determinada respecto del padre, de la madre o de ambos.

- i) Matrimonial.
- ii) No matrimonial.
- iii) Por fecundación mediante aplicación de técnicas de reproducción asistida.

Art. 182 CC. "El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas. No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente, ni reclamarse una distinta."

2) FILIACIÓN NO DETERMINADA: es aquella que, a pesar de existir en la realidad, no ha sido reconocida por el derecho.

2. Filiación Adoptiva. (Art. 179 inc. 2º CC).

Se rigen por la ley respectiva. Actualmente, es la ley 19.620.

- Pero los adoptantes y adoptados anteriores de esa ley siguen sujetos a la ley conforme a la cual se realizó la adopción (Ley 7.613 o Ley 18.703).
- Fuera de estos casos, no existe propiamente filiación adoptiva, porque de acuerdo al Art. 37 Ley 19.620, la adopción confiere al adoptado el estado civil de hijo, extinguiendo los vínculos de filiación de origen.

8.3 DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN.

8.3.1 DETERMINACIÓN DE LA MATERNIDAD

De acuerdo al Art. 183 CC, hay 3 formas de determinar la maternidad:

a) Por el parto:

Art. 183 inc. 1º CC. "La maternidad queda determinada legalmente por el parto, cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz constan en las partidas del Registro Civil."

a) Cuando conste el hecho del parto, la identidad del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz en las partidas del registro civil (art 183 CC), esto es, que efectivamente ésta es la mujer que ha parido y que efectivamente ése es el hijo que ha dado a luz. Para que esto conste en las partidas se debe llevar el certificado de la matrona o médico que asistió al parto, o bien la declaración de dos testigos conocidos.

b) Esta forma de determinación de la maternidad opera por el sólo ministerio de la ley y no requiere del consentimiento de la mujer, no tiene que haber una especie de reconocimiento (art 31 nº 4 LRC). La ley está privilegiando el derecho a la identidad y el interés superior del menor frente a, por ejemplo, la honra de la mujer.

c) De acuerdo al art 183 CC madre es la que ha tenido el parto. En Chile no existe lo que en el derecho comparado se conoce como maternidad subrogada (arrendamiento del vientre).

b) Por el reconocimiento de la madre.

c) Por sentencia judicial firme recaída en un juicio de filiación.

En estos dos casos se aplican las mismas reglas que para la determinación de la paternidad.

8.3.2. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN MATRIMONIAL.

Se produce en los siguientes casos (Art. 180 y 185 CC):

- 1) Cuando al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo exista matrimonio entre los padres.
- 2) Cuando con posterioridad al nacimiento del hijo, los padres contraen matrimonio entre sí, siempre que a la fecha del matrimonio la paternidad y maternidad hayan estado previamente determinadas por los medios que el CC establece.
- 3) Cuando los padres han reconocido al hijo en el acto del matrimonio o durante su vigencia, en el caso de que no haya estado determinada previamente la filiación.
- 4) Cuando una sentencia judicial dictada en juicio de filiación así lo establezca, en el caso de que los padres contraigan matrimonio pero no reconozcan al hijo.

Presunción de paternidad (Art. 184 CC)¹⁹:

Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges.

Sin embargo, la presunción no rige respecto de los hijos nacidos dentro de los 180 días siguientes al matrimonio, si (1) el marido se casó sin saber que la mujer estaba embarazada y (2) desconoce judicialmente su paternidad.

Excepcionalmente, rige la presunción para los hijos nacidos después de los 300 días siguientes a la disolución o separación, por el hecho de consignarse como padre el nombre del marido, a petición de ambos cónyuges, en la inscripción de nacimiento del hijo. Esto implica un reconocimiento.

En todo caso, la paternidad así determinada o desconocida puede ser impugnada o reclamada mediante las acciones de filiación.

8.3.3. DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN NO MATRIMONIAL.

Hay dos formas (Art. 186 CC):

a) Reconocimiento voluntario de los padres.

b) Reconocimiento forzado mediante sentencia judicial recaída en un juicio de filiación.

¹⁹ El artículo 21 de la ley 20.830, establece que “para efectos de la presunción de paternidad, en caso de convivientes civiles de distinto sexo se estará a las normas que la regulan en el artículo 184 del Código Civil”. De esta manera, **en el acuerdo de unión civil, asimismo, se presumen la paternidad del conviviente civil.**

8.4. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO.

1. Concepto de reconocimiento:

Es un acto jurídico de familia, por medio del cual una persona afirma ser padre o madre de otra cuya paternidad o maternidad no se encuentra determinada y que, cumpliendo con los requisitos y formas que prescribe la ley, tiene la eficacia de determinar la paternidad o maternidad.

2. Características del reconocimiento:

1) Es un acto jurídico unilateral, no se requiere el consentimiento de ambos progenitores para reconocer a un hijo, sin perjuicio de que ambos puedan reconocerlo.

Si el reconocimiento fuera sólo del padre o madre, aquel progenitor que lo reconoce no está obligado a señalar de quién es hijo.

2) Para reconocer no se requiere probar la veracidad del vínculo biológico. Aquí la ley se parta del principio de privilegiar la verdad biológica por sobre la verdad formal, en beneficio del interés superior del niño y de si derecho a tener una identidad.

3) Al ser un acto jurídico de familia tiene que cumplir con todos los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos, por tanto, su ineficacia habrá de regirse por las reglas generales, con la sola diferencia de que tratándose de la acción de nulidad por un vicio en el consentimiento, ella prescribe en 1 año contado desde la fecha del reconocimiento o desde que la fuerza haya cesado.

4) Es un acto jurídico solemne. La manifestación de voluntad, por la cual una persona reconoce que es padre o madre de otra, requiere que sea expresada en la forma la ley determine; esto depende del tipo de reconocimiento que se trate.

5) Es un acto jurídico personalísimo. En consecuencia, el menor adulto y el interdicto por disipación pueden reconocer que son padre o madre de una persona.

6) Puede reconocerse como hijo a un menor o mayor de edad sin limitaciones.

- El reconocimiento es un acto jurídico declarativo, no es un acto negocial, por lo que no se requiere que se reciba la manifestación de voluntad por parte del reconocido para que produzca efectos, sea que éste fuera menor o mayor de edad.

- La única limitación es que no puede reconocerse a una persona que ya tenga su filiación determinada, ya que nadie puede tenerla de más de un padre o de más de una madre. Quien quiera reconocer a una persona que ya su filiación determinada, tendrá que interponer una acción de impugnación conjuntamente con una acción de reclamación, teniendo que probar la

filiación biológica; sin embargo, la posesión notoria del estado civil de hijo que otros pudieran tener, le sería oponible a la prueba pericial de ADN.

7) Tampoco puede ser reconocido el hijo que ha sido procreado por mujer casada fuera del matrimonio.

8) Es irrevocable, aun cuando haya sido efectuado en un testamento (189 inc 2º).

9) Puede hacerse por medio de mandatarios. El mandato debe ser especial y constar en escritura pública.

10) No puede sujetarse a condición, plazo o modo.

11) Debe cumplir con una formalidad por vía de publicidad, inscribirse en el acta de nacimiento o subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento.

3. Clases de reconocimiento.

El reconocimiento puede ser:

1. Expreso, el cual a su vez puede ser espontáneo o provocado.
2. Tácito o presunto.

8.4.1 RECONOCIMIENTO EXPRESO.

1. Espontáneo (Art. 187 CC):

Se hace mediante una declaración formulada con ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos:

1. Ante el oficial del Registro Civil,
 - Al momento de inscribirse el nacimiento del hijo.
 - O en el acto del matrimonio de los padres.
 2. En acta extendida en cualquier tiempo, ante cualquier oficial del Registro Civil.
 3. En escritura pública.
 4. En un acto testamentario.
- Si se trata de un acto entre vivos puede hacerse por mandatarios (Art. 190 CC).
 - El mandato debe ser solemne (escritura pública) y especial.
 - Ello no es posible si se trata de un acto testamentario, porque la facultad de testar es indelegable (Art. 1004 CC).

2. Provocado (Art. 188 inc. 2º CC) DEROGADO (Año 2005):

a) Hasta el año 2005 el art 188 CC en los incs 2º, 3º y 4º regulaba lo que se conocía como reconocimiento forzado o provocado. Consistía en citar a la presencia judicial al

presunto padre o madre y se le hacía declarar, bajo juramento, la efectividad de ser o no padre (o madre) de aquel que lo había citado. Era una gestión judicial no contenciosa.

En la práctica esta institución se presentó inocua. Por esta razón en el 2005 se dictó la ley 20.030 que derogó los incs 2º, 3º y 4º del art 188, terminando con esta institución de reconocimiento, porque en realidad tenía más sentido darle más fuerza a la prueba pericial de ADN.

Además, la ley 20.030 incorporó el art 199 inc. 2 bis, que estableció el **reconocimiento provocado voluntario**.

b) El art 199 inc. 2 bis CC señala que cuando se interpone una acción de reclamación de la filiación, el padre o madre que ha sido emplazado a un juicio de filiación puede adoptar en la audiencia de preparación distintas posiciones, una de ellas es reconocer al hijo.

En el evento en que al ser consultado sobre la paternidad (o maternidad) reconozca, en la audiencia de preparación, como hijo a quien lo ha emplazado, es lo que se conoce como reconocimiento provocado voluntario.

- Es provocado porque lo ha sido a instancia de la interposición de una acción de reclamación de la filiación,
- es voluntario porque en la audiencia de preparación, el padre (o madre) reconoce que efectivamente quien lo está demandado es su hijo.

8.4.2 RECONOCIMIENTO TÁCITO O PRESUNTO (ART. 188 inc. 1º CC).

Hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción de nacimiento.

- Debe quedar claro que debe tratarse de una manifestación de voluntad de quien reconoce, por lo tanto no es posible que se consigne el nombre de uno a petición del otro.
- Este reconocimiento también se puede hacer por mandatarios (aunque la ley no lo dice), pero es necesario también que el mandato sea solemne y especial.

8.5. REPUDIACIÓN DEL RECONOCIMIENTO (FILIACIÓN NO MATRIMONIAL).

El hijo puede repudiar el reconocimiento de que ha sido objeto (Art. 191 CC). Esto sólo es efectivo respecto del reconocimiento voluntario espontáneo.

1. Concepto de repudiación:

Es un acto jurídico unilateral de familia y personalísimo por medio del cual, la persona que ha sido reconocida, rechaza el reconocimiento que le ha hecho otra persona de ser su padre (o madre).

2. No se requiere probar la verdad biológica para repudiar:

Para poder repudiar el reconocimiento no se requiere probar la verdad biológica, es decir, que aquel que lo reconoció no es biológicamente su padre (o madre); en consecuencia, se puede repudiar a quien efectivamente es su padre o madre.

- La ley lo permite porque deja siempre a salvo las acciones de reclamación y de impugnación.
- Se entiende que si el hijo repudia el reconocimiento es porque tiene razones de peso para hacerlo, y si le permite a quien lo reconoció no probar la verdad biológica, por qué se le tendrían que imponer cargas más fuertes al que desea repudiar el reconocimiento.
- Por otra parte, la ley entiende que, si bien el reconocimiento es un acto jurídico no recepticio, no puede ser impuesto a una persona.

3. Personas que pueden repudiar (Arts. 191 y 193 CC):

Es un acto jurídico personalísimo, el titular de la acción de repudiación es el hijo.

Precisiones.

- 1) Hijo mayor al momento del reconocimiento: sólo él puede repudiar. Plazo: 1 año desde que supo del reconocimiento.
- 2) Hijo menor: sólo él puede repudiar. Plazo: 1 año desde que, llegado a la mayor edad, supo del reconocimiento.
- 3) Hijo mayor interdicto por demencia o sordomudez: curador, previa autorización judicial.
- 4) Hijo interdicto por disipación: personalmente.
- 5) Hijo muerto o que falleció antes de llegar a la mayoría de edad: sus herederos. Plazo: 1 año, contado desde el reconocimiento o desde la muerte, respectivamente.
- 6) Hijo mayor que fallece antes de expirar el término para repudiar: sus herederos, por el tiempo que falte para completar el plazo.

4. Características de la repudiación:

- 1) Unilateral.
- 2) Solemne: escritura pública. Para que sea oponible a terceros, debe subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento (Art. 191 inc. 4º CC).
- 3) Irrevocable (Art. 191 inc. final CC).

5. No se puede repudiar si se aceptó el reconocimiento (Art. 192 CC):

- 1) Aceptación expresa: se toma el título de hijo en instrumento público o privado, o en acto de tramitación judicial.
- 2) Aceptación tácita: realización de un acto que supone necesariamente la calidad de hijo.

6. Efectos de la repudiación:

1) Priva retroactivamente al reconocimiento de todos los efectos que benefician exclusivamente al hijo o sus descendientes, pero:

- No altera los derechos ya adquiridos por los padres o terceros,
- No afecta a los actos celebrados ejecutados antes de la subinscripción correspondiente. Esto último no debe extenderse al derecho hereditario que podría invocar el padre en la sucesión del hijo que reconoce (Art. 191 inc. 5º CC).

2) El matrimonio posterior de los padres de aquél que repudió la filiación no matrimonial, no alterará los efectos de la repudiación: en efecto, dispone el Art. 194 CC que la repudiación de cualquiera de los reconocimientos que dan lugar a la filiación matrimonial de los nacidos antes del matrimonio de los padres impedirá que se determine legalmente dicha filiación.

CAPÍTULO 9. ACCIONES DE FILIACIÓN.

9.1 ASPECTOS GENERALES.

1. Tipos de acciones.

- 1) Acciones de reclamación de filiación.
- 2) Acciones de impugnación de filiación.
- 3) Acción de desconocimiento de paternidad.

2. Principios.

1. Libre investigación de la paternidad y maternidad.
2. Las acciones de filiación son declarativas de derechos, no constitutivas.
3. Las acciones de filiación sólo las puede ejercitar el propio interesado (hijo, padre o madre) y son intransmisibles.
4. Medidas protectoras para el hijo durante el juicio.
5. Amplia admisibilidad probatoria, aceptándose pruebas biológicas.

9.2 ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN.

1. Concepto.

Son (1) aquellas que la ley otorga al hijo en contra de su padre o madre, o a éstos en contra de aquel, (2) para que se resuelva judicialmente que una persona es hijo de otra.

2. Clases de acciones de reclamación.

1. ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN MATRIMONIAL.

Sujeto Activo (Art. 204 CC):

1) El hijo: debe demandar conjuntamente a ambos padres, porque no se puede reconocer filiación matrimonial de uno solo.

2) El padre o la madre: el otro padre debe intervenir forzosamente en el juicio, bajo pena de nulidad. El resultado del juicio los va a afectar a ambos, por lo que es necesario emplazarlos a los dos. Basta con el emplazamiento; no es necesario que efectúe gestiones.

2. ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN NO MATRIMONIAL.

Sujeto Activo (Art. 205 CC):

1) El hijo: personalmente o representado, en contra del padre, madre o ambos.

2) El padre o la madre:

- Cuando el hijo tenga determinada una filiación diferente, debe entablarse la acción de reclamación conjuntamente con la de impugnación (Art. 208 CC), y deben ser parte el hijo y las personas respecto de las cuales existe filiación.
- Si el hijo no tiene filiación determinada, no procede la acción, porque puede ser reconocido.

❖ Hijo que muere siendo incapaz:

- La acción de reclamación la pueden ejercer sus herederos, dentro del plazo de 3 años desde la muerte.
- Si el hijo muere antes de 3 años desde que alcanzó la capacidad, los herederos tienen la acción por lo que falte.
- Si los herederos son incapaces, el plazo se cuenta desde que alcanzan la capacidad (Art. 207 CC).

❖ Hijo póstumo o padre que muere dentro de los 180 días siguientes al parto:

- La acción de reclamación puede dirigirse en contra de los herederos del padre, dentro del plazo de 3 años desde la muerte.
- Si el hijo es incapaz, el plazo se cuenta desde que alcanza la capacidad (Art. 206 CC).

9.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN

1. Imprescriptible e irrenunciable, pero sus efectos patrimoniales se rigen por las reglas generales (Art. 195 inc. 2º CC).

2. Personalísima: no se puede ceder ni transmitir, salvo en el caso del hijo que muere siendo incapaz.

3. Se tramita en un juicio de filiación, con las siguientes características:

- 1) Es un juicio ordinario.
- 2) El proceso es secreto hasta que se dicte sentencia de término (Art. 197 inc. 1º CC).
- 3) El tribunal competente es el juez de familia del domicilio del demandado o demandante, a elección de este último. (artículo 147 del COT, modificado por la Ley 10.030 del año 2005)

9.2.2. PRUEBA EN LOS JUICIOS DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN.

1. La regla es que la paternidad o maternidad se puede establecer mediante toda clase de pruebas, decretadas de oficio o a petición de parte.

Pero:

- La prueba de testigos no es suficiente por sí sola, y
- En cuanto a las presunciones, deben ser graves, precisas y concordantes (Art. 198 CC).
- Se debe admitir todo medio que el juez estime idóneo, aunque no esté legalmente reconocido.

2. La ley admite las pruebas periciales de carácter biológico.

- Deben practicarse por el SML o por laboratorios idóneos designados por el juez.
- Las partes siempre, y por una sola vez, tienen derecho a solicitar un nuevo informe pericial (Art. 199 inc. 1º CC).
- El juez puede darles por sí solas valor suficiente para establecer o excluir la filiación, y la negativa injustificada hace presumir legalmente la paternidad o maternidad, o la ausencia de ella según corresponda. Negativa injustificada: la parte no concurre habiendo sido citada 2 veces.

3. La prueba más importante la constituye la posesión notoria de la calidad de hijo (Art. 200 CC).

Consiste en que el (1) padre o madre lo traten como hijo, (2) proveyendo a su educación y establecimiento de modo competente, y (3) presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; (4) y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal (trato, nombre y fama).

Requisitos:

- 1) Debe haber durado a los menos 5 años continuos.
- 2) Los hechos que la constituyen deben probarse por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de modo irrefragable. La posesión notoria prefiere a las pruebas periciales en caso de contradicción, salvo que hay graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo (Art. 201 CC).

4. El concubinato de los padres sirve de base para una presunción judicial de paternidad:

- Hijo que tiene filiación determinada respecto de su madre y prueba que ésta vivió en concubinato con el supuesto padre durante la época en que ha podido producirse la concepción (Art. 210 CC).
- Si el supuesto padre prueba que la madre cohabitó con otro durante esa época, la demanda no se desecha, pero debe emplazarse a este otro para poder dictar sentencia (no hay claridad acerca del objeto de este emplazamiento).

9.2.3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN.

1. Límites a la interposición de demandas de reclamación de filiación.

Responsabilidad por acción de mala fe o con el objeto de lesionar la honra del demandado (Art. 197 inc. 2º CC): debe indemnizar al afectado.

2. Sanción al padre o madre que se opone a la determinación de la filiación. (Art. 203 CC).

- Si la filiación se determina judicialmente contra la oposición de uno de los padres, queda privado de la patria potestad y, en general, de todos los derechos que la ley le confiere respecto de la persona y bienes del hijo.
- Pero mantiene todas las obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes.
- Sin embargo, el hijo mayor puede restablecerlos en sus derechos, por escritura pública o testamento.

3. Alimentos provisionales (Art. 209 CC).

El juez puede decretar alimentos provisionales, reclamada la filiación, en los términos del Art. 327 CC, es decir, en base a petición fundada y con cargo a restituirlos si la sentencia es absolutoria.

4. La sentencia que acoge la acción de reclamación es declarativa.

Art. 181 incs. 1º y 2º CC. "La filiación produce efectos civiles cuando queda legalmente determinada, pero éstos se retrotraen a la época de la concepción del hijo. No obstante, subsistirán los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas antes de su determinación, pero el hijo concurrirá en las sucesiones abiertas con anterioridad a la determinación de su filiación, cuando sea llamado en su calidad de tal."

9.3 ACCIONES DE IMPUGNACIÓN DE FILIACIÓN.

(1) Tienen por objeto dejar sin efecto la filiación generada por una determinada paternidad o maternidad, (2) por no ser efectivos los hechos en que se funda.

- No cabe la impugnación de la filiación determinada por sentencia firme (Art. 220 CC), lo que se aplica respecto del hijo y los padres que intervinieron en el pleito.
- Pero esto no obsta a que un tercero pueda demandar la filiación entablando conjuntamente las acciones de impugnación y reclamación (Art. 320 CC).

9.3.1 IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD DEL HIJO CONCEBIDO O NACIDO DURANTE EL MATRIMONIO.

Casos de impugnación

- **2 situaciones:**

- i) HIJO CONCEBIDO ANTES DEL MATRIMONIO Y NACIDO DURANTE ÉL:

- El hijo que nace dentro de los primeros 180 días del matrimonio se presume concebido antes de él (Art. 76 CC), y si el marido no tuvo conocimiento del embarazo, puede desconocer judicialmente la paternidad (Art. 184 CC).
 - Esto es propiamente una **acción de desconocimiento**, pero se rige por los plazos y formas de las acciones de impugnación.

- ii) HIJO CONCEBIDO DURANTE EL MATRIMONIO: esta sí es una impugnación.

- **Personas que pueden impugnar la paternidad:**

- i) MARIDO (Art. 212 CC):

El plazo dependerá de si los cónyuges viven juntos o no:

- a. Regla general: 180 días siguientes al día en que tuvo conocimiento del parto.
 - b. Si el marido prueba que a la época del parto estaban separados de hecho: 1 año desde la misma fecha.

❖ Presunciones sobre la fecha en que el marido supo del parto (simplemente legales):

- 1. Si reside en el lugar de nacimiento del hijo: se presume que lo supo inmediatamente, a menos que la mujer haya ocultado el parto.
 - 2. Si al tiempo del nacimiento estaba ausente: se presume que lo supo inmediatamente después de su vuelta, salvo que haya ocultación.

- ii) HEREDEROS DEL MARIDO O CUALQUIER PERSONA A LA QUE LA PRETENDIDA PATERNIDAD LE PRODUCE PERJUICIO (Art. 213 CC):

Mientras el marido vive, sólo él puede impugnar la paternidad. Pero si fallece antes de tomar conocimiento del parto o mientras está corriendo el plazo para impugnar, la acción pasa a los herederos y a las personas a las cuales la paternidad les causa perjuicio, por la totalidad o el resto del plazo, según el caso.

iii) EL HIJO (Art. 214 CC):

Si impugna:

- El representante legal, el plazo es de 1 año desde el nacimiento;
- El hijo, el plazo de 1 año se cuenta desde que adquiere plena capacidad.

9.3.2 IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD DETERMINADA POR RECONOCIMIENTO

- Cuando se trata de la impugnación de la paternidad determinada por reconocimiento, *el padre que reconoció al hijo no es titular de la acción de impugnación (el reconocimiento es un acto jurídico irrevocable), pero puede impetrar la nulidad del reconocimiento por vicios de la voluntad.*
 - Esta acción de nulidad por vicio de la voluntad prescribe en 1 año contado desde la fecha del otorgamiento, o en caso de fuerza, desde que cesa (Art. 202 CC).
- **Sí pueden entablar la acción de impugnación** (Art. 216 CC):

i. EL HIJO RECONOCIDO POR SU PADRE:

El plazo es de 2 años desde que el hijo supo del reconocimiento.

- Si el hijo es incapaz, puede impugnar el representante legal.
- Si muere desconociendo el reconocimiento o antes de que expire el plazo para impugnar, la acción corresponde a sus herederos por el mismo plazo o por lo que falte, respectivamente, desde la muerte del hijo.

En el caso de los hijos nacidos antes del matrimonio de sus padres, el plazo se cuenta desde que el hijo supo del matrimonio o reconocimiento.

ii. TODA PERSONA QUE PRUEBE INTERÉS ACTUAL EN LA IMPUGNACIÓN:

El plazo es de 1 año contado desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer su derecho. El interés debe ser patrimonial.

9.3.3 IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD.

Puede impugnarse atacando los hechos en que se funda (Art. 217 CC):

- i) La existencia del parto (falso parto).
- ii) Que el hijo sea producto de ese parto (suplantación del hijo).

- **Personas que pueden entablar la acción** (Art. 217 y 218 CC):

- i. EL MARIDO DE LA SUPUESTA MADRE. Plazo: 1 año desde el nacimiento del hijo.
- ii. LA SUPUESTA MADRE. Plazo: 1 año desde el nacimiento del hijo.
- iii. LOS VERDADEROS PADRE O MADRE. No hay plazo, porque se entabla conjuntamente la reclamación.
- iv. EL VERDADERO HIJO, O EL QUE PASA POR TAL si se reclama conjuntamente la determinación de la filiación auténtica. Si no la entabla conjuntamente con la reclamación, el plazo es de 1 año desde que alcanza la plena capacidad.
- v. TODA OTRA PERSONA A QUIEN LA MATERNIDAD APARENTE PERJUDIQUE ACTUALMENTE ENSUS DERECHOS SOBRE LA SUCESIÓN DE LOS SUPUESTOS PADRE O MADRE, siempre que no exista posesión notoria. Plazo: 1 año desde el fallecimiento de éstos.

Si sale a la luz algún hecho incompatible con la maternidad putativa, puede subsistir o revivir la acción respectiva por 1 año desde la revelación del hecho.

Sanción a los que intervengan en la suplantación del parto (Art. 219 CC): no les aprovecha en modo alguno el descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de patria potestad, o para exigirle alimentos o sucederle.

** Tanto las sentencias de reclamación como las de impugnación deben subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (Art. 221 CC). Este es un requisito de oponibilidad.

CAPÍTULO 10. EFECTOS DE LA FILIACIÓN.

10.1. AUTORIDAD PATERNA.

1. Concepto

Conjunto de derechos y obligaciones de contenido eminentemente moral, existente entre padres e hijos.

2. Contenido.

Hay que distinguir:

a) DEBERES DE LOS HIJOS PARA CON SUS PADRES Y ASCENDIENTES.

1) Deber de respeto y obediencia a los padres (Art. 222 CC).

2) Deber de cuidado (Art. 223 CC): el hijo queda siempre obligado a cuidar de sus padres en todas las circunstancias de la vida en que necesiten de su auxilio. Lo mismo ocurre con los demás ascendientes, en caso de inexistencia o insuficiencia de los inmediatos descendientes.

b) DERECHOS-DEBERES DE LOS PADRES PARA CON LOS HIJOS.

Para comprenderlos, es necesario tener en cuenta el interés superior del hijo (Art. 222 inc. 2º CC y art. 7 Ley Nº21.430).

1) DERECHO-DEBER DE CUIDADO DE LOS HIJOS.

El 21 de junio de 2013 se publicó la Ley Nº 20.680, "Amor de papá".

Esta ley estableció lo siguiente:

Art. 224 CC. **Toca de consuno a los padres**, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.

Art. 225 inc. 1 CC. **Si los padres viven separados** podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al padre, a la madre o a ambos en forma compartida.

Características del acuerdo:

- El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial del Registro Civil.
- El acuerdo deberá ser subinscrito al margen de la inscripción de nacimiento del hijo dentro de los treinta días subsiguientes a su otorgamiento.
- Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades.

Cuidado personal compartido:

Es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad.

A falta del acuerdo del inciso primero del Art. 225 CC:

- Los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo.
- En cualesquier de los casos establecidos en el artículo 225 CC, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido.
Esto deberá entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226 CC.
- En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres.
- Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos, considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229 CC.
- Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros.

En el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias (Art. 225-2 CC)

- a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres, y demás personas de su entorno familiar.
- b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad.
- c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro padre, pudiendo hacerlo.
- d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229 CC.
- e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades.
- f) La opinión expresada por el hijo.
- g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar.
- h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio.
- i) El domicilio de los padres.
- j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés superior del hijo."

Caso de inhabilidad física o moral de ambos padres: Art. 226 CC

El juez podrá confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2 CC.

En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes, al cónyuge o al conviviente civil del padre o madre según corresponda²⁰.

2) DERECHO-DEBER DE MANTENER CON EL HIJO UNA RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR.

Es el equivalente a lo que antes se llamaba "derecho de visita".

²⁰ La ley 20.830, modificó el inciso segundo del art. 226, que anteriormente señalaba únicamente: "en la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y, en especial, a los ascendientes".

El Art. 229 CC establece que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 225 CC o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.

Se entiende por **relación directa y regular** aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable.

Para la determinación de este régimen, los padres, o el juez en su caso, fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades, y considerando especialmente:

- a) La edad del hijo.
- b) La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos.
- c) El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado.
- d) Cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del hijo.

Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de éstos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana.

El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo.

Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente.

Relación directa y regular con los abuelos.

El Art. 229-2 establece, además, que el hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez fijará la

modalidad de esta relación atendido el interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229.

❖ Autorización para que el menor pueda salir al extranjero (Art. 49 Ley de Menores):

a. Si la tuición no ha sido confiada a ninguno de los padres: se requiere autorización de los dos, o del que lo haya reconocido.

b. Si la tuición se confió a uno de los padres o a un tercero: se requiere autorización del que tiene la tuición.

c. Si se ha decretado derecho de visitas: se requiere también la autorización del que tiene ese derecho.

3) CRianza Y EDUCACIÓN.

Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente (Art. 224 CC).

Educación se entiende en sentido amplio: formar al hijo para que logre el pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida.

❖ Los padres están privados del derecho a educar a sus hijos:

a. Cuando la filiación ha sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre (Art. 203 CC).

b. Cuando el cuidado del hijo haya sido confiado a otra persona (Art. 237 CC).

c. Cuando el padre ha abandonado al hijo (Art. 238 CC).

d. Cuando el hijo ha sido separado de su padre por inhabilidad moral de éste (Art. 239 CC).

4) GASTOS DE EDUCACIÓN, CRianza Y ESTABLECIMIENTO DE LOS HIJOS.

1. Si los padres están casados en régimen de sociedad conyugal: los gastos son de cargo de la sociedad (Arts. 1740 N° 5 y 1744 CC).

2. Si no hay sociedad conyugal: ambos padres deben contribuir en proporción a sus respectivas facultades económicas (Art. 230 CC).

3. Si el hijo tiene bienes propios: los gastos de establecimiento, y en caso necesario, los de su crianza y educación, pueden sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible (Art. 231 CC).

4. En caso de insuficiencia de los padres: la obligación de alimentar y educar al hijo pasa a sus abuelos, por una y otra línea (Art. 232 CC).

❖ Si hay desacuerdo entre los obligados a contribuir a estos gastos, la contribución será determinada de acuerdo a sus facultades económicas por el juez, que podrá modificarla cada cierto tiempo, en atención a las circunstancias (Art. 233 CC).

❖ **Derechos que asisten a la persona que alimenta y cría a un hijo ajeno:** sus padres sólo podrán sacarlo del poder de ella con autorización del juez, previo pago de los costos de crianza y educación. El juez sólo lo autorizará cuando sea de conveniencia para el hijo, por razones graves (Art. 240 CC).

❖ **Suministro de alimentos al menor ausente de su casa (Art. 241 CC):** se contempla una presunción (simplemente legal) en el sentido de que el padre, la madre, o la persona que tiene al menor a su cuidado autorizó al menor para efectuar las adquisiciones que se le hicieron en razón de alimentos, y por la misma razón deben responder de su pago. Requisitos para que opere:

1. Que el menor esté ausente de la casa de su padre, madre o persona que lo tenga a su cuidado.
2. Que el menor se encuentre en urgente necesidad.
3. Que el menor no esté en condiciones de ser asistido por el padre, madre o persona que lo tenga bajo su cuidado.
4. Que un tercero haga al menor suministros a título de alimentos.
5. Que este tercero dé noticia al padre o madre, o a quien corresponda la sustentación del menor, lo más pronto posible.

❖ **Facultad de los padres de corregir a sus hijos (Art. 234 CC):** los padres tienen esta facultad, pero debe cuidar que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal. Si se produce tal menoscabo, cualquier persona (incluso el juez de oficio) puede solicitar medidas de resguardo.

10.2. PATRIA POTESTAD.

1. Concepto.

Art. 243 inc. 1º CC. "La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o a la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados."

2. Titulares de la patria potestad (art. 244 CC).

A falta de acuerdo, toca al padre y a la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad.

Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos, se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres, o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negare injustificadamente, se requerirá autorización judicial.

10.3. ATRIBUTOS DE LA PATRIA POSTESTAD.

La patria potestad implica tres atributos:

1. El derecho legal de goce o usufructo legal
2. La administración de los bienes del hijo
3. La representación legal del hijo

10.3.1. DERECHO LEGAL DE GOCE O USUFRUCTO LEGAL.

1. Concepto:

(1) derecho personalísimo **(2)** que consiste en la facultad de usar los bienes del hijo y percibir sus frutos, **(3)** con cargo de conservar la forma y substancia de dichos bienes y de restituirlos, si no son fungibles; **(4)** o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si son fungibles (Art. 252 inc. 1º CC).

2. Características:

1. Derecho personalísimo.
2. Inembargable (Art. 2466 inc. final CC).
3. No obliga a rendir caución de conservación y restitución, ni tampoco a hacer inventario solemne, pero debe llevarse una descripción circunstanciada de los bienes desde que entre a gozar de ellos (Art. 252 inc. 2º CC).
4. Si quien goza del derecho legal de goce es la madre casada en régimen de sociedad conyugal, se considerará separada de bienes respecto de su ejercicio y de lo que en él obtenga, rigiéndose por el Art. 150 CC (Art. 252 inc. 3º CC).
5. Si la patria potestad la ejercen conjuntamente ambos padres, el derecho legal de goce se distribuye en la forma que ellos lo tengan acordado. A falta de acuerdo, por partes iguales (Art. 252 inc. 4º CC).

3. Bienes sobre los que recae el derecho legal de goce (Art. 250 CC): sobre todos los bienes del hijo.

Excepciones:

a. Bienes que integran el peculio profesional o industrial del hijo. Respecto de ellos, el goce lo tiene el hijo (Art. 251 CC).

b. Bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado, cuando el donante o testador:

1. Ha estipulado que no tenga el goce quien ejerza la patria potestad,
2. Ha impuesto la condición de obtener la emancipación, o
3. Ha dispuesto expresamente que tenga el goce el hijo.

c. Herencias o legados que han pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la patria potestad. Respecto de ellos, tiene el goce el hijo o el otro cónyuge.

- Si el padre o madre que tiene la patria potestad no puede ejercer el derecho de goce sobre uno o más bienes del hijo, este derecho pasa al otro.

- Si ambos están impedidos, la propiedad plena pertenece al hijo y se le debe dar un curador para la administración (Art. 253 inc. 2º CC).

10.3.2. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL HIJO.

1. BIENES QUE FORMAN EL PECULIO PROFESIONAL O INDUSTRIAL: los administra el hijo, con la limitación del Art. 254 CC.

2. RESPECTO DE LOS OTROS BIENES: la regla es que los administre quien tenga el derecho legal de goce (Art. 253 inc. 1º CC). Si ninguno lo tiene, administra un curador.

a. Facultades administrativas del padre: tiene amplias facultades, salvo las excepciones legales (limitaciones):

1. Para (1) enajenar o (2) gravar bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su peculio profesional o industrial, o derechos hereditarios, se requiere autorización judicial con conocimiento de causa (Art. 254 CC). Sanción por la omisión: nulidad relativa.

2. No puede (1) donar parte alguna de los bienes del hijo, (2) ni darlos en arriendo por largo tiempo, (3) ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y curadores:

1) Donaciones (Art. 402 CC): el padre no puede donar bienes raíces ni aun con autorización judicial (sanción: nulidad absoluta), pero sí bienes muebles, que el juez autorizará sólo cuando exista causa grave (sanción: nulidad relativa).

2) Arriendos (Art. 407 CC): no puede arrendarlos por más de 5 años si son urbanos, ni por más de 8 si son rústicos, ni por más tiempo que el que le falte para que el menor cumpla 18 años. Sanción: inoponibilidad por el exceso.

3) Aceptación de una herencia (Art. 397 CC): debe aceptar con beneficio de inventario. Sanción: el menor no será obligado por las deudas de la sucesión sino hasta concurrencia de lo que existe en la herencia o se pruebe que ha empleado en su beneficio.

4) Repudiación de una herencia (Art. 397 CC): se requiere autorización judicial con conocimiento de causa. Sanción: nulidad relativa.

3. Para provocar la partición de las herencias o bienes raíces en que tenga interés el menor, requiere de autorización judicial (Art. 1322 CC). La designación de partidor requiere aprobación judicial (Art. 1326 CC). Sanción en ambos casos: nulidad relativa de la partición.

b. Responsabilidad del padre o madre por la administración de los bienes del hijo: responde hasta de la culpa leve (Art. 256 CC).

c. Privilegio en favor del hijo: tiene un crédito privilegiado de cuarta clase por los bienes de su propiedad que sean administrados por el padre o madre, sobre los bienes de éstos (Art. 2481 N° 4 CC).

d. Extinción de la administración del padre o la madre:

1. Emancipación del hijo.
2. Suspensión de la patria potestad (Art. 257 inc. 2º CC).
3. Privación de la administración de los bienes del hijo al padre, madre o ambos, por haberse hecho culpable de dolo o de grave negligencia habitual (Art. 257 inc. 1º CC).

❖ Al término de la patria potestad, los padres deben poner a sus hijos en conocimiento de la administración ejercida sobre sus bienes (Art. 259 CC).

10.3.3. REPRESENTACIÓN LEGAL DEL HIJO.

i) El hijo menor adulto tiene capacidad para celebrar ciertos actos:

a. Actos judiciales o extrajudiciales que digan relación con su peculio profesional o industrial (Art. 251 CC).

b. Actos de familia, como (1) casarse, (2) testar y (3) reconocer hijos.

ii) Incapacidad del hijo menor: fuera de las excepciones recién señaladas, el hijo tiene que actuar representado o autorizado por su representante legal:

a. REPRESENTACIÓN EXTRAJUDICIAL.

El representante legal es el padre o la madre que lo tenga bajo su patria potestad. Si ninguno lo tiene, lo representa el respectivo curador.

1. Efectos de los actos del hijo, ajenos al peculio, autorizados o representados (Art. 261 CC):

i. Si el que ejerce la patria potestad está casado en sociedad conyugal: obligan directamente a éste, en conformidad a las disposiciones de ese régimen, y subsidiariamente al hijo, hasta concurrencia del beneficio que le reporte.

ii. Si no hay sociedad conyugal: sólo obliga al padre o madre que haya intervenido, pero puede repetir contra el otro en la parte en que haya debido proveer a las necesidades del hijo.

2. Efectos de los actos del hijo sin autorización del representante (Art. 260 CC): le obligan exclusivamente en su peculio profesional o industrial. Pero si no tiene, la sanción es la nulidad relativa (sanción normal).

3. Contratos entre padres e hijos sometidos a su patria potestad: la ley sólo prohíbe la compraventa (Art. 1796 CC). Fuera de este caso (y el de la permuta, por aplicación del Art. 1900 CC), la contratación entre ellos es posible, sin perjuicio de la incompatibilidad de intereses que puede darse.

b. REPRESENTACIÓN JUDICIAL.

1. Juicios en que el hijo es demandante o querellante (Art. 264 CC): el hijo no puede comparecer sino autorizado o representado por quien tiene la patria potestad. Si éste niega su consentimiento o está inhabilitado para prestarlo, puede suplirlo el juez, y dará al hijo un curador para la litis.

2. Acciones civiles seguidas contra el hijo (Art. 265 CC): el actor debe dirigirse a quien tenga la patria potestad, para que autorice o represente al hijo en la litis. Si la ejercen ambos padres, basta que se dirija a uno. Si se niega o no puede autorizar o representar, el juez puede suplirlo, y dará un curador para la litis. Esto no rige en juicios relativos al peculio.

3. Juicios criminales en contra del hijo (Art. 266 CC): no se requiere la intervención de quien tiene la patria potestad, pero está obligado a suministrarle los auxilios que necesite para su defensa.

4. Juicios del hijo en contra del padre o madre que ejerce la patria potestad (Art. 263 CC): requiere autorización del juez, que le dará un curador para la litis. El padre o madre deben proveerlo de expensas para el juicio, lo que regulará el juez.

10.4. SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD.

En este supuesto, la patria potestad no se extingue.

1) Casos (Art. 267 CC):

1. Prolongada demencia del que la ejerce.
2. Menor edad del que la ejerce.
3. Por estar el que la ejerce en entredicho de administrar sus bienes, cualquiera sea la causa de la interdicción.
4. Larga ausencia u otro impedimento físico del que la ejerce, de los cuales se siga perjuicio grave a los intereses del hijo.

2) Efectos de la suspensión:

- i) Si se suspende respecto de uno de los padres, pasa a ser ejercida por el otro.

ii) Si se suspende respecto de ambos, el hijo queda sujeto a guarda.

❖ La suspensión de la patria potestad opera por sentencia judicial; no opera de pleno derecho, salvo que se trate de la menor edad de quien la ejerce. Debe ser decretada judicialmente con conocimiento de causa (Art. 268 inc. 1º CC).

❖ Cuando cesa la causa que motivó la suspensión, el juez puede decretar que el padre o la madre recupere la patria potestad, en atención al interés del hijo (Art. 268 inc. 2º CC).

❖ Las resoluciones de suspensión y recuperación de la patria potestad deben subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento (requisito de oponibilidad, Art. 268 inc. final CC).

10.5. EMANCIPACIÓN.

1) Concepto:

Hecho que pone fin a la patria potestad del padre, de la madre o de ambos, según sea el caso (Art. 269 CC).

❖ Las normas sobre emancipación son de orden público. Por ello, las causales de emancipación son taxativas.

2) Clasificación:

i) Emancipación legal:

Se produce por el sólo ministerio de la ley, en los siguientes casos (Art. 270 CC):

- a. Muerte del padre o madre, salvo que corresponda ejercerla al otro.
- b. Decreto que da la posesión provisoria o definitiva de los bienes del padre o madre desaparecidos, salvo que corresponda ejercerla al otro.
- c. Derogado
- d. Mayoría de edad del hijo.

ii) Emancipación judicial:

Se produce por sentencia judicial en los siguientes casos (Art. 271 CC):

- a. Padre o madre que maltrata habitualmente al hijo, salvo que corresponda ejercerla al otro.
- b. Abandono del hijo, salvo que corresponda ejercerla al otro.
- c. Padre o madre condenados por delito que merezca pena aflictiva, por sentencia judicial ejecutoriada, aunque recaiga indulto, salvo que el juez estime que no hay riesgo para el interés del hijo, o corresponda ejercerla al otro.
- d. Inhabilidad física o moral del padre o madre, salvo que corresponda ejercerla al otro.

La sentencia que declara la emancipación judicial debe subinscribirse al margen de la inscripción de nacimiento del hijo (requisito de oponibilidad).

3) Efectos:

La emancipación no transforma al menor en capaz, salvo que la causal sea haber llegado a la mayoría de edad. El hijo menor que se emancipa queda sujeto a guarda (Art. 237 CC).

4) Irrevocabilidad de la emancipación (Art. 272 CC):

Toda emancipación es irrevocable, salvo en el caso de (1) muerte presunta o de (2) inhabilidad moral del padre o madre, las que pueden ser dejadas sin efecto probando fehacientemente la existencia o el cese de la inhabilidad del padre o madre. En estos casos, la revocación debe cumplir ciertos requisitos:

- i) Debe ser ordenada por sentencia judicial.
- ii) Sólo cabe cuando la emancipación se ha producido por las causales de los Arts. 270 N° 2 y 271 N° 4 CC.
- iii) El tribunal sólo puede decretarla cuando conviene a los intereses del hijo.
- iv) La resolución judicial produce efectos desde que se subinscribe al margen de la inscripción de nacimiento.
- v) Procede por una sola vez.

CAPÍTULO 11. DERECHO DE ALIMENTOS.

1. Concepto.

Es **(1)** el que la ley otorga a una persona **(2)** para demandar de otra, que cuenta con los medios para proporcionárselos, **(3)** lo que necesite para subsistir adecuadamente, **(4)** que debe cubrir a lo menos el sustento, habitación, vestidos, salud, movilización, enseñanza básica y media, y aprendizaje de alguna profesión y oficio (Art. 323 CC en relación con los Arts. 329 y 330 CC).

2. Clasificación.

a) ATENDIENDO A SI LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS PROVIENE DE LA LEY O DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES:

- 1) *Alimentos legales o forzosos*: los establece la ley.
- 2) *Alimentos voluntarios*: emanan del acuerdo de las partes o de la declaración unilateral de una parte.

El CC sólo regula los legales. En los voluntarios, debe estarse a la intención de las partes o del testador.

Cuando la persona obligada a pagar una pensión de alimentos muere, esos alimentos constituyen una asignación forzosa y una baja general de la herencia.

b) ATENDIENDO A SI SE OTORGAN MIENTRAS SE TRAMITA EL JUICIO O EN FORMA DEFINITIVA (SÓLO APLICABLE A LOS LEGALES):

- 1) *Provisorios*: son los que el juez ordena otorgar mientras se ventila el juicio de alimentos, desde que en el mismo juicio el que los demanda ofrezca fundamento plausible (Art. 327 CC).
- 2) *Definitivos*: son los que se determinan en una sentencia definitiva firme.

Cuando se ordena pago de alimentos provisorios, quien los recibe debe devolverlos si en definitiva no se da lugar a su demanda de alimentos, a menos que la haya intentado de buena fe y con fundamento plausible.

c) CLASIFICACIÓN DE LAS PENSIONES DE ALIMENTOS:

- 1) *Alimentos futuros*.
- 2) *Alimentos devengados o atrasados*.

3. Requisitos del derecho de alimentos.

a) Estado de necesidad en el alimentario:

Art. 330 CC. "Los alimentos no se deben sino en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social."

b) Que el alimentante tenga los medios necesarios para otorgarlos:

Art. 329 CC. "En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las facultades del deudor y sus circunstancias domésticas."

Por excepción, se presume que el alimentante tiene los medios para dar alimentos cuando los demanda un menor a su padre o madre (Art. 3º Ley de Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias).

c) Fuente legal.

Tiene que existir una norma legal que obligue a pagar alimentos. La principal es el Art. 321 CC.

Art. 321 CC. "Se deben alimentos:

- 1.º Al cónyuge;
- 2.º A los descendientes;
- 3.º A los ascendientes;
- 4.º A los hermanos, y
- 5.º Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.

La acción del donante se dirigirá contra el donatario.

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los niegue."

Lo normal en materia de alimentos es la reciprocidad. Pero esta regla se rompe en ciertos casos. Ej. Cuando se determina judicialmente la filiación contra la oposición de un padre, o cuando el padre o la madre a faltado al pago de pensión de alimentos judicialmente decretada.

Orden de precedencia para demandar alimentos:

Art. 326 CC. "El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el artículo 321, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, en el siguiente orden:

- 1.º El que tenga según el número 5º.
- 2.º El que tenga según el número 1º.
- 3.º El que tenga según el número 2º.
- 4.º El que tenga según el número 3º.
- 5.º El del número 4º no tendrá lugar sino a falta de todos los otros.

Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado. Entre los de un mismo grado, como también entre varios obligados por un mismo

título, el juez distribuirá la obligación en proporción a sus facultades. Habiendo varios alimentarios respecto de un mismo deudor, el juez distribuirá los alimentos en proporción a las necesidades de aquéllos.

Sólo en el caso de insuficiencia de todos los obligados por el título preferente, podrá recurrirse a otro.

4. Características del derecho de alimentos.

Es un derecho personalísimo. Consecuencias:

- 1) Es intransferible e intransmisible (Art. 334 CC).
- 2) Es irrenunciable (Art. 334 CC).
- 3) Es imprescriptible (Art. 2498 CC).
- 4) Es inembargable (Arts. 1618 N° 9 CC y 445 N° 3 CPC).
- 5) No se puede someter a compromiso (Art. 229 COT).
- 6) La transacción sobre el derecho de alimentos debe ser aprobada judicialmente (Art. 2451 CC).

❖ Las pensiones alimenticias ya devengadas no tienen estas características (Art. 336 CC):

- 1) Se pueden renunciar, ceder, transmitir, etc.
- 2) Si devengados los alimentos, no se cobran, el derecho a cobrarlos prescribe de acuerdo a las reglas generales.
- 3) La transacción sólo exige aprobación judicial en el caso de los alimentos futuros.

5. Características de la obligación alimenticia.

- a) No se puede extinguir por compensación (Art. 335 CC).
- b) Es intransmisible (al menos para un sector importante de la doctrina).

6. Transmisibilidad de la obligación alimenticia.

Se discute:

a) Es intransmisible:

- 1) De acuerdo al Art. 1168 CC, los alimentos que debía el difunto gravan la masa, y constituyen una baja general de la herencia (Art. 959 N° 4 CC), a menos que el testador la haya impuesto a un heredero, caso en que se trata de una deuda testamentaria.
- 2) Si fuera transmisible, no se justificaría el Art. 959 N° 4 CC; bastaría con el N° 2 (deudas hereditarias).
- 3) La obligación de alimentos se funda en el parentesco, matrimonio o donación, vínculos que generan obligaciones intransmisibles.
- 4) Historia fidedigna (se suprimió la disposición que establecía que era transmisible).

b) Es transmisible:

- 1) La regla general es que las obligaciones son transmisibles. La excepción requiere texto expreso.
- 2) Los herederos representan al causante, por lo que cumplen sus obligaciones.
- 3) Los alimentos se conceden por toda la vida del alimentario si continúan las circunstancias que legitimaron la demanda. Ello es así a pesar de la muerte del alimentante; tienen que hacerse cargo de la obligación los herederos.

7. Tribunal competente para conocer de las demandas de alimentos.

Art. 147 COT. "Será juez competente para conocer de las demandas de alimentos el del domicilio del alimentante o alimentario, a elección de este último. Asimismo, ello se aplicará a las solicitudes de aumento de pensiones alimenticias decretadas.

De las solicitudes de cese o rebaja de la pensión decretada conocerá el tribunal del domicilio del alimentario.

Asimismo, será juez competente para conocer de las acciones de reclamación de filiación contempladas Art. 2º en el Párrafo 2º del Título VIII del Libro I del Código Civil el del domicilio del demandado o demandante, a elección de este último."

8. Transacción en materia de alimentos futuros.

Art. 2451 CC. "La transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial; ni podrá el juez aprobarla, si en ella se contraviene a lo dispuesto en los artículos 334 y 335."

Sanción: la transacción no produce efectos.

La Ley Nº 14.908, agrega que el juez solo puede aprobar la transacción si se cumplen los siguientes presupuestos: (i) Que se disponga el pago mensual y anticipado de un monto expresado en unidades tributarias mensuales; (ii) Que el pago sea hecho mediante depósito o transferencia a una cuenta de ahorro u otro instrumento equivalente dispuesto exclusivamente para el cumplimiento de esta obligación; (iii) Que se especifique la época del mes en que dicho depósito o transferencia ha de realizarse; (iv) Sin perjuicio de lo anterior, también serán válidos los acuerdos de constitución de derechos de usufructo y de uso o habitación sobre bienes del alimentante, realizados de conformidad a lo dispuesto en el art. 9 de la Ley Nº 14.908; (v) También serán válidos los aportes económicos a los que se obligue el alimentante para el otorgamiento de prestaciones o beneficios en favor del alimentario, que surgen de una relación contractual suya que permite satisfacer las necesidades del alimentario en condiciones más favorables, tales como el aporte de la cotización para salud o el pago de la prima del seguro de salud. Estas prestaciones deberán ser valorizadas en unidades tributarias mensuales en el acuerdo, debiendo el incumplimiento ser alegado por el alimentario tan pronto lo conozca, objetando la liquidación; (vi) El acuerdo deberá especificar las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario; (vii) El acuerdo deberá indicar la proporción en la que los padres deberán contribuir, conformes a sus capacidades económicas, a solucionar los gastos extraordinarios del hijo en común,

entendiéndose por tales aquellas necesidades que surgen con posterioridad y cuya existencia no era posible prever, tales como el caso de hospitalizaciones y gastos médicos de urgencia; (viii) El monto de la pensión, expresado en unidades tributarias mensuales, no podrá ser inferior al establecido en el art. 3 de la Ley Nº 14.908

9. Modificación de las pensiones de alimentos.

La sentencia que fija una pensión de alimentos es inamovible mientras se mantengan las circunstancias que la hicieron procedente. Pero si estas circunstancias varían, las sentencias son modificables (Art. 332 inc. 1º CC). Por ello se dice que las sentencias en materia de alimentos no producen cosa juzgada.

10. Formas de obtener el cumplimiento de una resolución que ordenó el pago de alimentos.

- a) Se puede demandar ejecutivamente al alimentante.
- b) Notificando a la persona natural o jurídica que deba pagar al alimentante un sueldo o prestación en dinero, a fin de que retenga y entregue la suma o cuotas periódicas directamente al alimentario, o a su representante legal o persona a cuyo cuidado esté. Se recurre a esta forma cuando el alimentante es empleado.

Si el alimentante (cónyuge, padres o hijos) no cumple, el juez debe apremiarlo con arrestos y multas. Pero el juez puede suspender el arresto si el alimentante justifica que carece de los medios necesarios para el pago. El mismo apremio se puede aplicar al alimentante que renuncia sin causa justificada a su trabajo, para burlar la obligación de prestar alimentos.

11. Garantías para proteger las pensiones alimenticias.

Se permite en ciertos casos los apremios personales del deudor, y también la retención en poder de quien pague al deudor.

1) Son solidariamente responsables al pago quien viva en concubinato con el padre, madre o cónyuge alimentante, y los que sin derecho para ello dificulten o imposibiliten el fiel y oportuno cumplimiento de la obligación (Artículo 18 de la ley 14908).

- El tercero que colabore con el ocultamiento del paradero del demandado para efectos de impedir su notificación o el cumplimiento de alguna de las medidas de apremio establecidas en la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión nocturna, entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días.

2) Puede exigirse al deudor que garantice el cumplimiento con una hipoteca o prenda sobre sus bienes, o con otra forma de caución.

3) Cualquiera de los cónyuges puede pedir la separación de bienes si el otro, obligado al pago de pensiones alimenticias en su favor o en el de sus hijos comunes, hubiere sido apremiado por dos veces.

4) En los juicios de alimentos menores, los tribunales suelen conceder el arraigo del alimentante mientras no se cumpla la obligación alimenticia declarada judicialmente.

12. Forma de fijación, cuantía, reajustabilidad y fecha desde la cual se deben los alimentos.

El juez determina la forma y cuantía de los alimentos (Art. 333 CC).

1) Forma:

Lo normal es que fije una suma de dinero, pero también puede fijar un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos sin autorización del juez. Si se trata de un bien raíz, debe inscribirse la prohibición en el CBR.

2) Cuantía:

La fija el tribunal teniendo en cuenta los medios de que dispone el alimentante y las necesidades del alimentario (Art. 331 CC). Limitación importante: no puede exceder del 50% de las rentas del alimentante.

3) Reajustabilidad:

Cuando la pensión no se fije en un porcentaje de las rentas del alimentante ni en sueldos vitales, sino en una suma determinada, se reajustará anualmente.

4) Fecha desde la cual se deben:

Se deben desde la primera demanda (notificación), y se pagan por mensualidades anticipadas (Art. 331 CC). No se puede pedir la restitución de la parte de las anticipaciones que el alimentario no haya devengado por haber fallecido.

13. Extinción de la obligación de pagar alimentos.

Los alimentos se entienden concedidos para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda (Art. 332 inc. 1º CC). En consecuencia, mientras subsistan las condiciones vigentes al momento en que los alimentos se dieron, la obligación se mantiene, pero en ningún caso más allá de la vida del alimentario, porque el derecho de alimentos no se transmite (Art. 334 CC).

Excepción (Art. 332 inc. 2º CC): los alimentos concedidos a los descendientes y a los hermanos se devengan hasta que cumplan 21 años, salvo que:

- a) Estén estudiando una profesión u oficio: cesa a los 28 años, o
- b) Les afecte una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, o
- c) El juez los considere indispensables para su subsistencia, por circunstancias calificadas.

14. Cese de los alimentos por incurrir el alimentario en injuria atroz.

Art. 324 incs. 1º y 2º CC. "En el caso de injuria atroz cesará la obligación de prestar alimentos. Pero si la conducta del alimentario fuere atenuada por circunstancias graves en la conducta del alimentante, podrá el juez moderar el rigor de esta disposición.

Sólo constituyen injuria atroz las conductas descritas en el artículo 968."

Las conductas referidas son los casos de indignidad para suceder.

15. Los padres que abandonaron al hijo en su infancia carecen del derecho de alimentos.

Art. 324 inc. final CC. "Quedarán privados del derecho a pedir alimentos al hijo el padre o la madre que no haya pagado pensión de alimentos judicialmente decretada, o que le haya abandonado en su infancia, cuando la filiación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición."

CAPÍTULO 12. TUTELAS Y CURATELAS (EN GENERAL).

1. Concepto.

Art. 338 CC. "Las *tutelas* y las *curadurías* o *curatelas* son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida.

Las personas que ejercen estos cargos se llaman *tutores* o *curadores* y generalmente *guardadores*."

Art. 346 CC. "Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman *pupilos*."

2. Diferencias entre tutela y curatela.

TUTELA	CUARTELA
Se da a los impúberes (Art. 341 CC).	Se da a los menores púberes, al resto de los incapaces y también a simples patrimonios, como la herencia yacente.
Impone la obligación de velar por la persona y bienes del pupilo, debiendo conformarse con la voluntad de la persona o personas encargadas de la crianza y educación del pupilo (Art. 428 CC).	Puede o no referirse a la persona; generalmente se refiere a la administración de los bienes.
El tutor debe actuar representando al pupilo, porque es absolutamente incapaz.	El curador puede en algunos casos, autorizar al pupilo para que actúe él.
No admite clasificación.	Depende de la incapacidad, pueden ser: generales, especiales, adjuntas, de bienes, interinas.
Para nombrar a un tutor, no se consulta a la voluntad del impúber.	Cuando se designa curador a un menor adulto, éste propone a la persona (Art. 437 CC).

3. Caracteres comunes a tutores y curadores.

1) Son cargos obligatorios (Art. 338 CC). La no aceptación trae aparejada una sanción: son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador se excusen sin causa legítima.

2) Se otorgan en favor de personas que no se hallan bajo potestad de padre o madre que les pueda dar la protección debida. Sin embargo, la patria potestad no

es incompatible con una curaduría adjunta, sino sólo con la general (Arts. 344 y 348 CC).

3) Tanto el tutor como el curador general tienen la representación legal del pupilo y la administración de sus bienes (Art. 43 CC). Además, ambos deben cuidar de la persona del pupilo (Art. 340 CC).

4) Por regla general, no se puede dar curador a quien ya está sometido a guarda. Excepcionalmente, ello puede ocurrir cuando el tutor o curador alegue que los negocios del pupilo son excesivamente complicados, caso en el cual el juez puede agregar un curador (Art. 351 CC).

5) Lo normal es que el pupilo sea una sola persona. Pero pueden colocarse bajo una misma tutela o curaduría 2 o más individuos, con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonios (Art. 347 CC).

6) Un mismo pupilo puede tener uno o más guardadores (Art. 347 CC): una misma tutela o curaduría puede ser ejercida conjuntamente por 2 o más tutores o curadores.

7) Los guardadores son, por regla general, personas naturales. Excepcionalmente, un banco puede ser guardador, pero su función sólo alcanza a los bienes del pupilo, no a su persona.

4. Clases de curadurías.

a) Curaduría general:

Es aquella que se extiende tanto a la persona como a los bienes del pupilo (Art. 340 CC).

Están sometidos a curaduría general (Art. 342 CC):

- 1) Los menores adultos.
- 2) Los pródigos interdictos.
- 3) Los dementes interdictos.
- 4) Los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente.

b) Curaduría de bienes:

Es aquella que se da a los bienes de ciertas personas, pero que no alcanza a su persona.

Art. 343 CC. "Se llaman curadores *de bienes* los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por nacer."

c) Curadurías adjuntas:

Art. 344 CC. "Se llaman curadores *adjuntos* los que se dan en ciertos casos a las personas que están bajo potestad de padre o madre, o bajo tutela o curaduría general, para que ejerzan una administración separada."

Principales casos de curadurías adjuntas:

- 1) Si el padre o madre que tiene la patria potestad no la puede ejercer sobre uno o más bienes del hijo, se le da un curador para la administración de esos bienes (Art. 253 CC).
- 2) Cuando por sentencia judicial, que se debe subinscribir al margen de la inscripción de nacimiento, se ha quitado al padre o madre, o a ambos, la administración de los bienes del hijo por haberse hecho culpable de dolo, o de grave negligencia habitual (Art. 257 CC).
- 3) En el caso de la persona sometida a tutela o curaduría general, cuando a petición del tutor o curados se nombra otro curador, de acuerdo al Art. 351 CC.
- 4) En el caso en que se haga al pupilo una donación, herencia o legado, a condición de que administre estos bienes la persona que el donante o testador designe, y se acepta la donación, herencia o legado (Art. 352 CC).
- 5) Cuando se suspenda la patria potestad respecto del padre o madre (Art. 348 CC).

d) Curadurías especiales:

Art. 345 CC. "Curador *especial* es el que se nombra para un negocio particular."
Ej. Curador ad litem.

5. Clasificación de las tutelas y curatelas atendiendo a su origen.

Art. 353 inc. 1º CC. "Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o dativas."

a) Testamentaria:

Art. 353 inc. 2º CC. "Son *testamentarias* las que se constituyen por acto testamentario."

1) Personas que pueden designar curador:

1. El adoptante, con preferencia a los padres: con la actual ley de adopción, esto sólo tiene aplicación respecto de las personas que tenían calidad de adoptante antes de que entró en vigencia esta ley (en la ley actual, adoptante y adoptado son padre e hijo).

2. El padre o madre pueden nombrar por testamento:

a. Tutor tanto a los hijos nacidos como a los que se encuentran en el vientre materno, si nacen vivos (Art. 354 CC).

- b. Curador a los menores adultos y a los adultos de cualquiera edad que se hallen en estado de demencia o son sordos o sordomudos que no entienden ni se dan a entender claramente (Art. 355 CC).
- c. Curador para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está por nacer (Art. 356 CC).

2) Características de la guarda testamentaria:

- 1. Puede ser tutela o curaduría, y en este último caso, puede ser general, de bienes o adjunta.
- 2. Puede ser pura y simple o sujeta a condición suspensiva o resolutoria, o a plazo suspensivo o extintivo (Art. 365 CC).
- 3. Puede designarse uno o varios guardadores que ejerzan simultáneamente la guarda o que la dividan entre sí (Art. 361 CC).
- 4. Pueden nombrarse varios tutores o curadores que se sustituyan o sucedan uno a otro (Art. 364 CC).

b) Legítima:

Art. 353 inc. 3º CC. "*Legítimas*, las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuge del pupilo."

Tiene lugar sólo cuando falta o expira la testamentaria (Art. 366 CC).

1) Personas llamadas a la guarda legítima (Art. 367 CC):

- 1. El padre.
- 2. La madre.
- 3. Los demás ascendiente de uno u otro sexo.
- 4. Los hermanos de uno y otro sexo del pupilo y los hermanos de uno y otro sexo de los ascendientes del pupilo.

2) Características de las guardas legítimas:

- i) Puede ser tutela o curaduría general.
- ii) No puede estar sometida a plazo o condición; siempre es pura y simple.

c) Dativa:

Art. 353 inc. 4º CC. "*Dativas*, las que confiere el magistrado."

Tiene lugar a falta de otra tutela o curaduría (Art. 370 CC).

1) Casos en que falta otra tutela o curaduría:

- 1. Cuando se trata de personas que no pueden ser sometidas a guarda legítima.
- 2. Cuando se retarda por cualquier causa el discernimiento de una tutela o curaduría (Art. 371 CC).

3. Cuando sobreviene un embarazo que por algún tiempo impida al tutor o curador seguir ejerciéndola.
4. Cuando se trate de un curador especial (son siempre dativos).

En los casos ii) y iii), se designa un curador interino (Art. 371 CC).

2) Características de la guarda dativa:

1. El tribunal, para hacer la designación, debe oír a los parientes del pupilo y puede nombrar en caso necesario dos o más, y dividir entre ellos las funciones. Si hay curador adjunto, el juez lo debe preferir para la guarda dativa (Art. 372 CC).
2. El curador dativo puede ser general, adjunto o especial, y puede, además, ser definitivo o interino.
3. El menor adulto puede proponer al tribunal la persona que debe desempeñar este cargo.

6. Diligencias y formalidades que deben preceder al ejercicio de la tutela o curaduría.

- a) Discernimiento.
- b) Caución.
- c) Inventario solemne de los bienes del pupilo sometidos a su administración.

CAPÍTULO 13. ACUERDO DE UNIÓN CIVIL²¹

El 21 de abril de 2015 se publicó la ley 20.830 que regula e incorpora al ordenamiento jurídico el acuerdo de unión civil. Esta ley contempló un periodo de vacancia legal de 6 meses, entrando en vigencia el 21 de octubre del año 2015.

1. Concepto

La ley lo define en el artículo 1, señalando que “el acuerdo de unión civil es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente”.

2. Características

A partir de la definición anterior podemos señalar como características generales que el acuerdo de unión civil corresponde a un contrato (solemne) celebrado entre dos personas (sin importar su sexo), del cuál emanan vínculos de familia.

Según dispone el mismo artículo primero, el acuerdo de unión civil otorga el estado civil de conviviente civil mientras se mantenga vigente. Como vimos²², en virtud del AUC se genera parentesco por afinidad con los consanguíneos del otro conviviente civil.

Por otro lado, el artículo 3 de la ley establece que el acuerdo no podrá sujetarse a plazo, condición, modo ni gravamen alguno y que tampoco podrá prometerse su celebración.

Finalmente, el artículo 2 establece que los efectos de este contrato se regulará conforme a lo que establece la ley, teniendo presente que esta se remite en diversas materias, tanto al Código Civil, como por ejemplo en cuidado personal, presunción de paternidad, vicios de la voluntad y declaración de bien familiar, como a la ley de matrimonio civil al regular por ejemplo los impedimentos dirimentes, nulidad del acuerdo de unión civil y otras.

3. Celebración

El art. 5 de la ley, señala que el acuerdo de unión civil se celebrará en el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante cualquier oficial del registro civil, quién deberá levantar acta de todo lo obrado, la cual deberá ser firmada por él y ambos contrayentes.

Esta acta debe ser inscrita en un registro especial que llevará el mismo Servicio.

La celebración puede llevarse a cabo por un mandatario especialmente facultado para este efecto.

²¹ En base a QUINTANA, María Soledad, “El Acuerdo de Unión Civil. Su regulación. Semejanzas y diferencias con el matrimonio en el ordenamiento jurídico chileno”, Revista de derecho de PUCV, Valparaíso, 2015.

²² Ver p. 5.

Salta a la vista que la ley no exige la presencia de dos testigos hábiles, como si se establece en materia de matrimonio. Tampoco se exigen los trámites previos a la celebración del matrimonio.

4. Requisitos de existencia

Son requisitos de existencia del acuerdo de unión civil: i) Consentimiento ii) presencia del oficial del registro civil.

5. Requisitos de validez

Son requisitos de validez del acuerdo de unión civil: i) Mayoría de edad y libre disposición de sus bienes, ii) Ausencia de impedimentos de parentesco o ligamen, iii) Consentimiento libre e informado.

a) Mayoría de edad y libre administración de sus bienes.

El artículo 7 de la ley señala que para la validez del contrato se exige mayoría de edad de los contrayentes y que tengan la libre administración de sus bienes, agregando a continuación: *"No obstante lo anterior, el disipador que se halle en interdicción de administrar lo suyo podrá celebrar, por sí mismo, este acuerdo"*.

b) Impedimentos de parentesco y de ligamen.

El artículo 9 de la ley establece que: "no podrán celebrar este contrato entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado.

Tampoco podrán celebrarlo las personas que se encuentren ligadas por un vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente".

De esta manera, el impedimento de parentesco es idéntico al del matrimonio civil, pero hay que tener presente la diferencia respecto del parentesco por afinidad, que cesa una vez terminado el acuerdo de unión civil. Por lo tanto, terminado el matrimonio en general el cónyuge no puede contraer matrimonio con su suegra porque se mantiene el parentesco por afinidad, no así el conviviente civil.

Por otro lado, no cabe la celebración de acuerdo de unión civil si existe vínculo matrimonial no disuelto o acuerdo de unión civil vigente.

Llama la atención su disminución respecto de la ley de matrimonio, ya que no aparecen mencionados los impedimentos de privación de uso de razón, ni tampoco el de homicidio.

c) Consentimiento libre e informado.

Sólo vician el consentimiento el error y la fuerza. Respecto de la fuerza, la ley se remite al Código Civil. Respecto al error, sólo se refiere al recaído en la identidad del otro

contrayente. No aparece positivado el otro error en las calidades personales, sin embargo parte de la doctrina ha estimado que si debiese proceder toda vez que la persona es una entidad integrada no sólo por su corporeidad.

6. Prohibiciones o impedimentos impeditivos.

La ley 20.830, en su artículo 10, recoge una de las tres establecidas en el Código Civil para el matrimonio, la de segundas nupcias. Por lo tanto, incorpora la exigencia de la mujer de respetar el llamado plazo de soltería (art. 124 a 127 CC). Por otro lado, el artículo 11, repite, en lo sustancial, los artículos 128 y 129 CC.

Es preciso señalar que esta limitación es procedente solo cuando los contrayentes tengan diferente sexo.

Es comprensible la disminución de prohibiciones legales, pues la *ratio legis* de las otras dos es la protección de los menores de edad que contraigan matrimonio y dado el requisito de la mayoría de edad para poder convenir el acuerdo de unión civil, el asenso y las guardas no tienen cabida.

7. AUC celebrado en el extranjero

El art. 12 de la ley establece que los contratos homólogos al acuerdo de unión civil, serán reconocidos en Chile cuando cumplan los requisitos que el mismo artículo establece.

8. Efectos del acuerdo de unión civil

i) Efectos personales

El artículo 14 de la Ley N° 20.830, contempla el deber de ayuda mutua y a solventar los gastos ocasionados por la vida en común, conforme las facultades económicas de los convivientes y del régimen patrimonial que exista.

Curiosamente no consagra el derecho de alimentos recíproco, tampoco del deber de guardarse fe, ni del respeto y protección mutua, ni del auxilio para la litis.

Sorprende que no exista deber de fidelidad, aún cuando se establezca la presunción de paternidad, como vimos anteriormente.

ii) Régimen patrimonial

De la interpretación del artículo 15 de la ley se desprender que si los contrayentes nada dicen se entiende como régimen patrimonial la **separación total de bienes**. Sin embargo, en ese momento, **podrán pactar el régimen de comunidad** que regula el mismo artículo remitiéndose a lo dispuesto en el Código Civil.

iii) Derechos hereditarios.

El art. 16 de la ley establece: "Cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los **mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente.**

El conviviente civil podrá también ser asignatario de la cuarta de mejoras".

Estos derechos sólo se tienen si el AUC está vigente en el momento de la delación de la herencia (art. 18) La ley explicita que se le aplican las causales de desheredamiento del art. 1208, regla 1 del Código Civil.

Finalmente la ley, reconoce el derecho de adjudicación preferente del conviviente civil.

iv) Titularidad activa

Lo que atañe a la indemnización, si uno de los convivientes civiles haya ocasionado perjuicios por un hecho ilícito de un tercero que hubiere causado el fallecimiento del otro conviviente o que lo haya imposibilitado para ejercer por sí mismo las acciones legales correspondientes, tendrá legitimación activa para reclamar estas indemnizaciones y todas aquellas a que el ordenamiento jurídico le reconozca derecho

9. Terminación

El art. 26 establece que el acuerdo de unión civil terminará:

- a) Muerte natural de uno de los convivientes civiles.
- b) Muerte presunta o comprobación judicial de la muerte.
- c) Matrimonio entre los convivientes civiles
- d) Mutuo acuerdo de los convivientes civiles, que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante el oficial del Registro Civil.
- e) Voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles que deberá constar por escritura pública o acta otorgada ante el oficial del Registro Civil.

En cualquiera de estos casos (d y e) deberá notificarse al otro conviviente civil mediante una gestión voluntaria ante el tribunal de familia.

- f) Declaración judicial de nulidad del acuerdo.

El artículo 28 de la Ley N° 20.830 sucintamente declara: "*El término del acuerdo de unión civil pondrá fin a todas las obligaciones y derechos cuya titularidad y ejercicio deriven de la vigencia del contrato*".

10. Compensación económica

El artículo 27 de la ley establece: "*Si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los convivientes civiles no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante la vigencia del acuerdo de unión civil, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se produzca el término del acuerdo por las causales señaladas en las letras d), e) y f) del artículo precedente, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa*". Entonces, si el acuerdo de unión civil termina por mutuo acuerdo, voluntad unilateral o sentencia de nulidad, será procedente la compensación económica si se cumple con el resto de las exigencias.

A continuación, la ley expresa que la *"compensación se regulará y determinará en la forma prevista en los artículos 62 a 66 de la ley N° 19.947"*

Es así como, existe una gran similitud entre la compensación económica de la ley de matrimonio civil y la de la ley que crea el acuerdo de unión civil; los requisitos de procedencia son idénticos, y se someten a las mismas reglas.

Finaliza la disposición ordenando que, si la causal de término fuese la voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, en la notificación deberá expresarse la posibilidad de procedencia del derecho a la compensación y la fecha en que se subinscribió la terminación en el registro especial pertinente, pues el otro de los convivientes tiene un plazo de seis meses contados desde esta fecha para demandar la compensación ante el tribunal de familia que fuese competente.

Al ser muy breve el plazo concedido y la posibilidad de que la notificación no se lleve a efecto, podría este derecho ser una mera declaración, quedando el conviviente que ignora el término del acuerdo en imposibilidad de alegarlo.

Esta es la diferencia sustancial entre una y otra compensación, la del acuerdo de unión civil y la del matrimonio, pues en la establecida para este no se señala un plazo de prescripción de la acción, por lo que serían aplicables las reglas generales.

11. Disposiciones generales

Los conflictos relativos al acuerdo de unión civil serán de competencia de los tribunales de familia, según dispone el art. 22.

Los artículos 22 y 23 buscan la coherencia y concordancia normativa al señalar que todas las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que las leyes y reglamentos establecen respecto al cónyuge se hacen extensivas al conviviente civil. Así como también, las leyes y reglamentos que hacen alusión al conviviente (de hecho) se hacen aplicarán al conviviente civil.

Además establece el derecho a ser oído como pariente.

12. Modificaciones a diversos cuerpos legales

La ley modifica diversos cuerpos legales. Enunciaremos las más relevantes:

1. Salud: Permite al conviviente civil ser carga del otro para el sistema privado de salud y el régimen público de salud.
2. Laboral/Pensiones: Permite ser titular de pensión de sobrevivencia
3. Procesal:
 - a) Suspensión de la vista de la causa por muerte del conviviente civil (165 N°4)
 - b) Rentas inembargables las pensiones del conviviente civil (445 N°4)
 - c) Penal: Art 108 a) también es considerado víctima al conviviente civil junto al cónyuge

	MATRIMONIO	ACUERDO DE UNIÓN CIVIL
Concepto		
Estado Civil	Casado	Conviviente Civil
Edad	Mayor de 18	Mayor de 18
Celebración	Formalidades previas/coetáneas/posteriores	Ante un oficial del registro civil con inscripción en un registro especial
Vicios del Consentimiento	Fuerza y Error con particularidades	Fuerza 1456 y 1457 CC Error en la identidad de la persona
Delegación	Sí	Sí
Prohibiciones	Impedimentos impedientes y dirimentes	Vínculo matrimonial o AUC no disuelto + Impedimentos impedientes relativos + dirimentes de guardas y mujer embarazada
Relaciones personales		Sólo ayuda mutua entre los convivientes civiles
Régimen Patrimonial	Separación de bienes/ Participación en los Gananciales/ Sociedad Conyugal. Éste último será el régimen por defecto si es entre personas de distinto sexo. De lo contrario, es la separación de bienes.	Comunidad/Separación de bienes (por defecto)
Sustitución de régimen	1723 CC	En los mismos términos del 1723 del CC
Derechos Hereditarios	Cónyuge sobreviviente es legitimario	Herederero intestado y legitimario con iguales derechos que el cónyuge sobreviviente. Incluso derecho de adjudicación preferente del art 1337 CC
Filiación	Presunción 184 CC	Presunción 184 CC
Terminación	Muerte natural/presunta/divorcio/nulidad	Muerte natural/presunta + matrimonio/ mutuo acuerdo/ voluntad unilateral (con notificación)

Compensación Económica	Procede	Procede Puede demandarse dentro de 6 meses siguientes a la suscripción de la terminación unilateral (siempre que ésta contenga mención a la existencia del derecho + fecha de notificación de la terminación)
-------------------------------	---------	--

CAPÍTULO 14. ANEXOS.

ANEXO 1: ¿PUEDE PROBARSE EL CESE DE LA CONVIVENCIA POR CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA DEL MATRIMONIO?^{23 24}

El 26 de marzo de 2013, el TC se pronunció en un requerimiento de inaplicabilidad sobre si efectivamente la limitación probatoria establecida en el artículo 2 transitorio de la ley de matrimonio civil, leído junto con los artículos 22 y 25 de la misma, constituye o no una violación a la Constitución. Como se verá en las siguientes líneas, el razonamiento del TC en esta materia es muy complejo y oscuro.

El TC sostiene dos grandes argumentos en esta materia:

- En primer lugar afirma que no existe diferencia entre los medios de prueba con los cuales puede probarse el cese de convivencia en los matrimonios celebrados antes y después de la ley de matrimonio civil, es decir, en ambos escenarios puede usarse cualquier tipo de prueba para acreditar el cese.
- En segundo lugar, el TC sostiene que sí existe una diferencia en materia probatoria respecto de ambos tipos de matrimonios y que ésta se encuentra justificada, surgiendo la pregunta acerca de, ¿cuál es dicha diferencia probatoria?

Para el TC la diferencia probatoria queda demostrada en el considerando decimotercero del fallo en comento. Sostiene que el fundamento de la distinción entre ambos tipos de matrimonio se reduce a evitar el fraude o la simulación. Para ello es que el legislador ha establecido que en el caso de aquellos matrimonios celebrados de forma previa a la ley N° 19.947, cuando se presenten como medios de prueba destinados a probar el cese de la convivencia aquellos instrumentos enumerados en los artículos 22 y 25, el legislador ha autorizado al juez a apartarse de ellos cuando existan otros medios de prueba que afirmen una fecha de cese de la convivencia distinta.

Esto supone que en el caso de aquellos matrimonios celebrados con posterioridad a la ley, cuando las partes presentan los medios de prueba contemplados en los artículos 22 y 25, el juez en este escenario no tiene dicha facultad y, por tanto, no puede desconocerlos, aunque existan otros medios. Se observa que la limitación probatoria que identifica el TC no pasa por cuáles medios probatorios pueden usarse para probar el cese de la convivencia, sino si el tribunal, habiendo sido presentados aquellos medios contemplados en los artículos mencionados, puede o no ignorarlos.

²³ STC Chile, de 26 de marzo de 2013, requerimiento de inaplicabilidad rol N° 2207-12-INA.

²⁴ Cfr. FUENTES, Claudio. Comentarios de Jurisprudencia, RChDP, no.20, Santiago, jul. 2013, [En línea] <http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722013000100016&script=sci_arttext>

ANEXO 2: LA LESBOMATERNIDAD EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE

Existen dos fallos recientes que han reconocido la lesbomaternidad, ordenándose por tanto al Registro Civil que practique la inscripción de hijos de parejas homoparentales.

El primero de estos fallos se dictó durante el año 2020, luego de que en 2017 se rechazó inscribir a De Ramón como madre del hijo que había sido fecundado junto a su conviviente civil mediante el mecanismo de reproducción asistida. La razón que esgrimió el registro civil fue que el sistema únicamente permitía inscribir una madre y un padre. Ante la decisión se interpuso un recurso de protección que fue rechazado tanto por la Corte de Apelaciones como por la Corte Suprema.

No obstante, con posterioridad ambas decidieron que Di Giammarino interpusiese una demanda de reconocimiento de filiación en contra de De Ramón, con el propósito de que reconociese su maternidad y así los derechos y deberes que tiene respecto de su hijo. La demanda fue interpuesta ante el Segundo Tribunal de Familia, el cual acogió la demanda y ordenó al Registro Civil inscribir al niño como hijo de dos madres.

Los principales argumentos del fallo fueron los siguientes:

“La hipótesis de una desigualdad ante la ley se expresaría en dos niveles: primero, una desigualdad entre la representación de familia que figura en el derecho y las formas familiares concretas, mientras que en un segundo nivel queda la consecuencia inmediata de la primera brecha, que muchas familias de facto no son consideradas como tales, lo que ocasiona problemas concretos en su vida cotidiana”.

“La no aplicación del artículo 182 del Código Civil a este caso implica un doble atentado a la igualdad ante la ley: priva a Attilio José del reconocimiento de sus derechos de hijo de Emma de Ramón (quien se sometió en conjunto con la demandante a la Técnica de Reproducción Asistida, y además afectiva, y socialmente es su madre), dejándolo en una situación de desventaja frente a otros niños, que hubieran nacido en las mismas condiciones, pero cuyos progenitores sean una pareja de distinto sexo, con orientación heterosexual. Y, además, viola el derecho a la igualdad ante la ley de la demandada, quien, a pesar de haber participado en un proceso de reproducción asistida junto a su conviviente civil, concurriendo en ella voluntad procreacional, no puede reconocer legalmente al hijo nacido gracias a tal procedimiento”.

Además la sentencia hace referencia a que existiría un vacío legal en la ley que permite el sistema de reproducción asistida, ya que no regula la situación filiativa de los niños nacidos a raíz de donación de gametos no pertenecientes a los padres o a la pareja que se somete al procedimiento, en que los donantes no pueden reclamar la paternidad. “Frente a este vacío legal, y a objeto de resolver esta acción, resulta necesario observar el derecho internacional como parte del bloque constitucional de derechos fundamentales, realizando una interpretación integradora de la Constitución. Es esta interpretación la que permite dar un mayor resguardo y efectividad a los derechos fundamentales inherentes al ser humano, y que afectan a los intervinientes y afectados

por esta causa, especialmente, el derecho a la igualdad, el derecho a la identidad, a la vida familiar y el interés superior del niño”.

“La identidad del niño Attilio José está determinada por su origen y contexto familiar y social. Las personas que tomaron la decisión de traerlo a este mundo son demandante y demandada, ellas expresaron su voluntad procreacional, siendo esta tan importante que el legislador excluye al donante de gameto de todo derecho filiativo respecto de Attilio José. En cuanto a su entorno familiar y social determinado por sus lazos afectivos, él reconoce a la demandada como su madre: le da protección, seguridad, afecto y contención; familiares, cercanos y referentes formativos educacionales del niño, también la identifican, reconocen y respetan como tal”

Se hace también mención en el fallo al interés superior de niño, disponiendo que “el niño tiene derecho a la vida familiar, a preservar sus relaciones familiares, de tal manera que resulta vulneratorio que la ley impida que la filiación legal sea reflejo de la verdadera situación familiar del niño y su familia y se deslegitime de esa forma la posibilidad de reconocimiento y valoración social a una forma de hacer familia cuyo amparo se encuentra consagrado no sólo en el ámbito internacional sino en la propia constitución como ha sido expresado en forma previa y cuya única justificación se basa en una categoría sospechosa de discriminación de un colectivo históricamente postergado en razón de su orientación sexual”.

El segundo de los fallos se dictó en el presente año, y fue dictado por el Juzgado de Familia de Antofagasta, en donde la argumentación de la jueza se basó principalmente en el principio de igualdad que debía asistir tanto a la madre como al niño y al derecho a la identidad del niño.

Así dispone el fallo que “si bien en el presente juicio se ha podido acreditar por las partes que son una familia, que el niño se siente parte integrante de ésta, que tiene un círculo de cercanos que lo reconocen como tal en su día a día, existiendo las competencias parentales de ambas partes para seguir detentando el cuidado personal de su hijo como lo han venido haciendo desde antes, inclusive, de su nacimiento; no cabe más que concluir que el elemento que falta en el presente caso es el pronunciamiento judicial para reconocer dicha situación y por tanto dar protección legal al niño de autos como corresponde, aplicando normas internacionales que son plenamente vigentes en Chile y que vienen a concretar los derechos del niño”.

Continúa acusando que denegar la inscripción discrimina “tanto al niño como su madre por cuanto pierden derechos que podrían ejercer al ser reconocida como madre y que sí tienen otros niños que tienen padre y madre, como son el derecho que tendría el niño a pedir alimento a esta madre, tener derechos sucesorios sobre esta segunda madre y que, en caso de separación de estas madres, pudiera la madre que no aparece inscrita, pedir cuidado personal del niño y ejercerlo o también tener un relacionamiento y poder pedir el que se conoce como derecho de visitas”.

Así, vemos como la jurisprudencia más reciente ha venido dando pequeños pasos de avance hacia la igualdad y la defensa de los derechos de las familias homoparentales,

fundándose en los principios de igualdad, no discriminación, y de interés superior del niño.

ANEXO 3: LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

I. Cuestiones preliminares

Con fecha 10 de diciembre del año 2018, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.120 que "Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género".

La ley en comento tiene como objeto la necesidad de dar respuesta a un gran problema que las personas trans han debido enfrentar durante años: la falta de reconocimiento legal de su identidad de género, cuando ésta no corresponde con el sexo asignado al nacer.

Esta ley reconoce y garantiza el **Derecho a la Identidad de Género**, entendiendo por tal, la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar su rectificación.

En su artículo 3º, la ley establece una **garantía específica derivada de la identidad de género**, referida a que *toda persona tiene derecho a ser reconocida e identificada conforme a su identidad de género, una vez realizada la rectificación de su partida de nacimiento*. La Ley refiere expresamente a esta garantía en los instrumentos públicos y privados que acrediten su identidad, además de las imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas figuren en los registros oficiales.

Posteriormente el **artículo 4º establece garantías asociadas al goce y ejercicio** del derecho a la identidad de género

Los principios relativos al derecho a la identidad de género, desarrollados en el artículo 5º de la ley, refieren a: a) Principio de la no patologización; b) Principio de la no discriminación arbitraria; c) Principio de la confidencialidad; d) Principio de la dignidad en el trato; e) Principio de interés superior del niño; f) Principio de la autonomía progresiva.

En consecuencia, esta ley tiene por objeto **regular los procedimientos** para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo y nombre, ante el órgano administrativo o judicial respectivo, cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género y sus efectos.

Este derecho también puede ser **ejercido por menores de dieciocho y mayores de catorce años** a través de sus representantes legales, siendo competente el tribunal de familia del domicilio del solicitante.

II. Definiciones

1. **Sexo:** Se refiere al conjunto de características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres.
2. **Género:** Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad en una época determinada considera propios de cada sexo.
3. **Identidad de género:** La ley 21.120 señala en su artículo 2º que, *"para efectos de esta ley, se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción del nacimiento"*.

III. Objeto de la ley

El objeto de la ley en comento es el de regular los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona, en lo relativo a su sexo y nombre, ante el órgano administrativo o judicial respectivo, **cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género**²⁵.

IV. Procedimientos que regula la ley 21.120.

El artículo 2º de la Ley, consagra que su objetivo es regular los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su nombre y sexo cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género. Para acceder a la rectificación de partida se consagran dos procedimientos²⁶:

1) **Uno administrativo para mayores de edad sin vínculo matrimonial vigente:** se realiza ante cualquier oficina del Registro Civil e Identificación, hasta por dos veces, mediante trámite que no puede durar más de 45 días, desde que se presenta la solicitud.

Una vez recibida la solicitud el Registro Civil e Identificación debe citar a la persona solicitante a una audiencia con dos testigos. Cabe destacar que no se podrán requerir antecedentes adicionales para acoger la solicitud a tramitación y sólo puede rechazarse en una causal calificada: la edad (El requisito de la no existencia de vínculo matrimonial se eliminó en virtud de la ley 21.400 acerca del matrimonio igualitario).

En un plazo máximo de cuarenta y cinco días, contado desde la presentación de la solicitud, el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar la correspondiente orden de servicio, la que podrá acoger, rechazar fundadamente la solicitud, o declararla inadmisibles. Sólo procederá el rechazo de la solicitud por no haber acreditado el requirente su identidad o por no haberse verificado la declaración del solicitante y de los testigos hábiles en los términos indicados en el inciso segundo anterior.

²⁵ En ningún caso el órgano administrativo o judicial, según se trate, podrá exigir modificaciones a la apariencia o a la función corporal del solicitante, a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, para dar curso, rechazar o acoger las rectificaciones referidas en el inciso precedente.

²⁶ Para la implementación de ambos tipos de procedimientos se han dictado reglamentos en agosto 2019.

El Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación declarará inadmisibles las solicitudes únicamente cuando concurra la siguiente causal:

- a) La formulare una persona que no hubiere alcanzado la mayoría de edad.
- b) (ya no es necesario que la persona no se encuentre casada).

En caso de inadmisibilidad de la solicitud, el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá informar al solicitante de los procedimientos judiciales que establece la presente ley. Acogida la solicitud de rectificación por el Registro Civil o recibida la sentencia judicial firme, se procederá a emitir los nuevos documentos identificatorios.

2) Otro para mayores de 14 y menores de 18 que, aunque sea administrativo, se tramita ante tribunales: se encuentra radicado en los tribunales de familia, siendo tribunal competente el tribunal de familia del domicilio del solicitante.

La solicitud deberá ser fundada, exponiendo con claridad y precisión los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se apoya, con indicación precisa de las peticiones concretas que se someten al pronunciamiento del tribunal. Además, deberá señalar las razones conforme a las cuales, a juicio del solicitante, la pretensión hecha valer es beneficiosa para el mayor de catorce y menor de dieciocho años, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la presente ley.

Además se deberá señalar con claridad hechos y fundamentos de derecho. El juicio ante los tribunales de familia se estructura en tres etapas: i) audiencia preliminar, ii) preparatoria y iii) la audiencia de juicio. Las primeras audiencias se realizan de manera inmediata, siendo la primera en la cual la persona adolescente manifestará su voluntad sobre el cambio registral.

V. De la solicitud de rectificación de las personas con vínculo matrimonial vigente.

La solicitud de rectificación efectuada por personas con vínculo matrimonial vigente deberá ser fundada, exponiendo con claridad y precisión los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se apoya, con indicación precisa de las peticiones concretas que se someten al pronunciamiento del tribunal e individualizando al cónyuge no solicitante. El tribunal que acoja la solicitud de rectificación de una persona con vínculo matrimonial vigente, ordenará que la resolución judicial que acoge la solicitud sea notificada a su cónyuge. Asimismo, cuando se acoja una solicitud administrativa de rectificación de una persona con vínculo matrimonial vigente, el Servicio de Registro Civil e Identificación informará de la rectificación a su cónyuge.

La persona cuya solicitud de rectificación sea acogida podrá concurrir al tribunal con competencia en materias de familia correspondiente al domicilio de cualquiera de los cónyuges, a fin de solicitar que ordene la disolución del vínculo matrimonial. La solicitud se podrá formular dentro del plazo de seis meses contado desde la notificación o información señalada en el artículo anterior.

Los cónyuges tendrán derecho a demandar compensación económica de conformidad a las disposiciones del Párrafo 1º del Capítulo VII de la Ley de Matrimonio Civil.

ANEXO 4: LEY SOBRE DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS POR ACUERDO DE LOS PADRES

Con fecha 14 de mayo de 2021, fue publicada la ley 21.344, que modifica el régimen para la determinación de los apellidos en Chile, introduciendo la posibilidad de que, de común acuerdo, madre y padre establezcan un orden diverso de los apellidos del que procedería tácitamente (primero el del padre y luego el de la madre). Su entrada en vigencia se encuentra diferida hasta la dictación del reglamento que indica su art.6, el cual se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos²⁷.

Así, este cuerpo normativo incorpora al Código Civil un nuevo párrafo al Título primero (el cual pasa a llamarse "De las personas, en cuanto a su nombre, nacionalidad y domicilio"), a través de los arts. 58 bis y ter.

El art.58 bis. incorpora una definición de nombre, entendiendo tal como "el conjunto de palabras que sirve legalmente para identificar a una persona, el que está formado por el o los nombres propios, y por el o los apellidos con que se encuentra individualizada en su respectiva inscripción de nacimiento".

A su vez, el art.58 ter. crea el siguiente procedimiento para determinar los apellidos:

1. En la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes, los progenitores determinarán, de común acuerdo, el orden de transmisión de sus respectivos primeros apellidos, que valdrá para todos sus hijos comunes. En caso de no manifestarse acuerdo al momento de inscribir al primero de los hijos comunes, se entenderá su voluntad de que el orden de los apellidos sea determinado mediante sorteo ante el Oficial del Registro Civil.
2. En toda inscripción de nacimiento en que al tiempo de la inscripción quede determinada la filiación del nacido respecto de ambos progenitores, el oficial del Registro Civil procederá según el orden de los apellidos fijado en la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes de dichas personas; y si no tuvieran más hijos comunes, según el orden que se determine al practicarse la inscripción, de conformidad a lo dispuesto en la regla precedente.
3. En el caso del hijo cuya filiación no se encuentra determinada al tiempo de la inscripción, se realizará con el primer apellido de la persona respecto de la cual la filiación sí se encuentre determinada²⁸.

Si posteriormente se produjera la determinación y existen hijos comunes de dichos padres, se estará al orden fijado. Si no hay, se mantendrá como primer apellido el de cuya filiación se encontraba determinada al tiempo de la inscripción, a menos que, de común acuerdo, se manifieste voluntad de invertirlos.

Asimismo, en miras a mantener la armonía en nuestro ordenamiento, introduce una serie de modificaciones en esta línea a las leyes N°4.808 (sobre Registro Civil), N° 19.477

²⁷ La ley otorga un plazo de cuatro meses desde la publicación, el cual vence en septiembre de 2021.

²⁸ Es decir, en esos casos, quedará inscrito con un solo apellido, el primero de la madre o del padre, según el caso.

(Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación) y N° 17.344 (que autoriza el cambio de nombres y apellidos).

Dentro de las modificaciones relevantes encontramos el reconocimiento de la posibilidad de hacer el cambio del orden de los apellidos a todas las personas mayores de edad por una sola vez, sean nacionales o extranjeros (en el caso de los segundos sólo respecto de sus documentos de identificación chilenos y acreditando su permanencia en Chile). Así, esta posibilidad se encuentra limitada exclusivamente para quienes estén actualmente siendo procesadas o formalizadas, o tuvieran a su haber órdenes de arresto o detención pendientes, o se encontraran sujetas a otras medidas cautelares personales, o hubieren sido condenadas por crimen o simple delito, sin perjuicio de las excepciones que indica (salvo las personas que están condenadas por delitos sexuales, quienes nunca podrán cambiar el orden de sus apellidos).

Ante la solicitud, el SRCEI se reserva la posibilidad de aceptar, rechazar o declarar inadmisibles las solicitudes por no cumplir con las exigencias legales, o fallar en acreditar la identidad o el cumplimiento de los requisitos en cuestión.

Acogida la solicitud del requirente, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a practicar las modificaciones y subinscripciones pertinentes, tras lo cual se emitirán los nuevos documentos identificatorios², debiendo, además, informar a las instituciones que se indica, así como aquellas que señale el solicitante fundadamente.

En el caso de que la persona solicitante tenga hijos, la modificación de su partida implicará también la de las partidas de sus hijos menores en relación con el apellido de transmisión, mientras que si son mayores de 14 años y menores de 18 será necesario que estos consientan en la modificación de su propia inscripción, y en el caso de ser mayores de edad deberán solicitar la rectificación directamente.

Finalmente, la ley indica que la rectificación no afectará la filiación ya determinada, ni la titularidad de derechos y obligaciones, contemplando la sanción de presidio menor en su grado mínimo para todo quien haga uso de sus apellidos en el marco de las posibilidades que otorga esta ley (originales o modificados) para eximirse, dificultar o eludir el cumplimiento de cualquier obligación.

ANEXO 5: DISPOSICIONES TRANSITORIAS LEY 21.515

Artículo primero.- A las personas que, siendo menores de edad, hubieren celebrado un matrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, se les aplicarán las siguientes reglas especiales:

1º. Si estando en vigencia esta ley continuaren siendo menores de edad, podrán ejercer por sí mismas la acción de divorcio, sin perjuicio de su derecho a actuar por medio de representantes.

2º. Podrán solicitar la acción de divorcio unilateralmente o de común acuerdo, sin encontrarse afectas a la acreditación del cese de convivencia dispuesta en los incisos

² 29 La modificación no altera el rol único nacional del solicitante.

primero y tercero del artículo 55 de la ley N° 19.947, que establece nueva Ley de Matrimonio Civil. En este caso, la acción sólo podrá ser interpuesta por el cónyuge que contrajo matrimonio siendo menor de edad.

Artículo segundo.- Respecto de las personas que, siendo menores de edad, hubieren celebrado un matrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y que, durante la vigencia de ésta, rectificaran su nombre y sexo registral siendo menores de edad, el tribunal deberá notificar la resolución que disponga dicha rectificación al otro cónyuge, aplicándose lo dispuesto en el Título IV bis de la ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género.".
